2026 제37회 공인중개사 시험 대비 · 합격 요약노트

민법 및 민사특별법

민석기 강사 강의자료 기반 · 총 17단원

차례

제1장 법률행위와 의사표시 (민법총칙 ①)

제2장 대리 (민법총칙 ②)

제3장 무효와 취소, 조건과 기한 (민법총칙 ③)

제4장 물권법 총론 - 물권의 효력과 물권변동

제5장 점유권

제6장 소유권

제7장 용익물권

제8장 담보물권

제9장 계약법 총론

제10장 매매·교환

제11장 임대차(민법)

제12장 주택임대차보호법

제13장 상가건물임대차보호법

제14장 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률

제15장 가등기담보 등에 관한 법률

제16장 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률

99. 시험 직전 최종점검

제1장 법률행위와 의사표시 (민법총칙 ①)

민법 40문제 출제 구조(강사 제시)
민법총칙 **10문제** / 물권법 **14문제** / 계약법 **10문제** / 민사특별법 **6문제**. 합격선은 과목 40점 이상·1차 평균 60점 이상이다. 지문의 대부분이 **"판례의 결론"**을 묻는다. "가능/불가능, 유효/무효, 인정/부정"의 결론을 정확히 외우는 것이 곧 점수다.

권리변동과 법률행위의 기초 ★★

권리취득의 분류

구분	내용	대표 예
원시취득	타인의 권리에 기초하지 않고 새로 취득. 종전 권리의 **제한·하자를 승계하지 않는다**.	건물 신축, 무주물 선점·유실물 습득·매장물 발견, **선의취득**, **취득시효**, 첨부(부합)
승계취득 - 이전적 - 특정승계	개개의 권리를 개별 원인으로 취득	매매, 증여, 교환
승계취득 - 이전적 - 포괄승계	하나의 원인으로 권리·의무 일체를 취득	상속, 포괄유증, 회사합병
승계취득 - 설정적 승계	소유권은 그대로 두고 제한물권을 새로 설정받음	지상권·전세권·저당권 **설정계약**에 의한 취득

- 설정계약에 따른 지상권 취득 = **법률행위**에 의한 취득(승계취득). 민법 제366조 법정지상권 취득 = **법률규정**에 의한 취득.
- 상속에 의한 전세권 취득은 승계취득이므로 하자·제한을 그대로 승계한다.

법률행위의 요건

구분	내용	결여 시
성립요건	당사자, 목적, 의사표시	불성립
일반 효력요건	당사자의 능력(권리능력·의사능력·행위능력), 목적의 **확정·가능·적법·사회적 타당성**, 의사와 표시의 일치 및 하자 없음	무효 또는 취소
특별 효력요건	대리행위의 대리권, 조건·기한, **토지거래허가구역의 허가** 등	효력 불발생

- 의사무능력자의 법률행위 = **무효**, 제한능력자(미성년자·피한정후견인·피성년후견인)의 법률행위 = **취소할 수 있다**(취소 전까지는 유효).
- **농지취득자격증명**은 농지 매매의 효력발생요건이 **아니다**(증명 없이 체결한 매매계약도 유효). 반면 **토지거래허가**는 매매계약의 **효력발생요건**이다.
- 목적은 계약 체결 당시 확정되어 있을 필요는 없고 **이행기까지 확정될 수 있으면** 된다.

법률행위 목적의 불능

구분	계약의 효력	책임
원시적 불능(계약 당시 이미 불능. 체결 당시 법률로 금지된 경우 포함)	**무효**	계약체결상의 과실책임(제535조) = **법률규정상 책임**. 악의·과실 있는 자가 선의·무과실의 상대방에게 **신뢰이익**(이행이익 한도) 배상
후발적 불능 - 채무자 귀책 O	**유효**	채무불이행(이행불능) 책임 → 최고 없이 해제 + 손해배상
후발적 불능 - 채무자 귀책 X	**유효**	위험부담(제537조·제538조) 문제

매매예약 후 예약완결권 행사 전에 목적물이 멸실되면 예약완결권을 행사할 수 없다(옳은 지문). 매도인 귀책으로 목적물이 멸실되어도 매매계약이 효력을 잃는 것이 아니라 이행불능 책임이 생길 뿐이다.

법률행위의 종류 - 단독행위와 계약

구분	해당하는 것
상대방 있는 단독행위	취소, 추인, 동의, 채무면제, 상계, **법정해제·약정해제·계약금 해제·담보책임에 의한 해제**, 해지, **공유지분의 포기**, **취득시효 이익의 포기**, 수권행위 철회
상대방 없는 단독행위	유언(유증), 재단법인 설립행위, **소유권의 포기**
계약	매매, 교환, 임대차, 증여, **합의해제(해제계약)**

함정 주의

- "해제"라는 이름이 붙어도 **합의해제만 계약**이고 나머지(법정·약정·해약금 해제)는 모두 단독행위다.
- 포기 3형제: **소유권 포기 = 상대방 없는** 단독행위 / **공유지분 포기·시효이익 포기 = 상대방 있는** 단독행위.
- 단독행위에는 원칙적으로 조건을 붙일 수 없으나 **채무면제·유증**처럼 상대방에게 이익만 주는 경우에는 조건을 붙일 수 있다.

강행규정(효력규정과 단속규정) ★★★

규정의 종류	위반행위의 사법상 효력
강행규정 중 **효력규정** 위반	**무효**
강행규정 중 **단속규정** 위반	**유효**(처벌만 받음)
임의규정과 다른 약정	유효

쟁점(강사 핵심요약)	결론
공인중개사의 법정한도 초과 중개보수 약정	**초과부분만 무효**(일부무효)
무자격자(공인중개사 자격 없는 자)가 중개업을 하면서 한 보수약정	**전부 무효**(한도 내 부분도 무효)
개업공인중개사와 중개의뢰인의 직접거래(자기계약) 금지 규정	**단속규정 → 거래는 유효**
증권회사와 고객의 **투자수익보장** 약정	**무효**
증권회사와 고객의 **일임매매** 약정	**유효**
미등기 전매·중간생략등기(조세포탈 목적 포함)	원칙 **유효**(단속규정). 형사처벌 대상이어도 사법상 효력은 있다
토지거래허가구역 내의 중간생략등기	**무효**
공공주택 전매금지기간 위반 - **공공분양주택** 전매	**유효**(단속규정)
공공주택 전매금지 위반 - **공공임대주택** 임차권 양도·전대	**무효**
공공임대주택 **임대료 상한** 규정 위반	**효력규정 위반 → 초과 약정 무효**
농지의 임대차 계약(농지법 위반)	반사회적 행위가 아니라 **강행규정 위반**으로 무효

핵심 암기 - 강행규정(효력규정) 위반으로 무효인 경우의 효과

- 선의의 제3자에게도 무효로 대항 **가능**(절대적 무효).
- 무효행위의 추인 **불가능**.
- 위반한 자 스스로 무효를 주장하는 것도 **가능**(신의칙 위반 아님).
- 표현대리 법리 적용 **불가능**(토지거래허가제 위반 계약은 표현대리로 유효가 될 수 없다).

반사회질서의 법률행위(제103조) ★★★

선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 **무효**. **절대적 무효**(선의의 제3자에게도 대항 가능), 추인 불가, **불법원인급여**이므로 이행한 것의 반환청구 불가(부당이득반환은 물론 **소유권에 기한 반환청구도 불가**).

유형	반사회적 행위 O (무효)	반사회적 행위 X
첩(부첩) 계약	첩계약, **부첩관계의 종료를 해제조건으로 한 증여**	첩관계를 **단절하면서** 생활비·양육비를 지급하기로 한 약정
도박	도박자금 대여, 도박채무 변제약정, 도박채무 변제에 충당하는 행위	도박채무 변제를 위해 **도박채권자에게 부동산 처분의 대리권을 수여**한 행위(그 대리인과 거래한 제3자와의 매매는 유효)
진술(증언) 대가	**허위**진술의 대가 약정 / 사실대로 증언하는 대가라도 **통상 용인되는 상당한 수준을 초과**한 경우	진실한 진술의 대가가 상당한 수준(여비·일당 등) 이내
성공보수	**변호사 아닌 자**에게 지급하기로 한 약정 / 변호사의 **형사사건** 성공보수	변호사의 **민사사건** 성공보수
비자금·뇌물	뇌물·비자금을 **수수하는 행위**	비자금을 소극적으로 은닉하기 위해 **임치**한 행위
전통사찰	주지직을 거액의 금품으로 **양도·양수하는 거래행위**	그 거래를 알고 묵인·방조한 종교법인의 **주지 임명행위**
해외파견 경비	**연수 목적이 없는** 파견(실질이 근로)인데 퇴사 시 경비를 반환하기로 한 약정	교육·연수 목적 해외파견 후 일정기간 의무근무 약정·사규
기타	보험금 부정취득 목적의 다수 생명보험계약, 평생 이혼하지 않겠다는 약정	**강제집행 면탈 목적의 허위 근저당권설정**(→ 통정허위표시로 무효일 뿐), 양도소득세 회피 목적의 다운계약·미등기전매, 조세포탈 목적 명의신탁, 투기 목적의 세입자입주권 다수 매입

핵심 암기

- **동기의 불법**: 동기가 **표시되거나 상대방에게 알려진 경우**에 무효가 된다.
- 법률행위의 **성립과정에 강박**이라는 불법적 방법이 사용된 데 불과한 경우 → 반사회적 행위 아님. **취소** 사유(제110조)일 뿐이고 비진의표시도 아니다.
- 강행규정 위반이 아니어도, 불공정한 법률행위에 해당하지 않아도 반사회적 법률행위가 될 수 있다.

부동산 이중매매 (甲이 乙에게 매도 후 丙에게 다시 매도·등기)

쟁점	결론
원칙	이중매매는 유효. 먼저 등기한 丙이 소유권 취득. 乙은 甲에게 **최고 없이 해제**(이행불능) + 손해배상 청구
무효가 되는 경우	丙이 단순 **악의인 것만으로는 부족**, 甲의 배임행위에 **적극 가담**한 경우에 반사회적 행위로 무효
丙으로부터 전득한 丁	절대적 무효 → 丁이 **선의여도 소유권 취득 불가**
甲 → 丙 말소등기 청구	**불가능**(불법원인급여)
乙 → 甲 이전등기 청구	**가능**
乙 → 丙 직접 이전등기(또는 말소) 청구	**불가능**
乙이 甲을 **대위**하여 丙에게 말소등기 청구	**가능**
丙이 乙(점유자)에게 소유권에 기한 물권적 청구를 한 경우	乙은 丙 명의 등기의 무효를 주장할 수 있다

불공정한 법률행위(제104조) ★★★

당사자의 **궁박, 경솔 또는 무경험**으로 인하여 현저하게 공정을 잃은 법률행위는 무효.

쟁점	결론
궁박·경솔·무경험	셋 중 **하나만** 있으면 된다(모두 필요 X)
궁박의 범위	경제적 궁박 + **정신적·심리적 궁박 포함**
무경험의 의미	특정 영역이 아니라 **거래 일반**의 경험 부족
폭리자의 악의	상대방의 궁박 등을 알고 이용하려는 **폭리의사 필요**. 없으면 불성립
추정 여부	급부 간 현저한 불균형이 있어도 궁박·경솔·무경험은 **추정되지 않는다** → 무효 주장자가 모든 요건 입증
판단 시점	**법률행위 당시** 기준
대리행위의 경우	**궁박은 본인** 기준, **경솔·무경험은 대리인** 기준
적용 제외	**무상행위(증여·기부)**, **경매**
선의의 제3자	대항 **가능**(절대적 무효)
추인 / 전환	추인 **불가능** / 무효행위 **전환은 가능**
반환청구	**폭리자는 반환청구 부정**, **피해자는 반환청구 인정**(불법원인이 폭리자에게만 있음)

법률행위의 해석 ★★

- **자연적 해석(오표시무해의 원칙)**: 甲·乙이 X토지를 매매하기로 합의했으나 계약서에 Y토지로 잘못 표시 → 계약은 **X토지에 대하여 성립**. Y토지 등기는 원인무효(甲은 말소청구 가능, 乙로부터 Y토지를 전득한 자는 **선의여도 소유권 취득 불가**). 乙은 X토지의 이전등기 청구 가능. **착오 취소는 불가**(의사와 표시가 실질적으로 일치).
- **계약 당사자 확정**: 당사자 의사가 일치하면 **그 일치된 의사대로**(계약서 기재와 무관), 일치하지 않으면 **계약서의 표시 등 규범적 해석(상대방의 합리적 관점)**에 따라 확정한다.
- 명백히 표시한 사항에는 보충적 해석을 할 수 없다.
- 임대차계약서의 "모든 권리금을 인정함" = 임대인이 권리금 **반환을 약정한 것이 아니다**(임차인이 나중에 양수인에게서 권리금을 받는 것을 용인한다는 뜻).
- **사실인 관습**: 임의규정과 다른 관습이 있고 당사자 의사가 명확하지 않으면 그 관습에 의한다(제106조). **관습법**은 법원이 직권으로 조사·적용.

비진의표시(제107조)·통정허위표시(제108조) ★★★

구분	의사와 표시	효력	선의의 제3자
비진의표시	불일치를 표의자가 **알고**	원칙 **유효**. 상대방이 알았거나 알 수 있었을 경우 **무효**	대항 불가
통정허위표시	상대방과 **짜고**	**무효**	대항 불가
착오	불일치를 **모르고**	중요부분 착오 시 **취소**(중과실이면 불가)	대항 불가
사기·강박	의사=표시, 형성과정에 하자	**취소**	대항 불가

비진의표시 판례

- '진의'란 **특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각**이지, 마음속으로 진정 바라는 사항이 아니다.
- 강박에 의해서나마 **증여를 하기로 하고** 의사표시를 한 경우 → 비진의표시 **아니다**(진의 있음).
- 대출한도 초과 채무자를 위해 제3자가 **명의를 빌려주어** 대출약정서에 채무자로 서명 → 채무부담 의사가 있으므로 비진의표시 **아니다**(유효한 채무자).
- 공무원의 사직서 제출 등 **공법행위**에는 제107조 **적용 안 됨**(표시대로 유효).

- **대리권 남용**: 대리인이 자기 또는 제3자의 이익을 위해 대리권을 행사한 경우 제107조 1항 단서 **유추적용** → 원칙 유효, 상대방이 알았거나 알 수 있었으면 무효(본인 책임 없음). 법정대리에도 적용. 선의의 전득자에게는 대항 불가.

통정허위표시 판례

- 제3자 명의 대출약정은 원칙 유효. **채권자(금융기관)가 양해**하여 명의대여자에게 책임을 지우지 않기로 한 경우에만 통정허위표시로 무효.
- 가장매매도 **채권자취소권의 대상**이 된다. 허위표시 자체는 불법원인급여가 아니다(반환청구 가능). 추인하면 **새로운 법률행위**로서 그때부터 유효.
- 제3자는 **선의로 추정** → **무효를 주장하는 자가 제3자의 악의를 입증**. 제3자는 **선의이면 족하고 무과실은 불필요**.
- 선의의 제3자에게는 허위표시 당사자뿐 아니라 **그 누구도** 무효를 주장할 수 없다. 선의의 제3자로부터 전득한 자는 악의여도 보호(엄폐물 법칙).
- **은닉행위**: 증여를 매매로 가장 → 매매는 무효, **증여는 유효** → 수증자는 소유권 취득, 그로부터 매수한 자는 **선의·악의 불문** 소유권 취득.
- 가장매매에서 甲은 乙에게 진정명의회복을 원인으로 한 이전등기를 청구할 수 있다(선의의 저당권자 丙이 있어도 저당권 부담을 안은 채로 가능).

허위표시의 제3자에 해당 O	해당 X
가장양수인으로부터 매수·저당권설정·**가등기**를 받은 자 / 가장매매 대금채권·가장채권을 **양수하거나 (가)압류한 자** / 가장채권자가 파산한 경우의 **파산관재인** / 허위의 보증채무를 이행하고 **구상권을 취득한 보증인**	계약상 지위를 **인수한 자**(계약인수인) / 제3자를 위한 계약의 **수익자** / 상속인 등 포괄승계인 / 대리인이 허위표시를 한 경우의 본인 / 채권 가장양도에서의 채무자

착오에 의한 의사표시(제109조) ★★★

쟁점	결론
동기의 착오	동기가 **표시**되어 의사표시의 내용이 된 경우 취소 가능. 내용으로 삼기로 하는 **합의까지는 불필요**. 상대방이 **유발(제공)한 동기의 착오**는 표시 없어도 취소 가능
중요부분 착오 O	토지의 **현황·경계** 착오(대지로 알고 샀는데 대부분 하천부지), 보증계약에서 주채무자의 **동일성** 착오, 연대보증 서류를 신원보증 서류로 잘못 안 경우(제3자 기망 → **착오 법리**로 판단)
중요부분 착오 X	토지의 **시가·지적(면적)** 착오, 주채무자의 **자력**에 관한 착오, 장래의 막연한 기대가 어긋난 경우, 표의자에게 **경제적 불이익이 없는** 경우
표의자의 과실	**경과실**만 있으면 취소 가능 / **중과실**이면 원칙 취소 불가 / 상대방이 표의자의 착오를 **알고 이용**한 경우에는 중과실이어도 취소 가능
입증책임	중요부분 착오 = **취소하려는 자(표의자)** / 표의자의 중과실 = **취소를 저지하려는 자(상대방 = 유효 주장자)**
취소한 자의 손해배상	경과실로 착오에 빠져 취소해도 **불법행위 손해배상책임 없다**
경합	착오와 사기 → 선택 **가능** / 착오와 매도인의 담보책임 → 선택 **가능** / 매도인이 **해제한 후에도** 매수인은 착오 취소 **가능**
배제특약	제109조는 임의규정 → 착오 취소권 배제 특약 **가능**

중과실 판례: 공인중개사의 말만 믿고 목적물을 확인하지 않은 매수인은 중과실이 아니다. 공장 설립 목적 매수인이 관할관청에 건축 가능 여부를 확인하지 않은 것은 중과실.

사기·강박에 의한 의사표시(제110조) ★★★

- 기망은 **고의**가 필요(과실에 의한 기망은 취소사유 X). 묵시적 기망(고지의무 위반)도 가능.
- 교환계약에서 **시가를 묵비하거나 시가보다 높게 고지**한 것 → 위법한 기망 **아니다**. 백화점 **변칙세일**(원가 허위표시) → 위법한 기망 O.
- 의사결정의 자유가 **완전히 박탈**될 정도의 강박 → **무효**. 제한하는 정도에 그치면 취소.
- **제3자의 사기·강박**: 상대방이 그 사실을 **알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여** 취소 가능. 상대방의 **대리인**은 제3자가 아니다(상대방 본인이 선의·무과실이어도 취소 가능). 단순 **피용자**는 제3자에 해당한다.

- 사기 취소에 표의자의 **경제적 손해는 요건이 아니다**.
- 사기와 담보책임이 경합하면 **선택적**으로 행사 가능. 취소를 **하지 않고도** 불법행위 손해배상 청구 가능.
- 취소의 효과는 선의의 제3자에게 대항 불가(취소 후 말소등기 전에 이해관계를 맺은 선의의 제3자 포함).

의사표시의 효력발생 ★★

- **도달주의**: 상대방이 **요지할 수 있는 객관적 상태**에 놓이면 도달(실제로 읽을 필요 없음). 도달 **후에는 철회 불가**. 불착·연착의 불이익은 표의자 부담.
- 정당한 사유 없이 **수령을 거절**한 경우에도 요지할 수 있는 상태에 놓인 때 효력 발생.
- 발송 후 표의자가 **사망하거나 제한능력자가 되어도** 의사표시의 효력에 영향 없다.
- 수령자가 **제한능력자**이면 표의자는 도달을 주장할 수 없다(법정대리인이 안 후에는 가능). 제한능력자 측에서 효력발생을 주장하는 것은 가능.
- **공시송달**: 표의자가 **과실 없이** 상대방을 알지 못하거나 소재를 알지 못하는 경우에 가능.
- 등기우편·내용증명이 반송되지 않았으면 그 무렵 도달된 것으로 본다(보통우편은 추정 X).
- **발신주의 예외**(확답을 **"발하지"** 않으면): 무권대리 상대방의 최고 → **추인 거절**로 본다 / 제한능력자 상대방의 최고 → 추인(또는 취소)으로 본다 / 제3자를 위한 계약의 수익 여부 최고는 확답을 **"받지"** 못하면 거절.

기출·모의 지문 OX

1. 무권리자로부터 동산을 매수한 자의 선의취득과 점유취득시효에 의한 소유권 취득은 원시취득이다. → O
2. 합의해제는 상대방 있는 단독행위이다. → X (합의해제는 계약. 법정·약정·해약금 해제가 단독행위)
3. 소유권의 포기는 상대방 있는 단독행위이다. → X (상대방 없는 단독행위. 공유지분 포기·시효이익 포기가 상대방 있는 단독행위)
4. 무자격 중개업자가 체결한 중개수수료 약정도 법정한도를 초과하지 않은 부분은 효력이 있다. → X (전부 무효. 공인중개사의 초과약정은 초과부분만 무효)
5. 공공임대주택의 임대료 상한을 정하는 규정은 효력규정이므로 이에 위반한 약정은 효력이 없다. → O
6. 개업공인중개사가 의뢰인과 직접 거래하는 것을 금지하는 규정은 효력규정이다. → X (단속규정, 거래는 유효)
7. 조세포탈 목적의 중간생략등기는 형사처벌 대상이므로 사법상 효력이 없다. → X (단속규정 위반으로 유효)
8. 민사소송에서 승소하면 변호사에게 성공보수를 지급하기로 한 약정은 반사회적 법률행위이다. → X (형사사건 성공보수만 무효)
9. 도박채무 변제를 위해 도박채권자에게 부동산 처분 대리권을 수여한 행위는 반사회적 행위로 무효이다. → X (대리권 수여는 유효)
10. 강제집행을 면할 목적으로 허위의 근저당권설정등기를 한 행위는 반사회적 법률행위이다. → X (통정허위표시로 무효일 뿐)
11. 비자금을 소극적으로 은닉하기 위하여 임치한 것은 반사회적 행위로 무효이다. → X
12. 강박에 의해 증여계약이 체결된 경우 그 증여는 반사회적·불공정·비진의표시로서 무효이다. → X (취소하지 않는 한 유효. 증여는 제104조 적용도 없다)
13. 반사회적 법률행위의 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다. → X (절대적 무효, 대항 가능)
14. 제2매수인이 매도인의 배임행위에 적극 가담한 경우, 제1매수인은 제2매수인에게 직접 소유권이전등기를 청구할 수 있다. → X (매도인을 대위하여 말소청구만 가능)
15. 불공정한 법률행위에서 무경험은 어느 특정 영역의 경험 부족도 포함한다. → X (거래 일반의 경험 부족)
16. 불공정한 법률행위로 무효가 되면 쌍방은 이행한 급부의 반환을 청구할 수 있다. → X (피해자만 반환청구 가능)
17. 대출한도 초과 채무자를 위해 명의를 빌려준 제3자의 의사표시는 비진의표시이다. → X
18. 가장매매의 매매대금 채권을 가압류한 자는 허위표시의 제3자로 보호받을 수 없다. → X (제3자에 해당)
19. 증여를 매매로 가장한 경우, 수증자로부터 매수한 자는 선의인 경우에 한하여 소유권을 취득한다. → X (증여가 유효하므로 선·악 불문 취득)
20. 동기의 착오로 취소하려면 동기를 의사표시의 내용으로 삼기로 하는 합의가 있어야 한다. → X (표시로 족함)
21. 착오로 취소한 표의자는 상대방에게 손해배상책임을 진다. → X
22. 매도인의 담보책임이 성립하면 매수인은 착오를 이유로 취소할 수 없다. → X (선택 가능)
23. 교환계약에서 시가보다 높은 가액을 시가라고 고지한 것은 위법한 기망행위이다. → X
24. 기망행위자가 상대방의 대리인이고 상대방이 선의·무과실이면 표의자는 취소할 수 없다. → X (대리인은 제3자가 아니므로 항상 취소 가능)
25. 무권대리 상대방의 최고에 본인이 기간 내에 확답을 "받지" 못하면 추인을 거절한 것으로 본다. → X (본인이 확답을 "발하지" 아니한 때)
26. 표의자가 의사표시를 발송한 후 사망하면 그 의사표시는 효력이 없다. → X

제2장 대리 (민법총칙 ②)

대리 = 본인(甲)에게 대리권을 받은 대리인(乙)이 의사결정을 하여 상대방(丙)과 법률행위를 하고, 그 효과는 **직접 본인에게 귀속**되는 제도. 대리권이 있으면 **유권대리(유효)**, 없으면 **무권대리(유동적 무효)**이다. 매년 2~3문제가 출제된다.

대리권 - 범위·제한·소멸 ★★★

대리권의 범위

쟁점(강사 핵심요약)	결론
권한을 정하지 않은 임의대리인(제118조) - **보존행위**	**가능**(무제한): 미등기 부동산 보존등기, 기한 도래한 채무의 변제, 소멸시효 중단, 부패하기 쉬운 물건의 매각
〃 - **이용·개량행위**	물건·권리의 **성질을 변하지 않는 범위**에서 가능
〃 - **처분행위**	**불가능**(별도의 대리권 필요)
매매계약 체결의 포괄적 대리권을 받은 매도대리인 - **중도금·잔금 수령**	**가능**
〃 - **대금 지급기일 연기**	**가능**
〃 - **매매대금 채무 면제**(일부 면제 포함)	**불가능**
〃 - **매매계약의 해제·취소**	**불가능**(본인 명의로 체결된 계약을 취소하려면 별도 수권 필요)

대리인이 수령한 대금을 본인에게 전달하지 않았더라도 계약이 해제되면 **원상회복의무는 본인**이 부담한다(상대방은 대리인이 아니라 본인에게 청구).

대리권의 제한

쟁점	결론
자기계약·쌍방대리	원칙 **금지**(위반 시 무권대리)
본인이 **허락**한 경우	**가능**
다툼 없는 채무의 이행	**가능**
등기신청의 쌍방대리	**유효**(채무의 이행에 불과)
경매 입찰에서 이해관계가 다른 2인 이상을 대리한 입찰	**무효**
대리인이 수인인 경우	**각자대리** 원칙

대리권의 소멸사유

구분	소멸사유
공통(임의·법정) - **본인**	**사망**만 (본인의 성년후견개시·파산은 소멸사유 아님)
공통(임의·법정) - **대리인**	**사망, 성년후견의 개시, 파산** (한정후견 개시는 소멸사유 아님)
임의대리 특유	**원인된 법률관계의 종료, 수권행위의 철회**

두문자·암기법

본인은 "사", 대리인은 "사·성·파". 대리인은 **행위능력자임을 요하지 않는다**(제117조) → 미성년자도 대리인이 될 수 있고, 본인은 대리인의 제한능력을 이유로 대리행위를 취소할 수 없다. 그러나 대리인이 된 후에 성년후견이 개시되면 대리권은 소멸한다.

대리행위 - 현명주의와 하자 ★★★

쟁점(강사 핵심요약)	결론
현명한 경우	**본인**에게 직접 효과 귀속
현명하지 않은 경우	**대리인 자신을 위한 것으로 "본다"(간주)**. 단, 상대방이 대리인으로서 한 것임을 알았거나 알 수 있었으면 대리 효과 발생
현명하지 않아 자기 행위로 간주된 대리인의 착오 취소	**불가능**
현명 없이 대리인 자신을 당사자로 한 계약의 표현대리	성립 **불가능**
묵시적 현명	**인정**: 대리인이 **본인 명의(이름)를 사용**하거나 **위임장을 제시**하고 계약한 경우도 유효한 대리행위
대리행위의 하자(의사의 흠결, 사기·강박, 선의·악의·과실)	원칙 **대리인**을 표준으로 결정(제116조). 단, 본인의 지시에 따른 경우 본인은 자기가 안 사정에 관해 대리인의 부지를 주장 못함

사기·강박 사례 정리 (본인 甲, 대리인 乙, 상대방 丙)

상황	취소권
상대방 丙이 **본인 甲**을 기망	甲 취소권 **X**(의사결정은 대리인이 하므로)
상대방 丙이 **대리인 乙**을 기망·강박	취소권 **O**, 다만 취소권은 **본인 甲**에게 귀속(乙은 별도 수권 없이는 취소 불가)
본인 甲이 상대방 丙을 기망	丙 취소권 **O**
대리인 乙이 상대방 丙을 기망	丙 취소권 **O**(대리인은 제3자가 아니므로 甲이 선의·무과실이어도 취소 가능)

- 대리인이 상대방의 **이중매매 배임행위에 적극 가담**하였다면 본인이 그 사실을 몰랐어도 계약은 반사회적 행위로 **무효**.
- **대리권 남용**: 대리인이 자기·제3자의 이익을 위해 대리행위 → 원칙 유효한 대리. 상대방이 그 사정을 알았거나 알 수 있었으면 **무효** (제107조 1항 단서 유추). 다만 선의의 전득자에게는 무효를 주장하지 못한다. 법정대리에도 적용된다.

복대리 ★★

쟁점(강사 핵심요약)	결론
복대리인의 지위	대리인이 **자기 이름으로** 선임한 **본인의 대리인**
복대리인 선임행위가 대리행위인지	**대리행위 아님**
복대리인의 성질	법정대리인이 선임해도 항상 **임의대리인**
복대리인의 현명	**본인 이름**으로 현명. 하자 유무는 **복대리인** 기준
선임 후 대리인의 대리권	**유지**(소멸하지 않음)
대리인의 대리권이 소멸(사망·파산 등)하면	복대리권도 **소멸**

구분	복임권	책임
법정대리인	언제나 **자유롭게** 선임	원칙: 선임·감독에 과실 없어도 **무과실 책임** / **부득이한 사유**로 선임한 때: **선임·감독상 책임**으로 감경
임의대리인	원칙 없음. **본인의 승낙 또는 부득이한 사유**가 있는 경우에만 선임	원칙: **선임·감독상 책임** / **본인의 지명**으로 선임한 때: 부적임·불성실함을 알고 통지·해임을 태만히 한 때에만 책임(감경)

협의의 무권대리 ★★★

권리	요건·내용(강사 핵심요약 정답)
본인의 추인권	· 행사 시기: **상대방이 철회하기 전**까지 · 추인의 상대방: **상대방, 승계인, 무권대리인** 모두 가능(무권대리인에게 한 추인은 상대방이 알기 전에는 상대방에게 대항 못함 → 선의의 상대방은 여전히 철회 가능) · 묵시적 추인: **대금 수령은 가능**, 알면서 **장기간 방치한 것만으로는 불가능** · 일부추인·변경추인: 상대방 **동의 없으면 무효** · 효과: **계약 시로 소급**하여 유효(제3자의 권리는 해하지 못함). **무권리자의 처분행위 추인도 소급효 인정**
본인의 추인거절권	확정적 무효. 무권대리인이 본인을 **단독상속**한 경우 추인거절·등기말소 청구는 신의칙상 **불가**
상대방의 철회권	**선의**의 상대방만 / **본인의 추인이 있기 전**까지 / **본인 또는 무권대리인**에게 / 상대방의 선의는 **추정** → 철회를 저지하려는 본인이 상대방의 **악의를 입증**
상대방의 최고권	**악의**의 상대방도 가능 / **본인**에게만 / 상당한 기간 내 확답을 **"발하지"** 않으면 **추인 거절**로 본다
무권대리인의 책임 (제135조)	· 요건: 대리권 증명 X + 본인 추인 X + 상대방 **선의·무과실** + 무권대리인이 **행위능력자** · 내용: **상대방의 선택**에 따라 **계약의 이행 또는 손해배상**(이행이익) · 성질: **무과실 책임** - 무권대리인에게 고의·과실이 없어도, 제3자의 기망·위조로 무권대리를 하게 된 경우에도 책임

표현대리 ★★★

표현대리는 성질상 **무권대리**이다. 외관을 신뢰한 선의·무과실의 상대방 보호를 위해 본인에게 책임을 지운다.

쟁점(강사 핵심요약)	결론
강행규정 위반 행위에 표현대리	**불가능**
현명하지 않은 행위에 표현대리	**불가능**
법정대리에 적용 - 제125조(대리권 수여표시)	X
법정대리에 적용 - 제126조(권한을 넘은)	O
법정대리에 적용 - 제129조(대리권 소멸 후)	O
유권대리 주장 속에 표현대리 주장이 포함되는지	X(따로 주장해야 함)
표현대리가 성립한 경우 과실상계로 본인 책임 감경	X
표현대리를 주장할 수 있는 자	**상대방만**(본인·무권대리인·전득자는 주장 불가)
표현대리가 성립하는 경우 본인의 추인 / 상대방의 철회	모두 **가능**
정당한 이유(선의·무과실)의 판단 시점	**대리행위 당시**(판결 시 X)

권한을 넘은 표현대리(제126조)의 기본대리권

쟁점	결론
기본대리권과 월권행위의 동종·유사성	**불필요**
공법상 행위의 대리권, 등기신청 대리권	**인정**
복대리인의 대리권, 이미 **소멸한 대리권**(제129조와 중첩)	**인정**. 대리권 소멸 후 선임된 복대리인의 행위에도 표현대리 성립 가능
부부의 일상가사대리권, **사자(使者)**의 권한	**인정**
정당한 이유의 입증책임(강사 모의고사 정답 기준)	표현대리를 주장하는 **상대방**

대리인이 본인인 것처럼 행세하거나, 저당권설정 대리인이 자기 앞으로 이전등기 후 자기 이름으로 매도	대리행위의 외관이 없으므로 표현대리 **불성립**

함정 주의

- 철회권은 **선의**만, 최고권은 **악의도**. 철회는 본인·무권대리인 누구에게나, 최고는 **본인에게만**.
- 무권대리인의 책임은 "무권대리인의 선택"이 아니라 **"상대방의 선택"**.
- 상대방이 대리권 없음을 **알 수 있었다면(과실)** 무권대리인에게 제135조 책임을 물을 수 없다.
- 임의대리인 甲의 대리권은 **대리인 甲 자신의 파산**으로 소멸하지만 **본인 乙의 파산·성년후견개시**로는 소멸하지 않는다.

기출·모의 지문 OX

1. 매매계약 체결의 포괄적 대리권을 받은 대리인은 중도금·잔금을 수령하고 지급기일을 연기해 줄 권한도 있다. → O
2. 대리인이 대금을 수령하여 본인에게 전달하지 않은 상태에서 계약이 해제되면 상대방은 대리인에게 원상회복을 청구하여야 한다. → X (본인에게 청구)
3. 매도인의 대리인이 자신을 매수인으로 하여 본인의 부동산을 매수하는 것도 원칙적으로 허용된다. → X (자기계약은 원칙 금지)
4. 대리인이 매매 당사자 쌍방을 대리하여 등기를 신청하는 것은 허용된다. → O
5. 대리인이 대리인임을 밝히지 않고 본인의 이름을 사용하여 계약을 체결하더라도 유효한 대리행위가 될 수 있다. → O
6. 대리인이 현명하지 않고 자신을 당사자로 하여 체결한 계약에도 표현대리가 성립할 수 있다. → X
7. 대리인이 상대방으로부터 강박을 당한 경우 대리인은 본인의 의사와 관계없이 계약을 취소할 수 있다. → X (취소권은 본인에게 귀속)
8. 대리인이 상대방의 이중매매에 적극 가담했어도 본인이 몰랐다면 계약은 무효가 아니다. → X (대리인 기준으로 판단하여 무효)
9. 법정대리인은 본인의 승낙이나 부득이한 사유가 없으면 복대리인을 선임하지 못한다. → X (임의대리인에 관한 설명)
10. 복대리인의 대리행위에 하자가 있는지는 원칙적으로 그를 선임한 대리인을 기준으로 판단한다. → X (복대리인 기준)
11. 대리인이 파산선고를 받으면 복대리인의 대리권도 소멸한다. → O
12. 본인이 무권대리행위를 알면서 장기간 방치하였다면 묵시적 추인이 있는 것으로 본다. → X
13. 본인이 무권대리인에게 추인한 후에는 그 사실을 모르는 상대방도 철회할 수 없다. → X (상대방이 추인 사실을 알기 전에는 철회 가능)
14. 계약 당시 대리권 없음을 알았던 상대방도 본인에게 추인 여부를 최고할 수 있다. → O
15. 본인이 상대방의 철회를 저지하려면 상대방의 악의를 증명하여야 한다. → O
16. 무권대리인의 상대방에 대한 책임은 무권대리인에게 고의나 과실이 있는 경우에 한하여 인정된다. → X (무과실 책임)
17. 추인을 얻지 못한 무권대리인은 계약의 이행과 손해배상 중 자신이 선택한 책임을 진다. → X (상대방의 선택)
18. 본인이나 전득자도 표현대리를 주장할 수 있다. → X (상대방만)
19. 법정대리인의 행위에도 대리권 수여표시에 의한 표현대리가 성립할 수 있다. → X (제125조는 임의대리에만 적용. 제126조·제129조는 법정대리에도 적용)
20. 대리권 소멸 후 선임된 복대리인의 권한은 권한을 넘은 표현대리의 기본대리권이 될 수 없다. → X
21. 토지거래허가를 받지 않아 무효인 계약도 표현대리에 의하여 유효가 될 수 있다. → X

제3장 무효와 취소, 조건과 기한 (민법총칙 ③)

무효와 취소의 비교 ★★

구분	무효	취소
주장권자	누구나	**취소권자만**(제한능력자, 착오·사기·강박으로 의사표시한 자, 그의 **대리인·승계인**)
효력	처음부터 당연 무효	취소 전에는 유효 → 취소하면 **처음부터(소급하여)** 무효
기간 제한	없음(방치해도 유효로 안 됨)	**추인할 수 있는 날부터 3년, 법률행위를 한 날부터 10년**(제척기간)
추인	무효임을 알고 추인 → **새로운 법률행위**(소급효 X)	추인하면 확정적 유효(취소권 포기)
대표 사유	의사무능력, 원시적 불능, 강행규정 위반, 제103조·제104조, 비진의표시 단서, 통정허위표시	제한능력, 착오, 사기·강박

무효인 법률행위를 이행하지 않았다고 해서 채무불이행 손해배상책임이 생기지 않는다(무효인 계약에서는 이행의무 자체가 없다).

법률행위의 무효 ★★★

쟁점(강사 핵심요약)	결론
일부무효(제137조) 원칙	**전부 무효**. 단, 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정되면 나머지는 유효
제137조의 성질	**임의규정**(당사자 약정·개별 강행법규가 우선)
일부취소	**가능**(가분적이고, 나머지 부분을 유지하려는 가정적 의사가 인정되면)
무효행위의 전환(제138조)	무효인 행위가 **다른 법률행위**의 요건을 구비하고, 무효를 알았더라면 다른 법률행위를 의욕했으리라 인정될 때 그 다른 행위로서 효력
불공정한 법률행위의 전환	**가능**(추인은 불가)
무효행위의 추인(제139조)	당사자가 무효임을 **알고** 추인하면 **새로운 법률행위**로 본다 → **소급효 부정**(추인한 때부터 유효)
절대적 무효(강행규정 위반, 반사회적·불공정 행위)의 추인	**불가능**(무효 원인이 해소되지 않는 한)
통정허위표시의 추인	가능. 단, 새로운 법률행위로서 **추인한 때부터** 유효
취소한 후의 추인	취소로 무효가 된 법률행위도 **무효행위의 추인**으로 다시 유효하게 할 수 **있다**(취소원인이 소멸한 후여야 함)
소급효가 인정되는 추인	**무권대리 추인, 무권리자 처분행위의 추인** → 소급효 **인정**

토지거래허가구역 내 토지매매 - 유동적 무효 ★★★

허가를 받을 것을 전제로 체결한 계약은 허가 전까지 **유동적 무효**(허가 받으면 소급 유효, 불허가 확정 등이면 확정적 무효).

유동적 무효 중의 법률관계(강사 핵심요약)	결론
허가신청절차 **협력의무**의 이행청구·소구	**가능**
소유권 **등기이전의무·대금지급의무**의 이행청구	**불가능**(아직 채권·채무 없음)
협력의무 위반으로 인한 손해배상청구(손해배상액 예정도 유효)	**가능**
대금지급의무 불이행으로 인한 손해배상청구	**불가능**

허가신청 협력청구권 보전을 위한 가처분	**가능**
소유권이전등기청구권 보전을 위한 가처분	**불가능**
이미 지급한 계약금의 부당이득반환청구	**불가능**(확정적 무효가 되어야 가능)
대금 제공이 없음을 이유로 협력의무 이행 거절(동시이행 항변)	**불가능**(협력의무와 대금지급의무는 동시이행관계 아님)

유동적 무효 중의 해제·취소	**결론**
매매계약상 채무불이행(대금 미지급 등)을 이유로 한 해제	**불가능**
협력의무 위반을 이유로 한 매매계약 해제	**불가능**
계약금(해약금)에 의한 해제	**가능**(허가를 받은 후에도 이행착수 전이면 가능)
착오, 사기·강박을 이유로 한 취소(→ 협력의무를 면함)	**가능**

핵심 암기 - 확정적 무효·확정적 유효

- **확정적 무효**: 처음부터 허가를 **배제·잠탈**하는 내용의 계약(이후 구역 지정이 해제되어도 무효), 불허가 처분 확정, **쌍방이** 협력의무 이행거절 의사를 명백히 표시, 정지조건이 허가 전에 불성취로 확정, 타인 명의를 도용해 받은 허가.
- **확정적 유효**: 허가를 받은 경우, (잠탈 목적 없는 계약에서) 허가구역 **지정이 해제**되거나 기간 만료 후 재지정이 없는 경우.
- 확정적 무효에 귀책사유 있는 자도 무효를 주장할 수 있다.

법률행위의 취소 ★★★

쟁점(강사 핵심요약)	**결론**
취소권자	제한능력자(법정대리인 동의 없이 **단독으로** 취소 가능), 착오·사기·강박으로 의사표시한 자, 그 **대리인**, **승계인**(상속인 등)
취소의 상대방	법률행위의 **직접 상대방**(전득자에게 하는 것이 아님)
취소의 방법	특별한 방식 없음. 취소를 전제로 한 부당이득반환·말소등기 청구 소송에 취소 의사 포함 가능
취소의 효과	**소급효 인정**. 부당이득 반환
제한능력자의 반환범위	선의·악의 불문 **현존이익 한도**에서 반환
추인의 요건	**취소원인이 종료된 후**에, 취소할 수 있음을 알고 해야 함. **법정대리인(후견인)**은 취소원인 종료 **전에도** 추인 가능
취소 자체의 시기	취소원인 종료 **전에도** 취소는 가능(제한능력 상태·강박 상태에서 한 취소도 유효)
취소권 행사기간	**제척기간**. 추인할 수 있는 날부터 **3년**, 법률행위를 한 날부터 **10년** 중 먼저 도래하는 때. 법원의 **직권조사** 사항

법정추인(제145조)

취소원인 종료 후, 이의를 보류하지 않고 다음 행위를 하면 추인한 것으로 본다.

사유	**취소권자가 한 경우**	**상대방이 한 경우**
전부·일부의 **이행**	O	O(취소권자가 수령)
이행의 청구	O	X
경개(대물변제 약정 등 채무 내용 변경)	O	O
담보의 제공	O	O(취소권자가 제공받음)
취득한 **권리의 양도**(제한물권 설정 포함)	O	X
강제집행	O	O

함정 주의

"이행의 청구"와 "권리의 양도"는 **취소권자가 한 경우에만** 법정추인이 된다. 취소권자가 상대방으로부터 이행청구를 받은 것, 상대방이 자기 채권을 제3자에게 양도한 것은 법정추인 사유가 아니다. 기망에서 벗어난 매수인이 매수한 부동산에 제3자 앞으로 저당권·지상권을 설정해 주면 법정추인(권리의 양도)에 해당하여 취소권을 잃는다.

조건 ★★★

조건 = 발생이 **불확실**한 장래 사실(합격, 결혼). **정지조건**은 성취 시 효력 **발생**, **해제조건**은 성취 시 효력 **소멸**.

가장조건(제151조)

구분	정지조건이면	해제조건이면
불법조건(선량한 풍속 기타 사회질서 위반)	**법률행위 전체가 무효**(조건만 무효가 되는 것이 아님)	
기성조건(이미 성취된 사실)	**조건 없는 법률행위**	**무효**
불능조건(성취 불가능)	**무효**	**조건 없는 법률행위**

두문자·암기법

"**기·정·없, 불·해·없**" - 기성조건이 정지조건이면 조건 없는 법률행위, 불능조건이 해제조건이면 조건 없는 법률행위. 나머지 두 칸은 무효.

기타 쟁점(강사 핵심요약)	결론
조건부·기한부 권리의 처분·상속·보존·담보제공	**가능**(조건 성취가 미정인 동안에도)
조건 성취의 효력	원칙적으로 **소급효 부정**(성취한 때부터 효력 발생·소멸)
조건 성취의 효력을 소급시키는 특약	**가능**(제147조 3항)
조건을 붙일 수 없는 법률행위에 조건을 붙인 경우	**법률행위 전부 무효**(조건만 무효 X)
조건을 붙일 수 없는 행위	혼인·입양 등 신분행위, 단독행위(**취소**·해제·상계·추인 등). 단 **채무면제·유언(유증)**은 조건 가능
조건 존재의 입증책임	조건의 존재를 **주장하는 자**가 증명. (정지조건 성취 사실은 권리를 주장하는 자가 증명)
조건 성취의 방해(제150조)	불이익을 받을 자가 신의성실에 반하여 방해(**고의뿐 아니라 과실 포함**) → 상대방은 조건이 성취된 것으로 **주장할 수 있다**. 의제 시점 = 방해가 없었더라면 성취되었으리라고 **추산되는 시점**

기한 ★★

- **기한** = 발생이 **확실**한 장래 사실. 시점이 정해지면 확정기한(날짜), 아니면 불확정기한(사망). "기르던 개가 죽으면 증여한다" = **불확정기한**부(정지조건 아님).
- "타인에게 임대가 되면 보증금을 반환한다" = 불확정기한. 불확정한 사실의 **발생이 불가능한 것으로 확정된 때에도 기한이 도래**한 것으로 본다.
- 시기 있는 법률행위는 기한 도래 시부터 효력 발생, 종기 있는 법률행위는 기한 도래 시부터 효력 상실. 기한 도래의 효과는 **항상 장래효** - 소급효 없음, **특약으로도 소급 불가**.
- 기한의 이익은 **채무자**를 위한 것으로 **추정**(간주 X). 포기할 수 있으나 상대방의 이익을 해하지 못한다(채권자에게도 이익이 있으면 손해를 배상하고 포기).
- **기한이익 상실사유**: 채무자가 담보를 손상·감소·멸실하게 한 때, 담보제공 의무를 이행하지 않은 때, 파산.
- 기한이익 상실특약은 특별한 사정이 없으면 **형성권적** 기한이익 상실특약으로 **추정**(정지조건부 X) → 채권자의 의사표시가 있어야 이행기 도래.

기출·모의 지문 OX

1. 법률행위의 일부분에만 취소사유가 있는 경우 일부만을 취소하는 것은 허용되지 않는다. → X (가분적이면 일부취소 가능)
2. 일부무효에 관한 민법 제137조는 임의규정이다. → O
3. 반사회적 법률행위도 당사자가 무효임을 알고 추인하면 새로운 법률행위로 본다. → X (절대적 무효는 추인 불가)
4. 통정허위표시를 무효임을 알고 추인하면 처음부터 효력이 있었던 것으로 본다. → X (추인한 때부터)
5. 무권리자의 처분행위를 권리자가 추인하면 소급하여 유효한 처분행위가 될 수 있다. → O
6. 취소로 무효가 된 법률행위는 추인에 의하여 유효한 법률행위가 될 수 없다. → X (무효행위의 추인으로 가능)
7. 유동적 무효 상태에서 매도인은 매수인의 대금 이행제공이 없음을 이유로 허가신청 협력의무의 이행을 거절할 수 없다. → O
8. 유동적 무효 상태에서 상대방이 협력의무를 이행하지 않으면 이를 이유로 계약을 해제할 수 있다. → X (손해배상은 가능, 해제는 불가)
9. 유동적 무효 상태에서 매수인은 지급한 계약금의 반환을 청구할 수 있다. → X
10. 허가제를 잠탈할 목적으로 체결한 계약도 이후 허가구역 지정이 해제되면 확정적으로 유효가 된다. → X (처음부터 확정적 무효)
11. 강박에 의한 매도인은 매수인으로부터 토지를 전득한 자를 상대로 취소권을 행사할 수 있다. → X (취소의 상대방은 계약의 직접 상대방)
12. 취소의 원인이 종료하기 전에 한 취소도 효력이 있다. → O (추인은 종료 후에만 가능)
13. 미성년자는 법정대리인의 동의 없이 단독으로 취소권을 행사하지 못한다. → X
14. 취소권은 법률행위를 한 날로부터 3년 내에 행사하여야 한다. → X (추인할 수 있는 날부터 3년, 법률행위를 한 날부터 10년)
15. 취소권자가 상대방으로부터 이행의 청구를 받은 것은 법정추인 사유이다. → X (취소권자가 청구한 경우만)
16. 해제조건이 선량한 풍속에 위반한 때에는 그 조건만 무효로 된다. → X (법률행위 전체 무효)
17. 기성조건이 정지조건이면 그 법률행위는 무효이다. → X (조건 없는 법률행위)
18. 과실로 조건의 성취를 방해한 경우에는 상대방이 조건의 성취를 주장할 수 없다. → X (과실에 의한 방해도 포함)
19. 기한이익 상실특약은 특별한 사정이 없는 한 정지조건부 기한이익 상실특약으로 추정한다. → X (형성권적 상실특약으로 추정)
20. 당사자가 조건 성취의 효력을 성취 전으로 소급하게 할 의사를 표시한 경우 그 의사표시는 무효이다. → X (조건은 소급 특약 가능, 기한은 불가)

제4장 물권법 총론 - 물권의 효력과 물권변동

물권법은 **14문제**로 비중이 가장 크다. 총론(물권 일반·물권적 청구권·등기)에서 3~4문제가 나온다.

물권의 종류와 객체 ★★

민법상 물권	내용
점유권	사실상 지배
본권 - 소유권	사용·수익·처분
본권 - 제한물권 - 용익물권	지상권, 지역권, 전세권
본권 - 제한물권 - 담보물권	유치권, 질권, 저당권 (특별법: 가등기담보권)

쟁점(강사 핵심요약)	결론
물권법정주의: 물권을 창설할 수 있는 근거	**법률, 관습법**만 가능(대통령령·당사자 합의로는 불가)
관습법상 물권 O	**관습법상 법정지상권, 분묘기지권, 동산 양도담보권**
관습법상 물권 X	**온천권, 사도통행권, 근린공원이용권, 미등기 매수인의 '사실상 소유권'**
사용·수익 권능을 대세적·영구적으로 포기한 소유권	**불가능**
사용·수익 권능을 영구적으로 배제한 전세권	**불가능**
기존 건물의 사용을 목적으로 한 지상권에 최단존속기간 적용	X
일물일권주의: 토지의 일부에 지상권·지역권(승역지)·전세권	**가능**
토지의 일부에 소유권·저당권	**불가능**(분필해야 함)
건물의 일부에 구분소유권(구조상·이용상 독립성 필요)·전세권	**가능**
명인방법을 갖춘 수목	**소유권**의 객체만 가능(저당권 X)
입목등기를 한 수목(입목)	**소유권과 저당권**의 객체
타인 토지에 경작한 **농작물**	권한 **없는** 자가 경작했어도, 명인방법 없이도 성숙하면 **경작자 소유**
증감 변동하는 집합물(양어장의 뱀장어, 돈사의 돼지 등)에 하나의 양도담보권	**가능**

부동산 = 토지 및 그 정착물(제99조). 토지는 1필지, 건물은 1동(기둥·지붕·주벽)이 기준. 수목·농작물은 원칙적으로 토지의 일부.

물권적 청구권 ★★★

권리	반환청구	방해제거청구	방해예방청구
점유권, 소유권, 지상권, 전세권	O	O	O
지역권, 저당권(점유를 수반하지 않음)	X	O	O
유치권	유치권에 기한 물권적 청구권 규정 **없음** → 점유를 침탈당하면 **점유권에 기한** 반환청구만 가능		

쟁점(강사 핵심요약)	결론
물권과 물권적 청구권의 분리 양도	**불가능**
소유권에 기한 물권적 청구권의 시효소멸	**불가능**(소멸시효에 걸리지 않음)

침해자(상대방)의 고의·과실	**불필요**(손해배상청구에는 필요)
소유권을 **상실한** 전 소유자의 물권적 청구권	**불가능**(소유권을 이전하면서 청구권만 유보할 수 없음)
매도인이 **미등기 매수인**(점유 중) 또는 그로부터 다시 매수한 자에게 반환청구	**불가능**
매도인(등기 명의 보유)이 제3자인 불법점유자에게 청구	**가능**(아직 소유자)
대항력 있는 임차인의 방해배제 등 물권적 청구	**가능**(대항력 없으면 불가)
상대방: **간접점유자**	**가능**
상대방: **점유보조자**	**불가능**
상대방: 점유를 침탈했으나 **현재 점유하고 있지 않은 자**	**불가능**(현재 점유자가 상대방)

토지 소유자 甲 v. 무단 건축된 건물

상대방	甲이 청구할 수 있는 것
건물 **소유자**(무단 신축자)	**건물 철거 + 토지 인도** + 부당이득반환. **건물에서의 퇴거는 청구 불가**
건물을 **미등기로 매수**하여 점유하는 자	**철거 청구 가능**(법률상·사실상 처분권자)
건물 **임차인**(대항력 있어도)	**퇴거** 청구 가능(철거는 건물 소유자에게)
건물 공유자 중 일부에 대해서만 철거판결	전원에 대한 판결이 없으면 철거 **집행 불가**

부동산 물권변동과 등기 ★★★

핵심 암기 - 제186조·제187조

법률행위로 인한 부동산 물권변동 → **등기해야** 효력 발생(제186조). **상속, 공용징수, 판결, 경매 기타 법률의 규정**에 의한 취득 → **등기 불필요**, 단 **등기하지 않으면 처분하지 못한다**(제187조).

물권변동 사유(강사 핵심요약)	등기
매매·교환·증여·설정계약 등 법률행위	**필요**
공유지분 포기로 다른 공유자에게 지분이 귀속되는 효과	**필요**
공유물분할 **협의**(소송 중 조정 성립 포함)	**필요**
공유물분할 **판결**(형성판결)	**불필요**
상속, 포괄유증, 합병	**불필요**
공경매(경락대금 완납 시 취득), 공용징수(수용)	**불필요**
이전등기를 명하는 판결(이행판결)	**필요**(판결 확정만으로는 취득 X)
건물 신축, 건물 멸실, 구분소유권의 성립	**불필요**
용익물권의 존속기간 만료, 피담보채권 소멸에 의한 담보물권 소멸, 혼동	**불필요**
법정지상권·관습법상 법정지상권·분묘기지권의 **최초 취득**	**불필요**
점유취득시효 완성에 의한 소유권 취득(법률규정인데도 예외)	**필요**
매매계약의 **해제·취소**로 인한 소유권 복귀	**불필요**(말소등기 없이 당연 복귀)

등기 제도가 없는 물권: **점유권, 유치권, 분묘기지권**(점유·분묘 자체가 공시방법).

중간생략등기와 미등기 전매 (甲 → 乙 → 丙)

쟁점(강사 핵심요약)	결론

이미 경료된 중간생략등기의 효력	원칙 **유효**(실체관계에 부합) - 전원 합의 **불필요**
예외	**토지거래허가구역** 내 토지: 甲·丙을 당사자로 허가받아 직접 이전한 등기는 **무효**
丙이 甲에게 **직접** 이전등기 청구	**전원(甲·乙·丙)의 합의 필요**
丙이 乙을 **대위**하여 甲에게 청구(乙 앞으로 등기)	합의 **불필요**
전원 합의가 있은 후 乙의 甲에 대한 등기청구권	**소멸하지 않는다**
합의 후 甲·乙이 대금을 인상한 경우 / 甲이 乙에게서 대금을 못 받은 경우	甲은 丙의 등기청구를 **거절 가능**(동시이행 항변)
매수인 乙의 등기청구권 **양도**	매도인 甲의 **동의(승낙) 필요** - 통지만으로는 부족
점유취득시효 완성자의 등기청구권 양도	소유자의 동의 **불필요**(통상의 채권양도 방법)
甲이 미등기 매수인 丙(점유 중)에게 소유물반환청구	**불가능**

등기청구권의 성질과 소멸시효

등기청구권(강사 핵심요약)	성질
매수인의 매도인에 대한 이전등기청구권	**채권적**
점유취득시효 완성자의 등기청구권	**채권적**
가등기에 기한 본등기청구권	채권적(시효로 소멸 가능)
소유권을 상실한 저당권설정자의 (계약상) 말소등기청구권	**채권적** - 소유권 상실 후에도 청구 **가능**
현재 소유자의 원인무효 등기(무효 저당권 등) 말소청구권	**물권적**
매매계약이 해제(합의해제 포함)·취소된 경우 매도인의 말소등기청구권	**물권적**
변제를 완료한 양도담보설정자의 말소등기청구권	**물권적**
(유효한 명의신탁에서) 해지한 명의신탁자의 수탁자에 대한 등기청구권	**물권적**
진정명의회복을 원인으로 한 이전등기청구권	**물권적**

- 물권적 등기청구권 → 소멸시효 **적용 X**. 채권적 등기청구권 → **10년** 소멸시효 적용 O.
- 단, **매수인이 목적물을 인도받아 점유·사용**하는 동안에는 등기청구권의 소멸시효가 **진행하지 않는다**. 매수인이 제3자에게 전매하여 **점유를 승계**해 준 경우에도 **진행하지 않는다**.
- 매수인이 점유를 하지 않는(상실한) 경우 → **그때부터 소멸시효 진행**(즉시 소멸 아님). 점유취득시효 완성자가 점유를 상실한 경우도 같다.

등기의 효력 ★★★

실체관계 부합·유효 여부(강사 핵심요약)	결론
무효등기의 유용(저당권 등)	등기상 **이해관계 있는 제3자(후순위 저당권자 등)가 없는** 경우에만 가능
멸실된 건물의 보존등기를 신축건물의 등기로 유용	**불가능**
건물 완성 전에 한 소유권보존등기	나중에 등기와 일치하는 건물이 완성되면 **유효**
존속기간 개시 전에 한 전세권설정등기	**유효**
미등기 건물 매수인 명의로 직접 한 소유권보존등기	**유효**
말소등기 대신 진정명의회복을 원인으로 한 이전등기 청구	**가능**

등기가 원인 없이(불법) 말소된 경우	물권은 소멸하지 않음. 말소된 등기의 **최종 명의인은 회복등기 전에도 적법한 권리자로 추정**
저당권등기가 불법 말소된 후 경매로 매각대금이 완납된 경우	저당권은 경매로 소멸 → **회복등기 청구 불가**(배당받은 자에게 부당이득반환청구)

등기의 추정력

쟁점	결론
추정의 범위	권리의 존재·귀속, 등기원인, 절차의 적법, 대리권의 존재(대리권 없음을 주장하는 자가 입증). 등기명의인에게 **불이익한 경우에도** 인정
추정력 주장의 상대방	**제3자**에게도, **전(前) 소유자**에게도 주장 **가능**(이전등기)
소유권보존등기	신축자(원시취득자)가 따로 있음이 밝혀지면 깨진다. 명의인이 "양수했다"고 주장하고 전 소유자가 양도를 부인하면 추정력 **인정 안 됨**
등기명의인이 주장하는 등기원인이 인정되지 않은 경우	그것만으로 추정력이 **깨지지 않는다(유지)**
사망자 명의의 신청(전 명의인 사망 후 경료된 이전등기)	원칙 추정력 **부정**(현 명의인이 적법 원인을 증명). 단 **사망 전에 등기원인이 이미 존재**한 경우 등은 인정. 특별조치법에 의한 등기는 추정력 유지
사망자·허무인 명의의 보존등기	추정력 부정
근저당권설정등기	근저당권의 존재는 추정되나, **피담보채권을 성립시키는 기본계약의 존재는 추정되지 않는다** (주장하는 자가 입증)
표제부 기재사항, **가등기**	추정력 **없음**
점유의 권리적법 추정(제200조)	**동산**에만 적용. 등기된 부동산에는 적용 X

가등기 (甲 소유 토지에 乙 가등기 → 丙에게 소유권이전 → 乙 본등기)

시점	쟁점	결론
본등기 전	등기원인의 추정력	**부정**
	가등기권자의 물권적 청구권(말소청구 등)	**부정**(丙 등기가 원인무효여도 乙은 말소청구 불가)
	가등기상 권리의 양도	**가능**(부기등기)
본등기 후	순위 비교 기준	**가등기** 시(순위보전효) → 丙 등기는 직권말소
	물권변동(소유권 취득) 시기	**본등기** 시(소급 X) → 가등기 후 본등기 전 丙이 취득한 과실은 반환청구 불가
	본등기 청구의 상대방	**가등기 당시의 소유자 甲**(현재 명의인 丙이 아님)

물권의 소멸 - 혼동 등 ★★

사례(강사 핵심요약)	결론
지상권자가 토지 소유권 취득	지상권 소멸 **O**
저당권의 목적인 지상권의 지상권자가 토지 소유권 취득	지상권 소멸 **X**(제3자의 권리 목적)
점유권 + 소유권	점유권 소멸 **X**(혼동 적용 없음)
① 甲 저당권 ② 乙 저당권 → **甲**이 소유권 취득	甲 저당권 소멸 **X**(후순위가 있어 존속 실익)
① 甲 저당권 ② 乙 저당권 → **乙**이 소유권 취득	乙 저당권 소멸 **O**
① 甲 임차권(대항력) ② 乙 저당권 → 甲이 **매매 등으로** 소유권 취득	임차권 소멸 **X**

① 甲 임차권(대항력) ② 乙 저당권 → 甲이 **경매로** 소유권 취득	임차권 소멸 O(저당권이 경매로 소멸하므로 존속 실익 없음)
가등기권리자가 본등기에 의하지 않고 별도 원인으로 이전등기	본등기청구권 혼동 소멸 X
혼동의 원인(소유권 취득)이 무효·취소된 경우	소멸했던 물권은 **부활**

- 목적물 멸실 → 말소등기 없이 물권 소멸. 포락된 토지가 다시 성토되어도 종전 소유권은 부활하지 않는다.
- 소유권·점유권·저당권(단독으로)은 소멸시효에 걸리지 않는다. **지상권·지역권·전세권은 20년** 불행사로 시효소멸 가능.

기출·모의 지문 OX

1. 1필 토지의 일부에 저당권을 설정할 수 있다. → X (지상권·지역권·전세권은 가능, 저당권·소유권은 불가)
2. 명인방법을 갖춘 수목은 토지와 분리하여 소유권과 저당권의 객체가 될 수 있다. → X (소유권만. 저당권은 입목등기한 입목)
3. 근린공원이용권과 온천권은 관습법상의 물권이다. → X
4. 불법점유자에게 고의·과실이 없어도 소유자의 물권적 청구권은 인정된다. → O
5. 저당권자는 저당물을 불법점유하는 자에게 자신에게 반환할 것을 청구할 수 있다. → X
6. 甲이 乙에게 명의신탁한 부동산을 乙이 丙에게 처분하였다가 乙이 다시 취득한 경우, 甲은 乙에게 소유물반환청구권을 행사할 수 있다. → X (丙의 취득으로 甲은 소유권을 확정적으로 상실)
7. 토지 소유자는 무단 신축 건물을 미등기로 매수하여 점유하는 자에게 철거를 청구할 수 없다. → X
8. 토지 소유자는 무단 신축 건물의 소유자에게 건물에서의 퇴거를 청구할 수 있다. → X (소유자에게는 철거, 임차인에게 퇴거)
9. 이전등기청구 소송에서 승소판결이 확정되면 매수인은 판결확정 시에 소유권을 취득한다. → X (이행판결 → 등기 필요)
10. 공유물분할 소송 중 조정이 성립하여 조서가 작성되어도 등기를 하여야 물권변동의 효력이 생긴다. → O
11. 법정지상권을 취득한 자로부터 건물과 지상권을 매수한 자는 지상권 이전등기를 하여야 지상권을 취득한다. → O
12. 乙이 甲에 대한 등기청구권을 丙에게 양도하고 甲에게 통지하면 丙은 甲에게 직접 이전등기를 청구할 수 있다. → X (甲의 동의·승낙 필요)
13. 중간생략등기의 전원 합의가 있으면 乙의 甲에 대한 등기청구권은 소멸한다. → X
14. 점유취득시효 완성자가 점유를 상실하면 등기청구권은 즉시 소멸한다. → X (그때부터 소멸시효 진행)
15. 1번 저당권이 무효가 되었더라도 2번 저당권자가 있는 상태에서 새로 발생한 채권을 위해 1번 저당권 등기를 유용할 수 있다. → X
16. 가등기에 기한 본등기는 현재의 소유명의인 丙에게 청구하여야 한다. → X (가등기 당시 소유자 甲)
17. 등기명의인이 주장하는 등기원인이 인정되지 않으면 등기의 추정력은 번복된다. → X
18. 소유권이전등기의 명의자는 전 소유자에 대하여는 추정력을 주장하지 못한다. → X
19. 근저당권설정등기가 있으면 피담보채권의 존재 및 기본계약의 존재가 추정된다. → X
20. 대항력 있는 임차권 뒤에 저당권이 설정된 건물을 임차인이 경매로 취득하면 임차권은 소멸하지 않는다. → X (경매 취득 시에는 혼동으로 소멸. 매매로 취득한 경우에 존속)
21. 저당권자가 소유권을 취득하여 소멸한 저당권은 그 소유권 취득이 무효로 밝혀져도 부활하지 않는다. → X

제5장 점유권

점유의 관념화 - 간접점유와 점유보조자 ★★

구분	점유권	점유보호청구권	자력구제권
간접점유자(임대인·전세권설정자 등 점유매개관계로 타인에게 점유하게 한 자)	O	O	X(통설)
직접점유자(임차인 등)	O	O	O
점유보조자(점원·가사도우미 등 타인의 지시를 받아 사실상 지배)	X	X	O(통설)

- 점유보조자는 점유권이 없으므로 물권적 청구권의 **상대방도 될 수 없다**. 간접점유자는 상대방이 된다.
- 직접점유자가 간접점유자의 의사에 반하여 점유물을 타인에게 임의로 인도한 경우, 간접점유자는 점유물반환청구권을 행사하지 **못한다**(침탈이 아님).
- **건물의 부지**는 **건물 소유자**가 점유(건물을 점거하지 않아도). 건물의 유치권자·임차인은 부지의 점유자가 아니다.
- 소유권**이전**등기 명의자는 그 무렵 점유를 이전받은 것으로 볼 수 있으나, 소유권**보존**등기 명의자는 그렇지 않다.
- 점유권에 기인한 소와 본권에 기인한 소는 서로 영향을 미치지 않는다(본권에 관한 이유로 점유의 소를 재판할 수 없다).

자주점유와 타주점유 ★★★

쟁점(강사 핵심요약)	결론
자주점유의 개념	**소유의 의사(소유하려는 의사)**로 하는 점유. 소유권이 있다고 믿는 것(선의)과는 별개
자주·타주의 판단	점유자의 내심의 의사가 아니라 **점유권원의 성질에 의해 객관적으로** 판단
권원이 분명하지 않은 경우	**자주점유로 추정**(제197조) → 타주를 주장하는 자가 입증. 점유자가 스스로 자주점유의 권원을 입증하지 못해도 추정은 유지
악의의 무단점유가 입증된 경우	추정 깨짐 → **타주**
지방자치단체가 취득절차 증거를 제출하지 못하는 사실만으로	자주 추정 **번복되지 않음**

자주점유 O	타주점유 O
· **매매**(무효임을 모르고 매수한 경우 포함 - 후에 알게 되어도 자주 유지) 후 **매수인**의 점유 · 타주점유자(임차인)로부터 **매수**하여 점유하는 자(새 권원) - 자기 점유만 주장하면 자주 · 인접 토지를 **약간** 침범하여 점유 · 공유자 1인의 공유토지 전부 점유 중 **자기 지분** 비율 부분 · 매매계약이 해제되기 전 매수인	· **명의수탁자**(양자간·유효 명의신탁 모두), **분묘기지권자**, 임차인, 전세권자 · 매도하여 **이전등기해 준 매도인**(인도의무 있음) · 공부상 면적을 **상당히 초과**한 부분(경계침범 초과분) · **계약형 명의신탁**에서 신탁자의 점유 · 타주점유자의 **상속인**(새 권원 없는 한 자기 점유만 주장 불가) · 매매계약이 **해제**된 후 매수인의 점유 · 악의의 무단점유

본권에 관한 소와 점유의 전환

상황	결론
점유자가 소유자를 상대로 소(등기청구 등) 제기 → 점유자 패소	자주 추정 **유지**(타주로 전환 X)
소유자가 점유자를 상대로 소(반환청구) 제기 → 점유자 패소	**판결 확정 시**부터 **타주**로 전환
선의 점유자가 본권의 소에서 패소	**소 제기 시**부터 **악의** 점유자로 본다(제197조 2항)

암기
악의 전환은 "**소 제기 시**", 타주 전환은 "**판결 확정 시**".

점유의 추정력 ★★

- **태양의 추정**: 점유자는 **소유의 의사(자주)·선의·평온·공연**하게 점유한 것으로 추정. **무과실은 추정되지 않는다**(등기부취득시효 주장자가 스스로 입증).
- **계속의 추정**: 전후 양 시점에 점유한 사실이 있으면 그 사이 **계속**된 것으로 추정.
- **권리적법의 추정**(제200조): **동산**에만. 부동산(등기된 부동산)에는 적용 X.
- **점유의 승계**: 승계인은 자기 점유만 주장하거나 전 점유자의 점유를 아울러 주장할 수 있다. 아울러 주장하면 **하자(악의·타주 등)도 승계**. 상속인은 새로운 권원이 없는 한 자기 점유만 주장할 수 없다.

점유자와 회복자의 관계 ★★★

구분	선의 점유자	악의 점유자
과실(果實)(제201조)	**취득**(→ 부당이득반환의무 없음). 과실수취권 있는 본권이 있다고 **오신할 정당한 근거** 필요	수취한 과실 **반환**. 소비·과실(過失)로 훼손·수취 못한 과실의 대가 보상(과실 없이 수취 못한 것은 보상 X)
멸실·훼손 손해배상(제202조)	**자주**점유: 현존이익 한도 / **타주**점유: 모든 손해	모든 손해
비용상환청구(제203조)	선의·악의 **동일**하게 인정(악의 점유자도 가능). 청구 시점: **점유물을 반환할 때**(지출 즉시 X). 회복자가 반환청구 없이 등기말소만 구하면 비용상환 청구 불가	
필요비	가액 증가와 무관하게 청구. 단 **과실을 취득한 경우 통상의 필요비는 청구 불가**(선의 점유자). 악의 점유자는 과실을 취득하지 않으므로 통상 필요비도 청구 가능. 상환기간 허여 X	
유익비	**가액의 증가가 현존**하는 경우에 한하여, **회복자의 선택**에 따라 지출액 또는 증가액. 회복자의 청구로 법원이 **상환기간 허여 가능**(허여되면 유치권 불성립)	

선의 점유자가 점유물을 훼손한 경우에도 불법행위 손해배상책임은 성립할 수 있다(제202조는 배상 범위를 제한할 뿐).

점유보호청구권 ★★

쟁점(강사 핵심요약)	결론
점유물반환청구권의 요건	점유를 **침탈**당한 경우만. **사기(기망)로 인도**하거나 스스로 이전한 경우 **불가**
침탈자의 **특별승계인**에 대한 청구	**선의**의 특별승계인에게는 불가. **악의**면 가능. 포괄승계인(상속인)에게는 가능
행사기간	침탈당한 날부터 **1년** - **제척기간이며 출소기간**(반드시 소송으로 행사, 법원의 직권조사 사항)
방해제거청구	방해가 종료한 날부터 1년 내. 공사로 인한 방해: **착수 후 1년 경과 또는 공사 완성 시**에는 청구 불가
방해예방청구	방해의 염려가 있는 동안 언제든지. 예방 **또는** 손해배상의 담보를 청구(둘 다 함께 X)
자력구제	침탈 직후(현장에서 또는 추적하여) 즉시 가능. 점유자가 침탈 사실을 몰랐더라도 상당한 시간이 지나면 불가

기출·모의 지문 OX

1. 점유보조자도 점유보호청구권을 행사할 수 있다. → X (간접점유자는 가능)
2. 건물에 유치권을 행사하는 자는 그 건물의 부지를 점유하는 것으로 볼 수 없다. → O
3. 점유가 자주점유인지는 점유자에게 소유의 의사가 있었는지를 조사하여 판단한다. → X (권원의 성질에 따라 객관적으로)
4. 타주점유자의 상속인은 특별한 사정이 없는 한 자신만의 점유를 주장하지 못한다. → O
5. 명의신탁자의 자금으로 수탁자가 매수인이 되어 매수한 부동산에 대한 신탁자의 점유는 자주점유이다. → X
6. 매매계약이 무효임을 모르고 매수한 자가 후에 무효임을 알게 되면 타주점유로 변경된다. → X
7. 점유자가 소유자를 상대로 소를 제기하였다가 패소하면 판결 확정 시부터 타주점유로 변경된다. → X (소유자가 제기한 소에서 패소한 경우에 전환)
8. 선의 점유자가 본권의 소에서 패소하면 판결이 확정된 때부터 악의 점유자로 본다. → X (소 제기 시)
9. 점유자는 소유의 의사로 선의이며 과실 없이 점유한 것으로 추정된다. → X (무과실은 추정 X)
10. 점유의 승계인이 전 점유자의 점유를 아울러 주장하면 그 하자도 승계한다. → O
11. 선의 점유자가 과실을 취득하여 회복자에게 손해가 생기면 부당이득반환의무를 진다. → X
12. 선의 점유자라도 타주점유자이면 멸실·훼손으로 인한 모든 손해를 배상하여야 한다. → O
13. 점유할 권한이 없음을 알고 점유물을 사용·수익한 점유자도 통상의 필요비를 청구할 수 있다. → O (악의 점유자는 과실을 반환하므로)
14. 유익비는 지출액 또는 증가액을 점유자의 선택에 따라 상환청구할 수 있다. → X (회복자의 선택)
15. 회복자가 점유 반환을 청구하지 않고 이전등기 말소만 청구하면 점유자는 유익비 상환을 청구하지 못한다. → O
16. 乙이 甲을 기망하여 점유물을 인도받은 경우 甲은 乙에게 점유물반환청구권을 행사할 수 있다. → X (침탈이 아님)
17. 점유물반환청구권은 소송 외의 방법으로도 행사할 수 있다. → X (1년의 출소기간)
18. 점유 침탈자가 선의의 丙에게 매도·인도한 경우 甲은 丙에게 반환을 청구할 수 없다. → O
19. 점유자는 방해의 예방과 함께 손해배상의 담보를 청구할 수 있다. → X (예방 또는 담보 중 선택)

제6장 소유권

소유권 단원은 **상린관계 → 취득시효 → 부합 등 소유권취득 → 공동소유(공유)**의 네 덩어리로 출제된다. 특히 **취득시효(완성 후 법률관계)**와 **공유 사례**는 매년 반복 출제되는 최고 빈출 영역이므로, 결론을 문장으로 외우는 것이 아니라 "누가 누구에게 무엇을 청구할 수 있는가"를 표로 정리해 두어야 한다.

Ⅰ. 상린관계 ★★★

1. 상린관계의 의의와 성질

- 서로 인접한 부동산 소유자 사이에서 **이용을 조절**하기 위해 법률이 각자의 소유권을 확장하거나 제한하는 관계를 말한다(제216조~제244조).
- 상린관계 규정은 **법률의 규정에 의한 권리·의무**이므로 등기 없이도 당연히 발생하고, 토지가 양도되면 새 소유자에게 **당연히 따라간다**.
- 소유권뿐 아니라 **지상권·전세권**에도 준용된다(임차인에 대해서도 판례가 유추 적용을 인정).

2. 조문별 핵심 정리

조문	내용	핵심 결론(자주 바꿔치기되는 부분)
제216조 인지사용청구권	경계나 그 근방에서 담·건물을 **축조·수선**하기 위해 필요한 범위에서 이웃 토지의 사용을 청구할 수 있다.	이웃의 **주거(住居)**에 들어가려면 **그 이웃의 승낙**이 필요하다. 승낙을 거부하면 승낙에 갈음하는 판결을 받아야 하며, 이웃이 손해를 입은 때에는 **보상**을 청구할 수 있다.
제237조 경계표·담의 설치	인접지 소유자는 공동비용으로 경계표·담을 설치할 수 있다.	**설치비용은 쌍방이 절반씩(균분) 부담**, **측량비용은 토지의 면적에 비례**하여 부담. (비용 부담 기준을 서로 바꾸는 지문이 단골이다.)
제240조 수지·목근의 제거	이웃 나무의 가지·뿌리가 경계를 넘은 경우.	**가지(수지)**는 먼저 **소유자에게 제거를 청구**하고 응하지 않을 때 비로소 임의로 제거할 수 있다. **뿌리(목근)**는 **청구 없이 곧바로 임의 제거** 가능.
제242조 경계선 부근의 건축	건물을 축조할 때 경계로부터 **0.5m(반미터) 이상**의 거리를 두어야 한다.	위반 시 변경·철거를 청구할 수 있으나, **건축에 착수한 후 1년이 지났거나 건물이 완성된 후**에는 변경·철거는 청구하지 못하고 손해배상만 청구할 수 있다.

두문자·암기법

"가지는 말하고, 뿌리는 자른다" — 가지(수지)는 청구 먼저, 뿌리(목근)는 바로 제거. / **"설반측면"** — **설**치비용은 **반**씩, **측**량비용은 **면**적비율. / **"반미터, 일년"** — 0.5m 위반이라도 착수 후 1년 또는 완성 후면 **돈(손해배상)만**.

3. 주위토지통행권(제219조·제220조) ★★★

(1) 요건과 주체

- 어느 토지와 공로 사이에 **통로가 없어** 타인의 토지를 통과하지 않으면 공로에 출입할 수 없거나 **과다한 비용**을 요하는 경우에 인정된다(법정 통행권이므로 등기 불요).
- 통행권자: **토지소유자·지상권자·전세권자**, 판례는 **임차인**에게도 인정한다.
- 통행권자는 통행지 소유자의 손해를 **보상**하여야 한다(제219조 제2항).

(2) 범위에 관한 판례 법리(가장 많이 묻는 부분)

- 기존 통로가 있더라도 그것이 **통로로서의 충분한 기능을 하지 못하는 때**에는 새로운 통행권이 인정된다.
- 그러나 **기존 통로보다 더 편리하다는 이유만**으로는 다른 장소의 통행권을 주장할 수 없다.
- 통행권의 범위는 **현재의 토지 이용상황**을 기준으로 정한다. 장래의 이용상황까지 미리 대비한 범위는 인정되지 않는다.
- **건축법상 도로 폭**에 관한 규정이 있다고 하여 그 너비만큼 당연히 통행권이 보장되는 것은 아니다.

- 통행권자의 **승낙**을 받아 함께 통행하는 자에 대하여도, 통행지 소유자는 **그 자에게 직접 통행에 대한 대가(지료 상당액)를 청구할 수 있다**(판례).

(3) 무상주위토지통행권(제220조)

구분	당사자(분할자·일부양도 당사자) 사이	그 토지가 제3자에게 양도된 경우
토지의 분할·일부 양도로 공로에 통하지 못하게 된 때	**무상** 통행권(보상의무 없음), 다른 분할자·양도당사자의 토지만 통행	무상통행권은 승계되지 않는다 → 특정승계인에 대해서는 **제219조의 유상 통행권**만 문제된다

함정 주의
① "더 편리하므로 새 통로를 달라" → **불인정**. ② "장래 아파트를 지을 것이므로 넓게 달라" → **불인정(현재 이용상황 기준)**. ③ "분할로 생긴 무상통행권은 토지를 산 사람에게도 그대로 따라간다" → **틀림(제3자에게는 무상통행권이 인정되지 않는다)**.

Ⅱ. 취득시효 ★★★

1. 종류와 요건 비교

구분	부동산 점유취득시효(§245①)	부동산 등기부취득시효(§245②)	동산(§246)
기간	**20년**	**10년**	일반 **10년** / 단기 **5년**
점유의 태양	소유의 의사(자주)·평온·공연	자주·평온·공연 + **선의·무과실**	10년: 자주·평온·공연 5년: + **선의·무과실**
등기	기간 만료 후 **등기하여야** 취득	**소유자로 등기되어 있을 것**(등기가 요건)	등기 불요
효과	등기 시 소유권 취득	기간 경과로 소유권 취득	기간 경과로 소유권 취득

점유취득시효에서 **선의·무과실은 요건이 아니다**. 반대로 등기부취득시효와 동산 단기시효에서는 선의·무과실이 필요하며, **무과실은 추정되지 않으므로 주장하는 자가 증명**해야 한다(자주·평온·공연·선의는 제197조에 의해 추정).

2. 시효취득의 대상

시효취득 O	시효취득 X
소유권, 지상권·지역권(계속되고 표현된 것)·전세권 등 **계속 행사되는 재산권**, 관습법상 **분묘기지권**	**점유권·유치권·저당권**
자기 소유 부동산, **토지의 일부**, **공유지분**, **간접점유**에 의한 시효취득	**행정재산**(공용폐지 전), 집합건물의 **공용부분**
국유재산 중 **일반재산(구 잡종재산)**	

- **점유권**은 점유라는 사실상태 그 자체에서 나오는 권리이므로 따로 시효취득의 객체가 될 수 없다. **유치권·저당권**은 점유의 계속을 권리의 내용으로 하는 권리가 아니거나 등기(설정계약)에 의해서만 성립하는 담보물권이므로 시효취득의 대상이 아니다.
- **자기 소유**의 부동산도 시효취득을 주장할 수 있다(등기명의와 실질관계가 일치하지 않아 소유권 증명이 곤란한 경우 실익이 있다).
- **집합건물의 공용부분**은 전유부분과 분리하여 처분할 수 없으므로 시효취득의 대상이 되지 않는다.

3. 기산점

- **원칙**: **점유를 개시한 때**가 기산점이며, 점유자가 임의로 기산점을 선택할 수 없다.
- **예외**: 시효기간 중 **소유자의 변동이 없는 경우**에는 기산점을 임의로 선택하여 주장할 수 있다(판례).
- **재취득시효(2차 취득시효)**: 시효완성 후 소유자가 변경된 경우, 점유자는 **그 소유권 변동시를 새로운 기산점**으로 삼아 다시 취득시효의 완성을 주장할 수 있다(판례).

4. 효과

- 시효취득은 **원시취득**이다(승계취득 아님).
- 소유권 취득의 효력은 **점유를 개시한 때에 소급**한다(제247조). 등기한 때로 소급하는 것이 아니다. → 시효기간 중의 과실(果實)은 점유자에게 귀속되고, 그동안의 사용이익에 대해 부당이득반환의무를 지지 않는다.

- 점유취득시효 완성자의 **등기청구권**은 **채권적 청구권**이다(물권적 청구권 아님). 따라서 시효완성만으로 바로 소유권을 취득하지 못하고, 등기를 갖추어야 한다.
- 등기청구권은 점유를 계속하는 동안에는 소멸시효가 진행하지 않고, **점유를 상실하면 그때부터 소멸시효가 진행**한다(점유 상실만으로 곧바로 등기청구권이 소멸하는 것은 아니다).
- 소유의 의사(자주점유)는 추정되나, 타인의 토지임을 알면서 아무런 권원 없이 점유한 **악의의 무단점유**가 증명되면 자주점유의 추정은 깨진다(판례).

핵심 암기

20년·등기 / 10년·선의무과실·등기부 → 점유취득시효는 "오래 점유하고 등기까지", 등기부취득시효는 "등기가 이미 있는 자가 짧게". 효과는 **원시취득 + 점유개시시로 소급 + 등기청구권은 채권적 청구권** 3종 세트로 외운다.

Ⅲ. 점유취득시효 완성 후의 법률관계 ★★★

1. 시효완성자와 시효완성 당시 소유자 사이

쟁점	결론	이유
소유자의 건물철거·토지반환청구	**불가**	시효완성자는 등기 전이라도 **점유할 정당한 권원**이 있다
소유자의 부당이득반환청구(사용료)	**불가**	점유할 권리가 있으므로 부당이득이 성립하지 않는다
소유자가 제3자에게 처분한 경우	원칙적으로 **채무불이행책임 없음**	소유자는 등기 전까지 여전히 소유자로서 자유롭게 처분할 수 있다
시효완성 사실을 **알고** 처분한 경우	**불법행위책임 O**	시효완성자의 등기청구권을 침해한 위법행위
매수인이 그 사실을 알면서 **적극 가담**	그 처분행위는 **반사회질서 법률행위로 무효**	이중매매 법리와 동일(제103조)

2. 등기청구의 상대방 — 소유자 변동 시점이 관건

사안	시효완성자의 등기청구
시효기간 중에 소유자가 변경된 경우	**가능** — 시효완성 당시의 새 소유자를 상대로 등기청구(시효완성자에게 불리하지 않다)
시효완성 후에 소유자가 변경된 경우	**불가** — 새 소유자(제3자)에게는 등기청구를 할 수 없다(등기청구권은 채권적 청구권이므로 시효완성 당시의 소유자에게만 주장 가능)
시효완성 후 처분되었다가 **원래 소유자가 다시 등기명의를 회복**한 경우	**가능** — 다시 소유자가 된 그 자를 상대로 등기청구할 수 있다
시효기간 중 점유를 승계한 자	**자기 명의로 직접** 등기청구 가능(점유의 승계 + 자기 점유기간 합산)
시효완성 후 점유를 승계한 자	직접 청구 불가 — **전 점유자(시효완성자)를 대위**하여만 등기청구 가능

두문자·암기법

"기간 중 변동 = OK, 완성 후 변동 = NO, 다시 돌아오면 OK" / "중간승계는 직접, 완성 후 승계는 대위"

Ⅳ. 그 밖의 소유권 취득원인 ★★

1. 부합(제256조·제257조)

유형	부합 여부	귀속·결론
부동산 + 동산	**부합 O**	**부동산 소유자**가 동산의 소유권을 취득
부동산 + 부동산	**원칙 부합 X**	각각 독립한 부동산으로 존속

토지 + 건물	**부합 X**	건물은 **언제나 토지와 별개의 독립한 부동산**
토지 + 수목(**권원 있는 자**가 식재)	부합 X	식재한 자의 소유로 존속(지상권·임차권 등 권원 필요)
토지 + 수목(**권원 없이** 식재)	부합 O	**토지 소유자**에게 귀속

- **건물의 증축부분**: 권원 있는 자가 증축하였더라도 **구조상·이용상 독립성**이 있어야 부합하지 않고 별개의 소유권(구분소유권)이 성립할 수 있다. 독립성이 없으면 권원의 유무와 관계없이 기존 건물에 부합한다.

2. 무주물 선점·유실물 습득·매장물 발견

구분	요건·기간	귀속
무주물 선점 (§252)	무주의 **동산**을 소유의 의사로 점유	**선점자**가 소유권 취득
무주의 부동산	—	**국유**(선점 불가)
유실물 습득 (§253)	법률에 정한 공고 후 **6개월** 내에 소유자가 권리를 주장하지 않을 것	**습득자**가 소유권 취득
매장물 발견 (§254)	공고 후 **1년** 내에 소유자가 권리를 주장하지 않을 것	**발견자**가 소유권 취득(타인의 토지 등에서 발견한 때에는 토지소유자와 절반씩)

두문자·암기법

"유(6)실물은 6개월, 매장물은 1년" — 숫자를 서로 바꾼 지문이 전형적인 오답이다.

Ⅴ. 공동소유 ★★★

1. 공유·합유·총유 비교

구분	공유	합유	총유
인적 결합	개인적·독립적(결합 약함)	**조합(동업관계)**	**법인 아닌 사단**(종중·교회·부락공동체)
지분	O(자유로운 처분 가능)	O(단, 처분에 합유자 전원의 동의 필요)	X
분할청구	O(원칙적 자유)	X(조합 존속 중)	X
목적물의 처분	공유자 **전원의 동의**	합유자 **전원의 동의**	**사원총회의 결의**
예	공동상속재산(분할 전)	동업체가 매수한 부동산	종중 소유 토지

2. 공유물의 처분·관리·보존(제263조~제265조)

행위	요건	구체적 예
지분의 처분	**각자 단독·자유**	지분의 양도·저당권 설정(다른 공유자 동의 불요)
사용·수익	지분의 비율로 **공유물 전부**를 사용·수익	지분 1/3이라도 특정 1/3 부분이 아니라 전부에 미친다
처분·변경	**공유자 전원의 동의**	공유물 전부의 매도, 대지의 형질변경, 건물의 철거
관리행위	**지분의 과반수**로 결정	임대차 체결·해지, 사용방법의 결정, 갱신거절 여부의 결정
보존행위	**각 공유자 단독**	원인무효등기의 말소청구, 불법점유자에 대한 반환청구

지분이 정확히 1/2인 공유자는 과반수에 이르지 못하므로 **단독으로 관리방법(사용방법)을 정할 수 없다**. 다만 보존행위는 지분의 크기와 무관하므로 1/2 지분권자도 단독으로 할 수 있다.

3. 필수 사례 정리 ★★★

[사례 A] 과반수지분권자가 단독으로 점유·사용 — 甲 2/3, 乙 1/6, 丙 1/6 중 甲이 전부 사용

乙·丙의 청구	가부	이유
甲에 대한 공유물 반환(인도) 청구	**불가**	과반수지분권자가 공유물을 스스로 사용하기로 정하는 것도 **적법한 관리행위**이므로 甲의 점유는 위법하지 않다
甲에 대한 부당이득반환청구	**가능**(각 1/6)	적법한 사용이더라도 **자기 지분에 상응하는 사용이익**까지 甲이 보유할 근거는 없다

[사례 A-2] 소수지분권자가 단독으로 전부 점유·사용 — 乙(1/6)이 甲의 동의 없이 전부 사용

- 이는 적법한 관리행위가 아니다. 그러나 다른 소수지분권자 丙은 물론 **과반수에 미달하는 공유자**는 乙에게 **공유물의 인도(반환) 자체를 청구할 수는 없고**, **방해배제(방해제거)청구**만 할 수 있다(2020년 대법원 전원합의체).
- 甲·丙은 각자의 지분 비율(甲 2/3, 丙 1/6)만큼 乙에게 **부당이득반환**을 청구할 수 있다.

인도를 명하면 청구한 사람이 다시 단독점유를 하게 되어 같은 위법상태가 반복되기 때문이다. "소수지분권자 → 소수지분권자"의 관계에서는 **인도 X, 방해배제 O**로 기억한다.

[사례 B] 과반수지분권자의 단독 임대 — 甲 2/3, 乙 1/3, 甲이 단독으로 A에게 임대

- 甲의 임대는 **적법한 관리행위**이므로 **乙은 임차인 A에게 공유물의 반환을 청구할 수 없다**.
- 乙은 **A에게 차임의 1/3을 직접 청구할 수도 없다**(乙은 임대차계약의 당사자가 아니다).
- 乙은 **甲에게** 자기 지분 상당액(1/3)을 **부당이득**으로 반환청구할 수 있다.
- 상가임대차에서 **갱신거절 여부의 결정**도 관리행위이므로 과반수지분권자 甲이 단독으로 결정할 수 있다.

[사례 C] 공유자 1인이 공유물 전부를 매도한 경우

- 甲이 단독으로 공유물 전부를 A에게 매도하였더라도 **매매계약 자체는 유효**하다(타인 권리의 매매도 유효, 제569조).
- A 앞으로 전부에 관한 소유권이전등기가 마쳐지면, 乙은 **자기 지분(1/3)의 범위에서만** 그 등기의 말소를 청구할 수 있다(甲의 지분 부분은 유효한 처분이다).

[사례 D] 원인무효등기의 말소

공유물에 관하여 **원인무효의 등기**가 되어 있는 경우 그 말소청구는 성질상 **보존행위**이므로, 지분의 크기와 관계없이 각 공유자가 단독으로 등기 전부의 말소를 구할 수 있다(등기명의자가 다른 공유자이든 제3자이든 같다).

[사례 E] 제3자의 불법점유 — 甲 2/3, 乙 1/6, 丙 1/6, A가 불법점유

청구	결론
A에 대한 공유물 반환청구	**보존행위**이므로 甲·乙·丙 **누구든 단독으로 전부의 반환**을 청구할 수 있다
A에 대한 손해배상(부당이득)청구	손해배상채권은 **가분채권**이므로 **각자 자기 지분 비율만큼만**(甲 2/3, 乙 1/6, 丙 1/6) 청구할 수 있다

핵심 암기

"물건은 전부, 돈은 지분만" — 제3자를 상대로 한 **반환·말소청구(보존행위)는 단독으로 전부**, **손해배상·부당이득은 자기 지분만**. 또한 **"과반수는 쓸 수 있다, 단 돈은 나눠라"** — 과반수지분권자의 사용·임대는 적법하지만 소수지분권자에게 지분 상당액을 부당이득으로 반환해야 한다.

4. 공유물의 분할(제268조~제270조)

(1) 분할청구의 자유

- 공유물분할청구권은 **형성권**으로, 공유자는 원칙적으로 **언제든지** 분할을 청구할 수 있고 상대방은 이를 거절하지 못한다.
- **분할금지특약**은 **5년 내**의 기간에 한하여 유효하며, 갱신할 수 있으나 갱신한 날부터 **5년을 넘지 못한다**. (등기하여야 지분의 양수인에게 대항할 수 있다.)
- 분할청구권은 **공유관계가 존속하는 한** 소멸시효에 걸리지 않는다.
- 분할절차에는 **공유자 전원이 참여**하여야 하며, 일부 공유자만 참여한 분할은 **무효**이다.

- 이미 **협의에 의한 분할이 성립**한 경우에는 다시 재판상 분할을 청구할 수 없다.

(2) 분할의 방법

구분	협의분할	재판상 분할
요건	공유자 전원의 협의	**협의가 성립되지 아니한 때**에만 법원에 청구
방법	현물분할·대금분할·가액배상 등 자유	**현물분할이 원칙**. 현물분할이 불가능하거나 현물분할로 현저히 가액이 감손될 염려가 있는 때에 한하여 **경매를 명하여 대금분할**
물권변동	**등기하여야** 효력 발생(창설적 등기)	**판결 확정 시 등기 없이** 효력 발생(제187조)

- 현물분할이 가능한데도 곧바로 경매(대금분할)를 명하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.
- 판례는 **분할을 청구한 공유자의 지분 한도에서만 현물분할**을 하고 분할을 원하지 않는 나머지 공유자들은 종전대로 공유로 남게 하는 방법도 허용한다. 다만 **분할을 원하는 공유자를 그 의사에 반하여 계속 공유관계에 묶어두는 방식**은 허용되지 않는다.

(3) 분할의 효과

- 분할로 각 공유자는 단독소유권을 취득한다. 공유자는 다른 공유자가 분할로 취득한 물건에 대하여 **그 지분의 비율로 매도인과 동일한 담보책임**을 진다(제270조).
- 공유지분 위에 설정된 **저당권**은 공유물분할이 있더라도 저당권자의 동의가 없는 한 **분할된 각 부분 위에 종전의 지분비율대로 존속**하는 것이 원칙이며, 저당권설정자가 분할로 취득한 특정 부분에 당연히 집중되는 것은 아니다.

함정 주의

① "재판상 분할은 등기하여야 효력이 생긴다" → **틀림**(판결 확정 시 효력 발생). ② "협의분할은 협의만으로 소유권이 이전된다" → **틀림**(등기 필요). ③ "분할금지특약은 10년까지 가능" → **틀림**(5년). ④ "공유물분할청구권도 10년의 소멸시효에 걸린다" → **틀림**(공유관계 존속 중에는 시효로 소멸하지 않는다).

기출·모의 지문 OX

1. 인접지 소유자가 경계표를 설치하는 경우 그 설치비용과 측량비용은 모두 토지 면적에 비례하여 부담한다. → X (설치비용은 쌍방이 절반씩 균분 부담하고, 측량비용만 면적에 비례한다.)
2. 경계를 넘은 이웃 나무의 뿌리는 소유자에게 제거를 청구한 후 응하지 않을 때에만 임의로 제거할 수 있다. → X (뿌리는 곧바로 임의로 제거할 수 있다. 제거청구를 먼저 해야 하는 것은 가지이다.)
3. 건물을 경계로부터 0.5m 미만의 거리에 축조한 경우, 건물이 완성된 후에도 인접지 소유자는 그 철거를 청구할 수 있다. → X (착수 후 1년이 지났거나 건물이 완성된 후에는 손해배상만 청구할 수 있다.)
4. 주위토지통행권의 범위는 장래의 토지 이용상황까지 미리 고려하여 정하여야 한다. → X (현재의 이용상황을 기준으로 정한다.)
5. 기존 통로가 있더라도 그보다 더 편리하다는 이유만으로 다른 장소의 통행권을 주장할 수 있다. → X (더 편리하다는 사정만으로는 인정되지 않는다. 기존 통로가 통로로서 충분한 기능을 하지 못하는 경우여야 한다.)
6. 토지의 분할로 인하여 발생한 무상의 주위토지통행권은 그 토지의 특정승계인에게도 그대로 인정된다. → X (당사자 사이에서만 무상이고, 제3자에게 양도된 후에는 제219조의 유상 통행권이 문제된다.)
7. 점유취득시효가 완성되려면 20년간 소유의 의사로 평온·공연하게 점유하여야 하고, 그 점유는 선의·무과실이어야 한다. → X (점유취득시효에서 선의·무과실은 요건이 아니다. 등기부취득시효와 동산 단기취득시효의 요건이다.)
8. 저당권과 유치권도 취득시효의 대상이 될 수 있다. → X (점유권·유치권·저당권은 시효취득의 대상이 되지 않는다. 소유권·지상권·분묘기지권 등은 가능하다.)
9. 국유재산 중 행정재산은 공용폐지가 없는 한 시효취득의 대상이 되지 않지만, 일반재산은 시효취득의 대상이 된다. → O
10. 토지의 일부나 공유지분에 대해서는 취득시효가 인정되지 않는다. → X (토지의 일부, 공유지분, 자기 소유 부동산, 간접점유에 의한 시효취득 모두 가능하다.)
11. 취득시효로 인한 소유권 취득의 효력은 등기한 때부터 발생한다. → X (점유를 개시한 때에 소급한다. 그 결과 시효기간 중의 사용이익에 대해 부당이득반환의무를 지지 않는다.)
12. 점유취득시효가 완성된 후 등기를 마치기 전이라도, 그 소유자는 시효완성자에게 토지의 인도나 부당이득의 반환을 청구할 수 없다. → O
13. 점유취득시효 완성 후 소유자가 그 토지를 제3자에게 처분하면, 시효완성자는 그 제3자에게 시효완성을 이유로 등기를 청구할 수 있다. → X (등기청구권은 채권적 청구권이므로 시효완성 당시의 소유자에게만 주장할 수 있다. 다만 원 소유자가 다시 등기명의를 회복하면 그에게 청구할 수 있다.)
14. 시효완성 후에 점유를 승계한 자는 자기 명의로 직접 소유권이전등기를 청구할 수 있다. → X (전 점유자(시효완성자)를 대위하여서만 청구할 수 있다. 직접 청구가 가능한 것은 시효기간 중에 점유를 승계한 자이다.)
15. 타인의 토지에 권원 없이 나무를 심은 경우, 그 나무는 심은 사람의 소유로 남는다. → X (권원 없이 식재한 수목은 토지에 부합하여 토지소유자에게 귀속된다. 권원 있는 자가 식재한 경우에만 부합하지 않는다.)
16. 무주의 부동산을 소유의 의사로 점유한 자는 그 소유권을 취득한다. → X (무주의 부동산은 국유이다. 선점의 대상은 무주의 동산뿐이다.)
17. 합유자는 다른 합유자의 동의 없이 자기의 지분을 자유롭게 처분할 수 있다. → X (합유지분의 처분에는 합유자 전원의 동의가 필요하다. 자유로운 지분 처분이 가능한 것은 공유이다.)
18. 공유물에 관한 임대차계약의 체결은 공유물의 관리행위이므로 공유자 지분의 과반수로 결정한다. → O
19. 지분이 1/2인 공유자는 단독으로 공유물의 사용방법을 정할 수 있다. → X (1/2은 과반수가 아니므로 관리방법을 단독으로 정할 수 없다. 다만 보존행위는 단독으로 할 수 있다.)
20. 甲(2/3)·乙(1/6)·丙(1/6)의 공유물을 甲이 단독으로 점유·사용하는 경우, 乙은 甲에게 공유물의 인도를 청구할 수 있다. → X (과반수지분권자의 사용은 적법한 관리행위이므로 인도를 청구할 수 없다. 다만 자기 지분(1/6) 상당액의 부당이득반환은 청구할 수 있다.)
21. 소수지분권자가 다른 공유자의 동의 없이 공유물 전부를 독점 점유하는 경우, 다른 소수지분권자는 그에게 공유물의 인도를 청구할 수 있다. → X (인도는 청구할 수 없고 방해배제만 청구할 수 있다. 부당이득반환은 자기 지분 비율만큼 청구 가능하다.)
22. 甲(2/3)이 단독으로 공유물을 A에게 임대한 경우, 乙(1/3)은 A에게 차임의 1/3을 직접 청구할 수 있다. → X (乙은 임대차계약의 당사자가 아니므로 A에게 직접 청구할 수 없고, 甲에게 부당이득으로 1/3 상당액을 청구해야 한다.)
23. 공유자 甲이 단독으로 공유물 전부를 A에게 매도한 경우 그 매매계약은 무효이다. → X (타인 권리의 매매도 유효하다. 다만 A 명의로 전부 이전등기가 되면 乙은 자기 지분 범위에서 말소를 청구할 수 있다.)
24. 제3자가 공유물을 불법점유한 경우, 각 공유자는 단독으로 공유물 전부의 반환을 청구할 수 있고 손해배상도 전액을 청구할 수 있다. → X (반환청구는 보존행위로서 단독으로 전부 가능하지만, 손해배상은 가분채권이므로 자기 지분 비율만큼만 청구할 수 있다.)

25. 공유물분할금지의 특약은 10년을 넘지 못하며 갱신할 수 없다. → X (5년 내에서 유효하고, 갱신할 수 있으나 갱신한 날부터 5년을 넘지 못한다.)
26. 재판에 의한 공유물분할의 경우 분할판결이 확정되면 등기 없이도 물권변동의 효력이 생긴다. → O (반면 협의분할은 등기하여야 효력이 생긴다.)
27. 현물분할이 가능한 경우에도 법원은 임의로 경매를 명하여 대금분할을 할 수 있다. → X (현물분할이 원칙이며, 현물분할이 불가능하거나 현저히 가액이 감손될 염려가 있는 때에만 경매·대금분할이 허용된다.)
28. 공유자는 다른 공유자가 분할로 취득한 물건에 대하여 그 지분의 비율로 매도인과 같은 담보책임을 진다. → O

마무리 체크: ① 상린관계는 **숫자(0.5m·1년·절반·면적비율)**와 **가지/뿌리** 구분, ② 취득시효는 **20년·10년**과 **소유자 변동 시점**, ③ 공유는 **처분(전원)·관리(과반수)·보존(단독)** 삼분법과 **"물건은 전부, 돈은 지분만"**만 정확히 잡아도 이 단원의 실전 정답률은 크게 올라간다.

제7장 용익물권

제1절 지상권 총설 ★★★

1. 의의와 법적 성질

지상권은 **타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 물권**이다(제279조). 토지 그 자체를 객체로 하는 **용익물권**으로서 다음과 같은 성질을 가진다.

- **타물권** — 자기 토지에는 원칙적으로 설정하지 못한다.
- **지상물의 현존을 요하지 않는다** — 설정 당시 건물이나 수목이 **없어도** 지상권은 유효하게 성립한다. 따라서 **기존의 지상 건물이 멸실하더라도 존속기간이 남아 있는 한 지상권은 소멸하지 않는다**.
- **지료는 지상권의 요소가 아니다** — 무상의 지상권도 유효하다(전세권의 전세금과 구별).
- **독립성** — 지상권은 지상물의 소유권에 부종하지 않으므로 **건물과 분리하여 지상권만을 양도**할 수 있다.

2. 존속기간

(1) 최단존속기간(제280조) — 강행규정

지상물의 종류	최단존속기간
석조·석회조·연와조 또는 이와 유사한 **견고한 건물**이나 **수목**	30년
그 밖의 건물(목조 등)	15년
건물 이외의 공작물	5년

약정기간이 위 기간보다 **짧은** 때에는 위 기간까지 연장된다. 계약으로 존속기간을 정하지 않은 때에도 위 최단기간이 적용된다(제281조 제1항).

> **함정 주의**
> ① 지상권설정 당시 **공작물의 종류와 구조를 정하지 아니한 때**에는 제280조 제1항 **제2호**의 것으로 보므로 존속기간은 **15년**이다(제281조 제2항). "5년"으로 바꿔 출제하는 함정이 잦다. ② **기존 건물의 사용**을 목적으로 설정된 지상권에는 제280조의 최단존속기간 규정이 **적용되지 않는다**(판례).

(2) 최장기간

민법에는 최장기간의 제한이 **없다**. 판례는 **영구무한의 지상권 설정도 허용된다**고 본다(전세권의 최장 10년과 구별).

(3) 갱신과 지상물매수청구권(제283조)

1. 존속기간이 만료하고 **지상물이 현존**하면 지상권자는 계약의 갱신을 청구할 수 있다.
2. 설정자가 갱신을 거절하면 지상권자는 **상당한 가액으로 지상물의 매수를 청구**할 수 있다(**형성권**).

3. 지료

- 지료는 요소가 아니나, 약정한 경우 **등기하여야 제3자에게 대항**할 수 있다. 따라서 **지료를 등기하지 않으면 토지소유자는 지상권 양수인에게 지료를 청구할 수 없다**.
- 지료가 **2년분 이상 연체**되면 설정자는 지상권의 소멸을 청구할 수 있다(제287조). 2년은 연속될 필요가 없고 통산하여 2년이면 된다.
- 토지소유권이 양도된 경우, 연체가 **양도 전후에 걸쳐 2년분**에 이르더라도 **양수인에 대한 연체액이 2년분에 달하지 않으면** 양수인은 소멸청구를 할 수 없다.
- 지상권이 저당권의 목적이거나 그 토지 위의 건물·수목이 저당권의 목적인 때에는, 소멸청구는 **저당권자에게 통지한 후 상당한 기간이 경과**하여야 효력이 생긴다(제288조).
- 지료 증감청구권이 인정된다(제286조).

4. 처분의 자유

핵심 암기

지상권자는 **설정자의 의사에 반하여도** 지상권을 양도하거나 토지를 임대할 수 있고, 지상권을 담보로 제공할 수도 있다(제282조). **지상권의 처분을 금지하는 특약은 강행규정 위반으로 무효**이다. 지상권을 목적으로 하는 저당권의 설정을 금지하는 특약 역시 **효력이 없다**. (⇔ 전세권은 설정행위로 처분을 금지할 수 있다.)

지상권자에게는 **필요비상환청구권이 인정되지 않는다**. 토지의 사용대가인 지료를 부담하는 지위에 있기 때문이다.

5. 담보지상권(판례)

저당권자가 토지의 담보가치 하락을 막기 위해 함께 설정받는 무상의 지상권을 말한다.

- 지상권 존속 중에도 **설정자는 토지를 용법에 따라 사용·수익할 수 있다**.
- 담보지상권은 피담보채권에 부종하므로, **피담보채권이 시효로 소멸하면 담보지상권도 소멸**한다.
- 무단으로 건물을 축조한 자에 대하여 **철거 및 토지 인도를 청구할 수 있다**.
- 그러나 스스로 토지를 사용·수익하지 않으므로, 무단점유자에게 **임료 상당의 손해배상(부당이득)을 청구할 수는 없다**.

제2절 법정지상권과 관습법상 법정지상권 ★★★

1. 양자의 비교

구분	법정지상권(제366조)	관습법상 법정지상권
발생원인	저당권 실행 **경매**	**매매·증여·공유물분할·강제경매** 등
동일인 소유 판단시점	**저당권 설정 당시**	**소유권이 변동될 당시(처분 당시)**
건물의 존재	저당권 설정 당시 건물이 존재할 것	처분 당시 건물이 존재할 것
배제특약	**강행규정 — 포기·배제 특약 무효**	**임의규정 — 철거특약 있으면 불성립**
존속기간·지료	제280조 최단기간 적용 / 지료는 당사자 협의, 협의 불성립 시 **당사자의 청구로 법원이 결정**	

두문자·암기법

"동·존·달·특" — ①동일인 소유 ②건물 존재 ③소유자가 달라질 것 ④철거특약 없을 것. 앞 세 가지는 공통, 네 번째가 관습법상 법정지상권에서만 문제된다.

2. 성립 여부 판례 정리

사안	결론
미등기·무허가 건물의 소유를 위한 제366조 법정지상권	**성립**
토지 정착성이 없는 가설건축물	**불성립**
나대지에 저당권 설정 후 건물 신축(저당권자의 동의를 얻은 경우 포함)	**불성립**
토지·건물 공동저당 후 건물을 철거하고 신축한 경우	**불성립**
미등기건물과 토지를 함께 매수하고 토지만 이전등기 받은 뒤 토지 저당권이 실행된 경우	**불성립**
환지처분·환매로 소유자가 달라진 경우	**불성립**
토지 사용에 관하여 임대차계약을 체결한 경우	**불성립**(포기로 간주)

3. 취득과 처분 — 등기의 요부

핵심 암기

법정지상권의 **취득**은 법률규정에 의한 물권변동이므로 **등기 없이** 취득하고 토지의 새 소유자에게도 대항할 수 있다(제187조). 그러나 이를 **처분(양도)**하려면 **등기를 하여야** 한다(제187조 단서).

1. 법정지상권자 乙은 등기 없이도 토지 양수인 丙에게 대항할 수 있다.
2. 乙로부터 **매수**한 건물매수인 丁은 **지상권이전등기를 하여야** 지상권을 취득한다. 다만 등기 전이라도 토지소유자의 **건물철거청구는 신의칙에 반하여 허용되지 않는다**.
3. 다만 토지소유자는 丁에게 **토지 사용에 대한 부당이득의 반환은 청구할 수 있다**.
4. 乙로부터 건물을 **경락**받은 자는 경매가 제187조의 사유이므로 **등기 없이** 법정지상권을 취득한다.

지료가 아직 확정되지 않은 상태에서는 지료 연체를 이유로 한 지상권소멸청구를 할 수 없다.

제3절 구분지상권 ★

- 지하 또는 지상의 **공간에 상하의 범위를 정하여** 건물 기타 **공작물**을 소유하기 위해 설정한다(제289조의2). **수목의 소유를 목적으로는 설정할 수 없다**.
- 제3자가 토지를 사용·수익할 권리를 가진 때에도 **그 권리자 전원의 승낙**을 얻으면 설정할 수 있다.
- 존속기간·지상물매수청구권 등 일반 지상권 규정이 준용된다. 다만 **필요비상환청구권은 인정되지 않는다**.

제4절 분묘기지권 ★★

1. 취득유형

1. **승낙형** — 토지소유자의 승낙을 얻어 분묘를 설치한 경우
2. **취득시효형** — 타인의 토지에 승낙 없이 분묘를 설치하고 **20년간** 평온·공연하게 점유한 경우
3. **양도형** — 자기 토지에 분묘를 설치한 뒤 **이장의 특약 없이** 토지를 양도한 경우

함정 주의

① 취득시효형은 **「장사 등에 관한 법률」 시행일 전에 설치된 분묘**에 한하여 인정된다(시효기간이 시행일 전에 완성되었을 것을 요하는 것이 아니다). ② 분묘기지권의 취득에는 **등기를 요하지 않는다**. ③ 시신이 안장되어 있지 않은 **가묘·허묘**나 외부에서 인식할 수 없는 **평장·암장**은 분묘기지권이 성립하지 않는다.

2. 지료 — 유형별로 기산점이 다르다

유형	지료 지급의무의 기산점
취득시효형	**토지소유자가 지료를 청구한 날**부터
양도형	**분묘기지권이 성립한 날**부터

3. 효력과 범위

- 존속기간에 관하여 민법 제280조·제281조는 **적용되지 않는다**. 권리자가 분묘의 수호와 봉사를 계속하고 분묘가 존속하는 동안 존속한다.
- 효력은 분묘의 기지 자체뿐 아니라 **수호와 제사에 필요한 주위의 공지**에도 미친다. 면적은 장사법의 면적 규정이 절대적 기준이 되는 것은 아니고 관습에 따라 정해진다.
- 기존 분묘 외에 **새로운 분묘를 설치하거나 합장·이장을 위해 범위를 확장하는 것은 허용되지 않는다**.
- 분묘가 일시적으로 멸실되어도 **유골이 존재하여 원상회복이 가능**하면 분묘기지권은 존속한다.

제5절 지역권 ★★

1. 의의와 부종성

자기 토지(**요역지**)의 편익을 위하여 타인의 토지(**승역지**)를 이용하는 물권이다(제291조).

- **부종성** — 지역권은 요역지 소유권에 부종하여 이전하며, **요역지 소유권과 분리하여 양도하거나 다른 권리의 목적으로 하지 못한다**(제292조). 요역지 소유권이 이전되면 **별도의 등기 없이** 지역권도 함께 이전한다.
- **요역지는 1필의 토지 전부**여야 하며 **토지의 일부를 위한 지역권은 설정할 수 없다**. 반면 **승역지는 1필 토지의 일부**여도 된다.
- 요역지와 승역지가 **서로 인접할 필요는 없다**. 유상·무상 모두 가능하나, 대가는 등기사항이 아니다.

2. 불가분성 — 출제 1순위

조문	내용
제295조 제1항	공유자의 1인이 지역권을 취득하면 **다른 공유자도 이를 취득**한다
제293조 제1항	공유자의 1인은 **자기 지분만에 대하여 지역권을 소멸시키지 못한다**
제296조	요역지 공유자 1인에 의한 **소멸시효의 중단·정지**는 다른 공유자를 위하여 효력이 있다
제295조 제2항	취득시효의 중단은 **지역권을 행사하는 모든 공유자**에 대한 사유가 아니면 효력이 없다

3. 시효취득과 물권적 청구권

- **계속되고 표현된** 지역권에 한하여 시효취득할 수 있다(제294조). 통행지역권은 **요역지 소유자가 스스로 통로를 개설**하여야 하며, **타인이 개설한 통로를 이용한 것만으로는 시효취득할 수 없다**.
- **불법점유자**는 통행지역권을 시효취득하지 못한다.
- 통행지역권을 시효취득한 자는 **승역지 소유자가 입은 손해를 보상**하여야 한다.
- 지역권은 점유를 수반하지 않으므로 **반환청구권은 인정되지 않고**, **방해제거·방해예방청구권만** 인정된다(제301조).
- 지역권은 **20년간 행사하지 않으면 소멸시효**로 소멸한다.

제6절 전세권 ★★★

1. 성립

- **전세금의 지급은 전세권의 요소**이다. 다만 현실로 수수할 필요는 없고 **기존의 채권으로 전세금의 지급에 갈음할 수 있다**.
- 당사자의 합의가 있으면 **제3자 명의**의 전세권설정등기도 유효하다.
- **농경지는 전세권의 목적으로 하지 못한다**(제303조 제2항). 1필 토지·1동 건물의 일부에도 설정할 수 있다.

> **함정 주의**
> **채권담보 목적의 전세권** — ①사용·수익 권능을 배제하지 않았다면 당연히 유효하다. ②판례는 **목적물의 인도 없이** 채권담보 목적으로 설정된 전세권도 유효하다고 본다. ③그러나 임차보증금반환채권 담보 목적의 전세권으로서 **실제의 임대차와 양립할 수 없는 범위**에서는 **통정허위표시로 무효**이다.

2. 존속기간

구분	내용
최장기간	토지·건물 모두 **10년**. 초과 약정은 10년으로 단축. 갱신한 경우에도 갱신한 날부터 10년을 넘지 못함
최단기간	**건물**에 한하여 1년. **토지전세권에는 최단기간 제한이 없다**
기간의 정함이 없는 때	각 당사자가 언제든지 소멸통고 가능, 상대방이 통고받은 날부터 **6월**이 경과하면 소멸
법정갱신	**건물**전세권에 한함. 만료 전 **6월부터 1월까지** 사이에 통지가 없으면 동일한 조건으로 갱신된 것으로 봄

함정 주의

건물전세권이 **법정갱신**되면 그 **존속기간은 정함이 없는 것으로 본다**(제312조 제4항). "1년" 또는 "2년으로 본다"는 지문은 틀린 것이다(2년은 주택임대차보호법상 묵시적 갱신). 법정갱신은 법률규정에 의한 물권변동이므로 **갱신등기 없이도 제3자에게 대항**할 수 있다.

3. 효력

- **유지·수선의무는 전세권자가 부담**한다(제309조). 따라서 **필요비상환청구권은 인정되지 않고, 유익비상환청구권만 인정**된다(제310조).
- **처분의 자유** — 전세권자는 설정자의 동의 없이 전세권을 양도·담보제공하거나 전전세·임대할 수 있다. 다만 **설정행위로 이를 금지할 수 있다**(제306조 단서). 금지특약은 등기하여야 제3자에게 대항할 수 있다.
- **전전세**(제308조) — 원전세권의 범위 내에서만 가능하고, 전전세권자는 원전세권의 존속기간이 남아 있는 동안에는 전세금반환 지체를 이유로 경매를 청구할 수 없다. 전전세한 전세권자는 **전전세하지 않았더라면 면할 수 있었던 불가항력으로 인한 손해**까지 책임진다.
- **제304조** — 건물전세권의 효력은 그 건물의 소유를 목적으로 한 **지상권·임차권에도 미친다**.
- **제305조** — 대지와 건물이 동일인 소유였다가 건물에만 전세권을 설정한 후 대지소유자가 변경된 경우, 대지소유자는 전세권설정자에 대하여 **지상권을 설정한 것으로 본다**.
- 전세권설정자는 전세권자가 **용법에 위반**하여 사용한 때 소멸청구를 할 수 있다(제311조).

4. 소멸과 전세금의 반환

- 전세권 목적물의 **소유권이 이전**되면 신소유자가 전세권설정자의 지위를 승계하므로, **전세금반환의무는 신소유자가 부담**한다. 전세권 양수인도 신소유자에게 반환을 청구하여야 한다.
- **동시이행** — 전세금반환의무와 목적물 인도 및 전세권설정등기 말소서류 교부의무는 동시이행관계이다(제317조). 따라서 목적물을 현실로 인도하지 않으면 경매를 청구할 수 없다.
- **경매청구권·우선변제권**(제303조·제318조) — 목적물의 **일부**에 대한 전세권자는 전부에 대하여 경매를 청구할 수는 없으나, **전부의 매각대금에서 우선변제를 받을 수는 있다**.
- **토지전세권자에게는 지상물매수청구권**이 인정되고, **건물전세권자는 설정자의 동의를 얻어 부속시킨 물건**에 대하여 부속물매수청구권을 가진다(제316조).
- 전세권을 목적으로 저당권이 설정된 경우, **존속기간 만료로 전세권이 소멸하면 저당권자는 전세권 자체에 대하여 저당권을 실행할 수 없고**, 전세금반환채권에 대하여 **물상대위(압류)**를 할 수 있을 뿐이다.

핵심 암기

전세금반환채권의 분리양도 — ①전세권만을 전세금반환채권과 분리하여 양도하는 것은 **불가**. ②존속기간 중 전세금반환채권만을 **확정적으로** 분리양도하는 것도 **불가**. ③다만 **전세권의 소멸을 정지조건**으로 하는 분리양도는 **가능**. ④전세권이 **소멸한 후**에는 전세금반환채권만의 양도가 **가능**.

제7절 지상권·지역권·전세권 종합 비교 ★★★

구분	지상권	지역권	전세권
목적물	토지	승역지(토지)	토지·건물(**농경지 제외**)
목적물의 일부	가능	승역지는 가능, 요역지는 불가	가능
대가의 요소성	지료 — **요소 아님**	대가 — **요소 아님**(등기사항 아님)	전세금 — **요소임**
최단기간	30년·15년·5년	없음	**건물만 1년**
최장기간	**제한 없음(영구 가능)**	없음	**10년**

구분	지상권	지역권	전세권
처분금지특약	**무효**	부종성상 분리처분 불가	**유효**(제306조 단서)
물권적 청구권	반환·방해제거·방해예방 모두	**반환청구권 없음**, 방해제거·예방만	반환·방해제거·방해예방 모두
소멸시효(20년)	대상 ○	대상 ○	최장 10년이라 문제되지 않음

경매·우선변제권	없음	없음	**있음**
비용상환청구권	필요비 ×	—	필요비 ×, **유익비** ○

두문자·암기법

"전세권만 3가지를 가진다" — ①전세금(요소) ②우선변제·경매권 ③유익비상환청구권. 반대로 **"지역권에만 없는 것"** — 반환청구권, 점유권능.

기출·모의 지문 OX

1. 지상권에 의하여 토지를 사용하면서 신축한 지상 건물이 멸실되면 지상권도 소멸한다. → X (존속기간이 남아 있는 한 건물이 멸실되어도 지상권은 소멸하지 않는다.)
2. 지상권설정 당시 지상물의 종류와 구조를 정하지 않은 경우, 존속기간은 15년이 된다. → O (제281조 제2항에 의해 제280조 제1항 제2호의 건물, 즉 15년으로 본다. "5년"으로 바꾼 지문은 틀림.)
3. 기존의 건물을 사용할 목적으로 설정된 지상권도 그 건물이 견고한 건물이면 30년의 최단존속기간이 적용된다. → X (기존 건물의 사용을 목적으로 하는 경우에는 최단존속기간 규정이 적용되지 않는다.)
4. 지상권의 존속기간을 영구무한으로 설정하는 것은 허용되지 않는다. → X (판례는 영구무한의 지상권 설정도 허용된다고 본다.)
5. 지상권자는 토지소유자가 명시적으로 반대하더라도 지상권을 제3자에게 양도할 수 있고, 이를 금지하는 특약은 무효이다. → O (제282조는 강행규정이다. 지상권을 목적으로 하는 저당권 설정을 금지하는 특약도 효력이 없다.)
6. 지상권은 지상건물과 분리하여 제3자에게 처분할 수 없다. → X (지상권은 지상물의 소유권에 부종하지 않으므로 분리처분이 가능하다.)
7. 지료에 관한 등기를 하지 않았더라도 토지소유자는 지상권 양수인에게 지료를 청구할 수 있다. → X (지료는 등기하여야 제3자에게 대항할 수 있으므로 양수인에게 청구할 수 없다.)
8. 지료 연체가 토지소유권 양도 전후에 걸쳐 통산 2년분에 이르면, 양수인은 곧바로 지상권의 소멸을 청구할 수 있다. → X (양수인에 대한 연체액이 2년분에 달하여야 소멸청구를 할 수 있다.)
9. 지상권이 저당권의 목적인 경우, 지료 연체를 이유로 한 소멸청구는 저당권자에게 통지하고 상당한 기간이 지나야 효력이 생긴다. → O (제288조.)
10. 담보지상권자는 토지를 무단점유하는 자에게 임료 상당의 손해배상을 청구할 수 있다. → X (스스로 사용·수익하지 않아 손해가 없으므로 불가. 다만 무단 건축물의 철거는 청구할 수 있다.)
11. 나대지에 저당권이 설정된 후 저당권자의 동의를 얻어 건물을 신축하였다면 법정지상권이 성립한다. → X (저당권 설정 당시 건물이 존재하지 않았으므로, 저당권자의 동의가 있어도 법정지상권은 성립하지 않는다.)
12. 관습법상 법정지상권자로부터 건물을 경매로 취득한 자는 등기 없이도 법정지상권을 취득한다. → O (경매는 제187조의 법률규정에 의한 물권변동이다. 반면 매매로 취득한 자는 지상권이전등기를 하여야 한다.)
13. 법정지상권이 성립한 건물을 매수하였으나 지상권이전등기를 하지 않은 자에 대하여, 토지소유자는 건물철거를 청구할 수 있다. → X (신의칙상 철거청구는 허용되지 않는다. 다만 토지 사용에 대한 부당이득의 반환은 청구할 수 있다.)
14. 「장사 등에 관한 법률」 시행 후에 설치된 분묘도 20년간 평온·공연하게 점유하면 분묘기지권을 시효취득할 수 있다. → X (같은 법 시행일 전에 설치된 분묘에 한하여 시효취득이 인정된다. 시효취득에 등기는 필요 없다.)
15. 분묘기지권을 시효취득한 자는 분묘기지권이 성립한 날부터 지료를 지급할 의무가 있다. → X (시효취득형은 토지소유자가 지료를 청구한 날부터 지급의무가 있다. 자기 토지에 분묘를 설치한 후 이장 특약 없이 토지를 양도한 경우라야 성립한 날부터이다.)
16. 요역지 공유자 중 1인이 지역권을 취득하면 다른 공유자도 이를 취득하지만, 공유자 1인은 자기 지분만에 대하여 지역권을 소멸시킬 수 없다. → O (지역권의 불가분성. 제293조·제295조.)
17. 지역권자는 승역지를 불법점유한 자에게 승역지의 반환을 청구할 수 있다. → X (지역권은 점유를 수반하지 않으므로 반환청구권은 없고 방해제거·방해예방청구권만 인정된다.)
18. 타인이 개설한 통로를 20년간 통행하였다면 통행지역권을 시효취득할 수 있다. → X (요역지 소유자가 스스로 통로를 개설하여야 하며, 불법점유자도 시효취득할 수 없다.)
19. 건물전세권이 법정갱신되면 그 존속기간은 1년으로 본다. → X (기간의 정함이 없는 것으로 본다. 따라서 각 당사자는 언제든 소멸통고를 할 수 있고 6월이 지나면 소멸한다. 법정갱신은 등기 없이 제3자에게 대항할 수 있다.)
20. 토지에 대한 전세권의 존속기간을 1년 미만으로 정한 약정은 무효이다. → X (최단기간 1년의 제한과 법정갱신은 모두 건물전세권에만 인정된다.)
21. 전세권자는 목적물의 현상유지·수선의무를 지므로 필요비의 상환을 청구할 수 없고, 유익비만 청구할 수 있다. → O (제309조·제310조.)
22. 전세권의 존속기간 중에 전세금반환채권만을 확정적으로 제3자에게 양도할 수 있다. → X (확정적 분리양도는 불가. 전세권 소멸을 정지조건으로 하는 양도나, 소멸 후의 양도는 가능하다.)
23. 토지 일부에 전세권을 가진 자는 전세금 반환이 지체되면 토지 전부에 대하여 경매를 청구할 수 있다. → X (일부 전세권자는 전부에 대한 경매청구는 할 수 없으나, 매각대금에서 우선변제는 받을 수 있다.)

24. 전세권 목적물의 소유권이 이전되면 신소유자가 전세권설정자의 지위를 승계하여 전세금반환의무를 부담한다. → O (따라서 전세권 양수인도 구 소유자가 아닌 신소유자에게 전세금 반환을 청구하여야 한다.)

※ 용익물권 단원은 ①지상권의 처분 자유와 2년 지료연체, ②법정지상권의 동일인 소유 판단시점, ③지역권의 불가분성, ④전세권의 존속기간·법정갱신·전세금반환채권 분리양도가 매년 반복 출제되는 핵심 논점이다.

제8장 담보물권

제1절 담보물권 총설 ★★

1. 담보물권의 의의와 종류

담보물권은 채권의 **우선변제 확보**를 목적으로 타인의 물건 위에 성립하는 제한물권으로, 성립원인에 따라 다음과 같이 나뉜다.

- **법정담보물권**: 유치권(제320조) — 법률요건을 갖추면 당사자의 설정계약 없이 **당연히 성립**한다.
- **약정담보물권**: 질권(제329조 이하), 저당권(제356조 이하) — 설정계약과 공시방법(질권은 인도, 저당권은 등기)을 갖추어야 성립한다.

2. 담보물권의 통유성(공통 성질)

1. **부종성**: 피담보채권이 변제·시효완성 기타 사유로 소멸하면 담보물권도 소멸한다(제369조).
2. **수반성**: 채권이 이전하면 담보물권도 함께 이전한다. 따라서 **저당권만 채권과 분리하여 양도하거나 다른 채권의 담보로 제공할 수 없다**(제361조).
3. **불가분성**: 채권 전부를 변제받을 때까지 목적물 전부에 권리를 행사할 수 있다. 세 담보물권 모두 인정.
4. **물상대위성**: 목적물의 멸실·훼손·공용징수로 설정자가 받을 금전 등에 효력이 미치는 성질. **질권·저당권에는 인정되나 유치권에는 인정되지 않는다**.

> **두문자·암기법**
> 통유성 네 가지는 **"부·수·불·물"**(부종성-수반성-불가분성-물상대위성). 이 중 **유치권에 없는 것은 "물"** 하나뿐이라고 외운다. 유치권은 "우선변제권 없음 → 물상대위 없음"이 한 묶음이다.

제2절 유치권 ★★★

1. 의의 및 법적 성질

타인의 물건 또는 유가증권을 점유한 자는 그 물건이나 유가증권에 관하여 생긴 채권이 **변제기에 있는 경우**에는 변제를 받을 때까지 그 물건 또는 유가증권을 유치할 권리가 있다(제320조 제1항). 다만 그 **점유가 불법행위로 인한 경우에는 적용하지 아니한다**(동조 제2항).

- 법정담보물권이나, **당사자의 유치권 배제특약은 유효**하다(강행규정 아님).
- 동산·부동산·유가증권 모두 목적물이 될 수 있다. 부동산 유치권도 등기 없이 성립한다.
- 독립성이 없는 정착물(토지의 구성부분)에는 별도의 유치권이 성립할 수 없다.

2. 성립요건

(1) 타인의 물건 또는 유가증권일 것

목적물은 **채권자 이외의 자의 소유**이면 족하므로 채무자의 소유일 필요는 없고 제3자 소유물이어도 된다. 그러나 **채권자 자신의 소유물에는 유치권이 성립하지 않는다**. 따라서 도급계약에서 신축건물의 소유권을 원시취득한 수급인은 그 건물에 대하여 공사대금채권을 위한 유치권을 행사할 수 없다.

(2) 채권과 목적물 사이의 견련관계

"그 물건에 관하여 생긴 채권"이어야 한다. 채권이 목적물 자체로부터 발생하였거나 목적물의 반환청구권과 동일한 법률관계에서 발생한 경우를 말한다.

견련성 인정(유치권 O)	견련성 부정(유치권 X)
공사대금채권(타인 소유 건물)	임차보증금반환채권
필요비·유익비 상환청구권	권리금반환채권
수리비채권, 목적물로 인한 손해배상채권	매매대금채권

임차인이 임대차와 관련하여 갖는 **보증금·권리금 채권**은 건물 자체에 관하여 생긴 채권이 아니므로 유치권을 행사할 수 없다는 것이 확립된 판례이다. 시험에서 가장 많이 출제되는 함정이다.

(3) 채권의 변제기 도래

변제기가 도래하지 않으면 유치권은 성립하지 않는다. 그러므로 **법원이 유익비에 관하여 상환기간을 허여한 때에는(제626조 제2항 단서) 변제기가 도래하지 않은 것이 되어 그 유익비채권으로는 유치권을 행사할 수 없다.**

(4) 적법한 점유의 계속

- 점유는 성립요건인 동시에 **존속요건**이다(제328조: 점유상실로 소멸).
- **직접점유·간접점유 모두 가능**하다. 다만 **채무자를 직접점유자로 하는 간접점유로는 유치권이 성립할 수 없다**(유치적 효력이 없기 때문).
- 불법행위로 점유를 개시한 자(불법점유자)에게는 유치권이 인정되지 않는다.
- 채권 발생 후에 점유를 취득한 경우에도 유치권은 성립한다(점유와 채권 발생의 선후는 불문).

함정 주의

- "채무자 소유여야 한다" → **X**. 타인 소유이면 족하다(제3자 소유 가능).
- "점유와 채권은 동시에 또는 점유가 먼저 있어야 한다" → **X**. 순서 불문.
- "임의로 지출한 유익비로는 유치권을 행사할 수 없다" → **X**. 임의지출이라도 유익비상환청구권이 인정되는 이상 유치권이 성립한다.
- 임차인이 **원상복구(원상회복) 특약**을 한 경우 → 비용상환청구권 포기의 특약으로 보아 **유익비 유치권 불가**.

3. 유치권의 효력

(1) 유치권자의 권리

- **유치적 효력(인도거절권)**: 채권 전부를 변제받을 때까지 목적물 전부를 유치할 수 있다(불가분성, 제321조).
- **경매권**: 변제를 받기 위하여 유치물을 경매할 수 있다(제322조 제1항). 그러나 **우선변제권은 없어** 배당에서는 일반채권자의 지위에 그친다(사실상 우선변제의 효과만 있음).
- **간이변제충당권**: 정당한 이유가 있는 때에는 감정인의 평가에 의하여 유치물로 직접 변제에 충당할 것을 **법원에 청구**할 수 있다(제322조 제2항).
- **과실수취권**: 유치물의 과실을 수취하여 다른 채권보다 먼저 그 채권의 변제에 충당할 수 있다(제323조).
- **비용상환청구권**: 필요비·유익비 모두 소유자에게 상환을 청구할 수 있다(제325조). 유익비는 법원이 상환기간을 허여할 수 있다.
- **보존에 필요한 사용권**: 소유자의 승낙 없이도 보존에 필요한 범위의 사용은 가능하다. 다만 **사용으로 얻은 이익은 부당이득으로 반환**하여야 한다.

(2) 유치권자의 의무

- **선량한 관리자의 주의의무**(제324조 제1항).
- 채무자(소유자)의 승낙 없이 유치물을 **사용·대여·담보제공**하지 못한다(동조 제2항, 보존행위 제외).
- 위반 시 채무자는 **유치권의 소멸을 청구**할 수 있다(동조 제3항). 소멸청구는 형성권이며, 소멸청구가 있어야 소멸한다.

핵심 암기

- 유치권에 **있는 것**: 점유(공시방법)·부종성·수반성·불가분성·경매권·간이변제충당권·과실수취권·비용상환청구권·보존사용권.
- 유치권에 **없는 것**: **우선변제권·물상대위·등기·유치권 자체에 기한 물권적 반환청구권**. 목적물을 빼앗기면 **점유권에 기한 반환청구권(제204조)**으로만 회수할 수 있고 1년의 제척기간 내에 행사하여야 한다.

4. 경매절차와 유치권(중요 판례)

사안	매수인(경락인)에 대한 효력
경매개시결정(압류) **전**에 성립한 유치권	대항 가능 → **인도거절 O** / 변제청구는 **불가**
경매개시결정(압류) **후**에 점유를 취득한 경우	대항 불가(압류의 처분금지효 저촉)
압류 전 점유 + 압류 후 채권 발생	대항 가능

- 유치권자가 소유자의 승낙 없이 유치물에 **거주·사용**한 경우: 소멸청구 사유가 되고, 차임 상당액의 **부당이득반환의무**를 진다.

- 유치권자가 승낙 없이 **임대**한 경우: 소멸청구 사유가 되며, 그 임차인은 **소유자에게 임차권으로 대항할 수 없다**.
- 유치권자가 제3자에게 **보관을 위탁**한 경우: 점유보조자·이행보조자를 통한 점유로서 유치권은 유지되고, 위탁받은 자도 소유자의 인도청구를 거절할 수 있다.
- 유치권의 행사는 **채권의 소멸시효 진행에 영향을 미치지 아니한다**(제326조). 즉 유치권을 행사하고 있어도 피담보채권의 시효는 계속 진행하므로 별도의 중단조치가 필요하다.

5. 유치권의 소멸

1. 물권 일반의 소멸사유(목적물 멸실·혼동·포기 등)
2. 담보물권 공통: **피담보채권의 소멸**(부종성)
3. 유치권 특유: **점유의 상실**(제328조), 의무위반에 따른 **소멸청구**(제324조 제3항), 채무자의 **상당한 담보제공에 의한 소멸청구**(제327조)

유치권과 동시이행의 항변권은 **병존**할 수 있다. 소송에서 유치권 항변이 받아들여지면 법원은 청구기각이 아니라 **상환이행판결(원고 일부승소)**을 한다.

제3절 저당권 ★★★

1. 의의와 성질

저당권자는 **채무자 또는 제3자가 점유를 이전하지 아니하고** 채무의 담보로 제공한 부동산에 대하여 다른 채권자보다 자기 채권의 **우선변제**를 받을 권리가 있다(제356조). 즉 저당권은 **점유를 수반하지 않는 비점유담보(등기로 공시)**라는 점에서 질권·유치권과 구별된다.

2. 저당권의 당사자

- **저당권자 = 채권자**: 원칙적으로 동일인이어야 한다(부종성). 다만 판례는 채권자·채무자·제3자 사이의 합의가 있고 채권이 실질적으로 제3자에게 귀속되었다고 볼 사정이 있으면 제3자 명의의 (근)저당권등기도 유효하다고 본다.
- **저당권설정자 ≠ 채무자여도 무방**: 타인의 채무를 위하여 자기 부동산에 저당권을 설정한 자를 **물상보증인**이라 하며, 채무 없는 책임만을 부담한다.
- **제3취득자**: 저당권이 설정된 부동산에 관하여 소유권·지상권·전세권을 취득한 자를 말한다.

3. 저당권의 목적과 피담보채권

- 목적: 부동산, 지상권, 전세권(제371조). **요역지와 분리된 지역권 단독으로는 저당권의 목적이 될 수 없다**.
- 피담보채권은 금전채권에 한하지 않으며 **장래의 채권**도 담보할 수 있다.
- 저당권은 담보한 채권과 **분리하여 양도하거나 다른 채권의 담보로 하지 못한다**(제361조).
- 피담보채권이 소멸하면 저당권도 소멸하므로(제369조), **채권이 소멸한 뒤에 저당권 이전의 부기등기를 받은 자는 저당권을 취득하지 못한다**.

4. 저당권의 효력이 미치는 목적물의 범위

(1) 부합물·종물 (제358조)

저당권의 효력은 저당부동산에 **부합된 물건과 종물**에 미친다. 다만 법률에 특별한 규정 또는 설정행위에 다른 약정이 있으면 그러하지 아니하다. **부합·종물이 된 시기가 저당권 설정의 전후인지는 묻지 않는다**.

판례는 건물에 대한 저당권의 효력이 그 건물의 소유를 위한 **지상권·임차권 등 종된 권리**에도 미친다고 본다.

(2) 과실 (제359조)

저당권의 효력은 저당부동산에 대한 **압류가 있은 후**에 저당권설정자가 그 부동산으로부터 수취한 과실 또는 수취할 수 있는 과실에 미친다. 따라서 **압류 전에 발생한 차임채권에는 저당권의 효력이 미치지 않는다**.

(3) 피담보채권의 범위 (제360조)

항목	담보 여부	비고
원본	O	당연히 담보
이자·위약금	O	**등기한 경우에 한하여** 효력
채무불이행으로 인한 손해배상(지연배상)	O	원본의 이행기일 경과 후 **1년분에 한함**

저당권의 실행비용	O	등기 불요
저당물의 하자로 인한 손해배상	X	질권(제334조)과 달리 제외

5. 물상대위 (제370조 → 제342조 준용)

- 저당물의 **멸실·훼손·공용징수**로 저당권설정자가 받을 금전 기타 물건(보험금청구권, 손실보상금청구권 등)에 저당권을 행사할 수 있다.
- 요건: 그 지급 또는 인도 **전에 압류**하여야 한다. 특정성 유지가 목적이므로 **반드시 저당권자 자신이 압류할 필요는 없고 제3자가 압류한 경우에도 물상대위가 가능하다**.
- 공익사업을 위한 **협의취득**에 따른 보상금에 대하여도 물상대위가 인정된다.
- 전세권을 목적으로 저당권을 취득한 자는 전세권이 기간만료로 소멸한 경우 전세금반환채권에 대하여 물상대위할 수 있다.
- 주의: **저당물의 매매대금이나 임료(차임)는 물상대위의 대상이 아니다**(멸실·훼손·공용징수가 아니므로).

6. 저당권의 실행과 일괄경매청구권

(1) 일괄경매청구권 (제365조)

토지를 목적으로 저당권을 설정한 후 그 설정자가 그 토지에 건물을 축조한 때에는 저당권자는 **토지와 건물을 일괄하여 경매**를 청구할 수 있다.

사례	일괄경매
저당권 설정 **당시 이미 건물이 존재**한 경우	X (법정지상권 문제)
설정 후 설정자가 신축하여 **현재도 설정자 소유**인 경우	O
설정자가 신축 후 **제3자에게 처분**한 경우	X
제3자가 축조한 건물을 **설정자가 취득하여 현재 소유**하는 경우	O

- 요건: (가) 저당권 설정 **후**의 축조, (나) **경매신청 당시 저당권설정자 소유**일 것.
- 일괄경매는 **권리이지 의무가 아니다**. 토지에 대해서만 경매를 신청하여도 무방하다.
- **건물의 매각대금에서는 우선변제를 받을 수 없다**(토지의 매각대금에서만 우선변제).

(2) 제3취득자의 보호

- **대위변제(제364조)**: 저당부동산에 대하여 소유권·지상권·전세권을 취득한 제3자는 저당권자에게 그 부동산으로 담보된 채권을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있다.
- **비용상환청구(제367조)**: 제3취득자가 그 부동산의 보존·개량을 위하여 지출한 **필요비·유익비**는 경매대가에서 우선상환받을 수 있다.
- 제3취득자는 경매절차에서 **매수인이 될 수 있다**.

함정 주의

- **후순위 저당권자가 목적 부동산의 소유권을 취득**하여도 그 저당권은 **혼동으로 소멸하지 않는다**(선순위 저당권 실행 시 자기 권리를 보호할 필요가 있으므로).
- 무효인 저당권등기를 **다른 채권을 담보하기 위하여 유용**하는 것은, 등기부상 이해관계 있는 제3자가 생긴 후에는 허용되지 않는다.
- 피담보채권이 존재하지 않는 **무효인 저당권에 기한 경매**가 완료되어도 매수인은 소유권을 취득하지 못한다.
- 후순위 저당권자는 선순위 저당권자의 **동의 없이도 대위변제**할 수 있다.

7. 저당권과 다른 권리의 순위 — 경매 후 소멸 여부

권리	저당권보다 먼저 설정	저당권보다 나중에 설정
전세권	소멸하지 않음(단, 배당요구 시 소멸)	소멸
지상권·지역권	존속	소멸
유치권	인수(인도거절 가능)	인수. 단 압류 후 점유취득은 대항 불가

말소기준권리(저당권)보다 선순위인 용익물권은 매수인이 인수하고 후순위는 소멸한다. 甲 저당권 → 乙 전세권 순서라면 누가 경매를 신청하든 乙의 전세권은 소멸하고, 乙 전세권 → 甲 저당권 순서라면 乙의 전세권은 존속한다(다만 선순위 전세권자가 배당요구를 하면 소멸).

제4절 근저당권 ★★★

1. 의의와 성질 (제357조)

계속적 거래관계에서 발생하는 **불특정 다수의 채권**을 **채권최고액** 한도에서 담보하는 저당권이다. 확정 전에는 **피담보채권이 일시적으로 0원이 되어도 근저당권은 소멸하지 않는다**(부종성의 완화).

2. 등기사항과 채권최고액

- **채권최고액**: 반드시 등기하여야 하는 필요적 기재사항.
- **존속기간·결산기**: 임의적 기재사항(등기하지 않아도 무방).
- 채권최고액에는 **이자가 당연히 포함**되므로 이자를 별도로 등기할 필요가 없다.
- 근저당권에는 제360조 단서(지연배상 1년분 제한)가 **적용되지 않으므로**, 1년분을 초과하는 지연배상금이라도 **채권최고액 범위 내라면 전액 우선변제**를 받을 수 있다.
- **경매실행비용**은 채권최고액과 **별도로** 우선변제를 받는다.

3. 피담보채권의 확정시기

사유	확정시기
결산기 도래·존속기간 만료·기본계약 해지	그 시점
근저당권자 스스로 경매를 신청한 경우	**경매신청 시**
후순위권리자 등 타인이 경매를 신청한 경우	**매각대금(경락대금) 완납 시**

근저당권자가 스스로 경매를 신청하여 채권이 확정된 이상, 그 후 **경매신청이 취하되더라도 확정의 효과는 번복되지 않는다**.

4. 확정 후의 법률관계 — 말소청구의 요건

청구권자	변제하여야 할 금액
채무자 본인	**채권 전액**(최고액 초과분 포함)
물상보증인·제3취득자	**채권최고액**만 변제하면 말소청구 가능

- 근저당권의 목적물을 취득한 **제3취득자는 기본계약을 해지할 수 없다**(해지권은 기본계약의 당사자·설정자에게 있음).

> **핵심 암기**
> 근저당 3점 세트: ① **최고액 등기 필수**, ② **지연배상 1년분 제한 없음**(최고액 내 전액), ③ **실행비용은 최고액 별도**. 그리고 확정시기는 "**내가 신청하면 신청 시, 남이 신청하면 완납 시**"로 외운다.

제5절 공동저당 ★★

1. 의의

동일한 채권의 담보로 **수 개의 부동산**에 저당권을 설정한 경우이다(제368조). 각 부동산이 채권 전부를 담보하므로(불가분성) 저당권자는 어느 부동산에서든 전액 만족을 받을 수 있으나, 후순위저당권자 보호를 위하여 다음의 조정 규정을 둔다.

2. 동시배당 — 안분주의 (제368조 제1항)

동시에 배당하는 때에는 **각 부동산의 경매대가에 비례하여** 채권의 분담을 정한다.

3. 이시배당 — 후순위자의 대위 (제368조 제2항)

일부 부동산만 먼저 경매된 경우 공동저당권자는 그 대가에서 **채권 전부의 변제**를 받을 수 있다. 이때 그 부동산의 **차순위저당권자**는, 공동저당권자가 동시배당이었다면 다른 부동산에서 변제받을 수 있었던 금액의 한도에서 **선순위 공동저당권자를 대위하여 그 저당권을 행사**할 수 있다.

계산 공식·예제

[문제] 채권자 甲은 채무자 乙에 대한 **9억원**의 채권을 담보하기 위하여 乙 소유 X토지(경매대가 **8억원**)와 **물상보증인 소유** Y건물(경매대가 **4억원**)에 1순위 공동저당권을 설정하였다. 두 부동산이 동시에 경매되어 동시배당하는 경우, 甲이 **Y건물의 매각대금에서 우선변제받는 금액**은?

[공식] 각 부동산의 분담액 = 피담보채권액 × (해당 부동산 경매대가 ÷ 전체 경매대가의 합)

1. 전체 경매대가 = 8억 + 4억 = **12억원**
2. 분담비율 = X : Y = 8억 : 4억 = **2 : 1**
3. X토지 분담액 = 9억 × (8억/12억) = **6억원**
4. Y건물 분담액 = 9억 × (4억/12억) = **3억원**
5. 따라서 甲이 Y건물 대금에서 우선변제받는 금액은 **3억원**, Y건물의 남은 1억원은 후순위자가 없다면 물상보증인에게 귀속된다.

[정답] 3억원

심화: 판례는 공동저당 목적물 중 일부가 **물상보증인 소유**인 경우 물상보증인의 변제자대위(제481조·제482조)를 보호하기 위하여 채무자 소유 부동산의 대가에서 먼저 배당하여야 한다는 취지로 판시한 바 있다. 다만 시험의 계산문제는 위와 같이 **제368조 제1항의 안분기준**으로 출제된다.

제6절 질권 — 보충(강의자료 외) ★

1. 동산질권

채권자가 채권의 담보로 채무자 또는 제3자(물상보증인)로부터 받은 **동산**을 점유하고, 그 동산에 대하여 다른 채권자보다 자기 채권의 **우선변제**를 받을 수 있는 약정담보물권이다(제329조).

- **성립**: 설정계약 + **목적물의 인도**(공시방법). **점유개정에 의한 질권설정은 인정되지 않는다**(제332조: 질권자는 설정자로 하여금 질물을 점유하게 하지 못함).
- **유치적 효력 + 우선변제적 효력**을 모두 가진다는 점이 유치권·저당권과 구별되는 특징이다.
- **유질계약의 금지**(제339조): 변제기 전의 계약으로 질물의 소유권을 질권자에게 이전하거나 법정 방법 외로 처분하기로 하는 약정은 무효이다(상행위로 생긴 채무 담보의 경우에는 상법상 예외로 허용된다).
- **물상대위**가 인정되며(제342조), 이 규정이 저당권에 준용된다(제370조).

2. 권리질권

재산권을 목적으로 하는 질권이다(제345조). 채권·주식·지식재산권 등이 대상이며, 부동산의 사용·수익을 목적으로 하는 권리는 질권의 목적이 될 수 없다. 채권질권의 대항요건은 제3채무자에 대한 통지 또는 승낙이다.

3. 저당권과의 차이

- **목적물**: 질권은 동산·권리 / 저당권은 부동산·지상권·전세권.
- **공시방법**: 질권은 인도(점유) / 저당권은 등기.
- **점유이전**: 질권은 필수 / 저당권은 **점유를 이전하지 않는다**.

공인중개사 시험에서 질권은 담보물권의 분류·비교 차원에서만 출제되는 편이다. 존속기간·절차 등 숫자와 기간이 관련된 사항은 개정 가능성이 있으므로 **최신 법령 확인**이 필요하다.

제7절 유치권·질권·저당권 종합비교 ★★★

구분	유치권	질권(동산)	저당권
발생원인	법정담보물권	약정담보물권	약정담보물권

목적물	동산·부동산·유가증권	동산·재산권	부동산·지상권·전세권
공시방법	**점유**	**점유(인도)**	**등기**
부종성	O	O	O
수반성	O	O	O (분리양도 금지)
불가분성	O	O	O
물상대위성	X	O	O
우선변제권	X	O	O
유치적 효력	O	O	X
경매권	O	O	O
간이변제충당	O	O	X
과실수취권	O	O	압류 후에만

두문자·암기법

- **"유치권은 점·경은 되고 우·물은 안 된다"** — 점유로 공시하고 경매권은 있으나, 우선변제권과 물상대위는 없다.
- **"질권은 다 되고, 저당권은 유치적 효력만 없다"** — 질권은 유치적 효력과 우선변제권을 겸유하는 유일한 담보물권이다.

기출·모의 지문 OX

1. 유치권은 법정담보물권이므로 당사자 사이의 유치권 배제특약은 무효이다. → X (배제특약은 유효하다. 유치권 규정은 강행규정이 아니다)
2. 건물신축공사를 도급받은 수급인이 그 건물의 소유권을 원시취득한 경우, 공사대금채권을 위하여 그 건물에 유치권을 행사할 수 있다. → X (유치권의 목적물은 타인의 물건이어야 하며, 자기 소유물에는 성립하지 않는다)
3. 임차인은 임차보증금반환채권이나 권리금반환채권을 담보하기 위하여 임차건물에 유치권을 행사할 수 없다. → O (건물에 관하여 생긴 채권이 아니어서 견련성이 부정된다)
4. 채무자를 직접점유자로 하여 채권자가 간접점유하는 경우에도 유치권이 성립한다. → X (간접점유에 의한 유치권은 가능하나, 채무자를 직접점유자로 하는 간접점유로는 성립하지 않는다)
5. 법원이 유익비에 관하여 상당한 상환기간을 허여한 경우, 임차인은 그 유익비채권으로 유치권을 행사할 수 없다. → O (변제기 미도래로 되어 유치권이 성립·존속할 수 없다)
6. 임차인이 임대차 종료 시 건물을 원상복구하기로 약정한 경우에도 유익비를 이유로 유치권을 행사할 수 있다. → X (비용상환청구권 포기 특약으로 보아 유치권이 인정되지 않는다)
7. 유치물이 화재로 소실된 경우 유치권자는 소유자가 받을 화재보험금청구권에 대하여 물상대위권을 행사할 수 있다. → X (유치권에는 우선변제권이 없으므로 물상대위도 인정되지 않는다)
8. 경매개시결정 전에 유치권을 취득한 자는 매수인에게 목적물의 인도를 거절할 수 있으나, 매수인에게 피담보채권의 변제를 청구할 수는 없다. → O (인도거절권만 있을 뿐 매수인이 채무를 인수하는 것은 아니다)
9. 유치권의 행사는 피담보채권의 소멸시효 진행에 영향을 미치지 아니한다. → O (제326조. 유치권을 행사해도 시효는 계속 진행한다)
10. 저당권의 효력은 저당권설정 후에 저당부동산에 부합된 물건에는 미치지 않는다. → X (부합·종물은 설정의 전후를 불문하고 저당권의 효력이 미친다)
11. 저당부동산에 대한 압류 전에 발생한 차임채권에도 저당권의 효력이 미친다. → X (제359조. 과실에는 압류 후의 것에만 효력이 미친다)
12. 저당권으로 담보되는 이자와 위약금은 등기한 경우에 한하여 우선변제를 받을 수 있다. → O (제360조. 지연배상은 원본 이행기일 경과 후 1년분에 한한다)
13. 물상대위를 하려면 반드시 저당권자 자신이 보상금의 지급 전에 압류하여야 한다. → X (지급 전 압류는 필요하나 제3자가 압류한 경우에도 물상대위가 가능하다)
14. 저당권설정 당시 이미 그 토지 위에 건물이 존재한 경우에도 저당권자는 일괄경매를 청구할 수 있다. → X (제365조는 설정 후 설정자가 축조한 건물에 적용된다)
15. 일괄경매를 한 경우 저당권자는 건물의 매각대금에서도 우선변제를 받을 수 있다. → X (우선변제는 토지의 매각대금에서만 받을 수 있다)
16. 근저당권의 피담보채권이 일시적으로 존재하지 않게 되어도 근저당권은 소멸하지 않는다. → O (부종성이 완화되어 확정 전에는 존속한다)
17. 후순위권리자가 경매를 신청한 경우 선순위 근저당권의 피담보채권은 경매신청 시에 확정된다. → X (타인이 신청한 경우에는 매각대금 완납 시에 확정된다)
18. 채권최고액을 초과하는 채무를 부담하는 경우, 물상보증인이나 제3취득자는 채권최고액만 변제하고 근저당권의 말소를 청구할 수 있다. → O (채무자 본인은 채권 전액을 변제하여야 말소를 청구할 수 있다)

제9장 계약법 총론

제1절 계약의 의의와 종류 ★★

1. 계약의 의의

계약은 **서로 대립하는 의사표시의 합치**로 성립하는 법률행위이다. **본질적·주요 내용**에 관하여 객관적·주관적 합치가 있어야 하며, 합치가 없으면 **불합의로서 계약은 성립하지 않는다**.

- **객관적 합치**: 의사표시의 내용이 일치할 것 / **주관적 합치**: 상대방이 누구인가에 관하여 일치할 것.
- **의식적 불합의**와 **무의식적 불합의**(숨은 불합의) 모두 계약 불성립의 문제이다.

함정 주의

무의식적 불합의는 계약이 성립하지 않는 문제이므로, 성립한 계약을 전제로 하는 **착오에 의한 취소(제109조)의 문제가 아니다**. "숨은 불합의가 있으면 착오를 이유로 취소할 수 있다" → 틀린 지문.

2. 계약의 종류

(1) 쌍무계약과 편무계약

당사자 쌍방이 **서로 대가적 의미의 채무**를 부담하면 쌍무계약이다. **동시이행의 항변권(제536조)과 위험부담(제537조·제538조)은 오직 쌍무계약에서만** 문제된다.

(2) 유상계약과 무상계약

계약의 성립부터 이행까지 **대가적 출연**이 있는지에 따른 구별이다. **쌍무계약은 언제나 유상계약이지만, 유상계약이 언제나 쌍무계약인 것은 아니다**(현상광고). 유상계약에는 매매의 규정이 준용되므로 **임대차·교환에도 매도인의 담보책임 규정이 준용**된다.

(3) 낙성계약과 요물계약

합의만으로 성립하면 낙성계약, **물건의 인도 등 급부의 실행**까지 있어야 성립하면 요물계약이다.

계약	쌍무·편무	유상·무상	낙성·요물
매매·교환·임대차	쌍무	유상	낙성
증여·사용대차	편무	무상	낙성
현상광고	편무	**유상**	**요물**
계약금계약(종된 계약)	편무	-	**요물**

두문자·암기법

"현·계 = 요물" — 현상광고, 계약금계약은 요물계약. **"쌍무는 무조건 유상, 유상은 쌍무가 아닐 수 있다(현상광고)". 위험부담·동시이행 = 쌍무계약(매·교·임)**.

제2절 계약의 성립 ★★

1. 청약

청약은 승낙만 있으면 곧바로 계약을 성립시키는 **구체적·확정적 의사표시**이다. 반면 **청약의 유인**은 상대방에게 청약을 하게 하려는 준비행위에 불과하다.

- 청약자는 **특정인일 필요가 있으나**, 상대방은 **불특정 다수인이어도 무방**하다(자판기 설치, 광고에 의한 청약).
- 청약은 **도달한 때 효력이 발생**하며(제111조), 도달하여 효력이 생긴 뒤에는 **이를 철회하지 못한다**(제527조, 청약의 구속력).
- 청약자가 청약 발송 후 **사망하거나 제한능력자가 되어도** 청약의 효력에는 영향이 없다(제111조 제2항).
- **승낙기간을 정하지 않은 청약도 유효**하며, 상당한 기간 내에 승낙의 통지를 받지 못하면 효력을 잃는다(제529조).

- "일정 기간 내에 **이의를 하지 아니하면 승낙한 것으로 본다**"는 청약은 상대방을 구속할 수 없으므로 **원칙적으로 효력이 없다**.

아파트 **분양광고**, 상품목록의 배포, 구인광고 등은 원칙적으로 **청약의 유인**이다.

2. 승낙

- 승낙은 **특정한 청약자에 대하여** 하여야 한다. 따라서 **불특정 다수인에 대한 승낙은 불가능**하고, **제3자에게 한 승낙은 승낙으로서 효력이 없다**.
- 승낙기간 내에 도달하지 않으면 청약은 효력을 잃고 계약은 성립하지 않는다.
- **연착된 승낙**은 청약자가 **새로운 청약으로 볼 수 있다**(제530조). 원래의 청약자가 이에 승낙하면 계약이 성립한다.
- 보통 기간 내에 도달할 수 있었던 발송임이 명백한데 청약자가 **지체 없이 연착의 통지를 하지 않으면** 연착되지 않은 것으로 보아 **계약이 성립**한다(제528조).
- **조건을 붙이거나 변경을 가한 승낙**은 청약의 거절과 동시에 **새로운 청약을 한 것으로 본다**(제534조).

3. 계약의 성립시기

유형	성립시기	근거
대화자 간	승낙의 의사표시가 **도달한 때**	제111조
격지자 간	승낙의 통지를 **발송한 때**	제531조
교차청약	양 청약이 **모두 도달한 때**	제533조
의사실현	승낙의 의사표시로 인정되는 **사실이 있는 때**	제532조

함정 주의
격지자 간 계약은 **발신주의**이지만, 이는 승낙이 승낙기간 내에 도달할 것을 전제로 한다. 따라서 **승낙을 발송하였으나 분실되어 도달하지 않으면 계약은 성립하지 않는다**. 교차청약은 "먼저 도달한 때"가 아니라 **나중의 청약이 도달한 때** 성립한다.

제3절 약관에 의한 계약 ★

- **구속력의 근거**는 법규범이어서가 아니라 **당사자가 계약내용으로 하기로 합의하였기 때문**이다(판례).
- **명시·설명의무** 위반 조항은 **사업자가 계약내용으로 주장할 수 없다**. 반면 고객은 그 조항의 적용을 주장할 수 있다(상대적 효력).
- 거래상 일반적·공통적이어서 **충분히 예상할 수 있었던 사항**이나 **법령에 정하여진 것을 되풀이한 사항**은 설명의무가 면제·완화된다.
- **작성자 불이익의 원칙**: 뜻이 명백하지 않으면 **작성자에게 불리하게** 해석한다. 다만 조항이 일의적으로 명백하면 적용되지 않는다.
- **개별약정 우선**: **특약사항이 약관에 우선**한다.
- **일부무효의 법리**: 일부 조항이 무효여도 나머지는 유효함이 원칙이고, 나머지만으로 계약목적 달성이 불가능하거나 일방에게 부당하게 불리한 때에만 전부 무효가 된다.

제4절 계약체결상의 과실책임 ★

목적이 **원시적·객관적·전부 불능**인 계약은 무효이나, 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 자는 상대방이 그 계약의 유효를 믿었음으로 인하여 받은 손해를 배상하여야 한다(제535조).

- 요건: **원시적 불능**으로 계약이 무효일 것 + 배상의무자의 **악의·과실** + 상대방의 **선의·무과실**.
- 배상범위: **신뢰이익**의 배상이며, 이행이익을 넘지 못한다.

함정 주의
후발적 불능은 계약체결상 과실책임의 문제가 아니라 **위험부담 또는 채무불이행(해제·손해배상)**의 문제이다. 수량부족(담보책임)·계약교섭의 부당파기(불법행위책임)도 제535조의 적용대상이 아니다.

제5절 동시이행의 항변권 ★★★

1. 요건과 효과

1. **하나의 쌍무계약**에서 발생한 대가적 채무가 존재할 것.
2. **상대방의 채무가 변제기에 있을 것**(∴ 선이행의무자는 원칙적으로 항변권이 없다).
3. 상대방이 **이행 또는 이행제공 없이** 이행을 청구할 것.

- **이행지체 저지**: 항변권이 존재하면 **원용하지 않아도 이행지체책임이 발생하지 않는다**(존재효과설·판례).
- **상계 금지**: 항변권이 붙은 채권을 자동채권으로 상계하지 못한다.
- **소송상 효과**: 피고가 원용한 때에만 법원이 고려하여 **상환이행판결(원고 일부승소)**을 한다.
- **불안의 항변권**(제536조 제2항): 선이행의무자도 상대방의 이행이 곤란할 현저한 사유가 있으면 이행을 거절할 수 있다.

2. 동시이행관계 인정·부정 사례 정리

구분	사례	결론
변제·담보	채무의 변제 ↔ 영수증 교부, 채권증서·어음·수표 반환, 저당권설정등기 말소	**인정**
임대차	임대인의 보증금반환 ↔ 임차인의 목적물반환	**인정**
매매	토지거래허가 협력의무 ↔ 대금지급의무	**인정**
매매	가압류등기 말소를 포함한 소유권이전등기의무 ↔ 대금지급의무	**인정**
무효·해제	매매 무효·취소 시 상호 부당이득반환의무, 해제 시 원상회복의무	**인정**
당사자 변경	채권양도·전부명령으로 당사자가 바뀐 경우	**인정(유지)**
채무 변형	기존 채무가 손해배상채무로 변경된 경우	**인정(유지)**
제공 중단	수령지체가 있었으나 그 후 이행제공이 계속되지 않은 경우	**인정(부활)**
선이행	선이행의무 불이행 중 상대방 채무의 변제기가 도래한 경우	**인정(전환)**
부수적 채무	부수적 채무 ↔ 주된 급부의무	부정
별개 약정	별개의 약정에 기하여 발생한 채무	부정
경매 무효	경락인의 등기말소의무 ↔ 근저당권자의 배당금반환의무	부정
권리금	권리금 회수 방해로 인한 손해배상 ↔ 임차목적물 반환	부정

핵심 암기

이행제공은 계속되어야 한다. 한 번 이행을 제공하여 상대방을 수령지체에 빠뜨렸더라도 **그 제공을 계속하지 않으면 상대방의 동시이행항변권은 다시 살아난다**. "일단 제공했으므로 상대방은 더 이상 항변할 수 없다" → 틀린 지문.
선이행의무의 전환. 중도금을 지급하지 않은 채 잔금기일이 도래하면, 그때부터 중도금·잔금 지급의무와 소유권이전등기의무는 **동시이행관계로 전환**된다(판례).

함정 주의

임차권등기명령에 의하여 경료된 임차권등기의 말소의무와 보증금반환의무는 **동시이행관계가 아니며, 임대인의 보증금반환의무가 먼저 이행되어야 한다**(판례). 임차인의 목적물반환의무와 동시이행관계인 것과 구별할 것.

제6절 위험부담 ★★

쌍무계약에서 **쌍방의 책임 없는 사유**로 일방의 채무가 **후발적으로 불능**이 된 경우 그 대가위험을 누가 부담하는가의 문제이다.

- **원칙 - 채무자위험부담주의(제537조)**: 채무자는 상대방의 이행을 청구하지 못하고, 이미 받은 급부는 부당이득으로 반환한다.
- **예외 - 채권자위험부담(제538조)**: ① 채권자의 귀책사유로 불능이 된 때, ② 채권자의 **수령지체 중** 쌍방 무귀책으로 불능이 된 때에는 채무자가 **반대급부를 청구할 수 있다**. 이때 채무자는 채무를 면함으로써 얻은 이익을 상환하여야 한다.

- 위험부담 규정은 **임의규정**이므로 당사자의 특약으로 달리 정할 수 있다.

甲(매도인)이 乙(매수인)에게 부동산을 매도한 후 목적물이 멸실된 경우

멸실 원인	법률관계	甲의 대금청구	乙의 해제
甲(채무자)의 귀책	위험부담 아님 · **채무불이행**	불가	**가능(+손해배상)**
쌍방 무귀책(자연재해)	제537조 **채무자위험부담**	**불가**	해제 불요(당연 소멸)
제3자의 귀책	채무자에게 귀책 없음 → 제537조	불가	해제 불요
乙(채권자)의 귀책	제538조 제1항 1문	**가능**	매도인은 해제 불가
乙의 수령지체 중 무귀책	제538조 제1항 2문	**가능**	-

핵심 암기

"채무자 잘못 = 해제·손배 / 아무 잘못 없음 = 채무자가 손해 / 채권자 잘못 = 채권자가 돈 낸다". 매수인의 과실로 목적물이 멸실되면 **매도인은 대금을 청구할 수 있을 뿐 계약을 해제할 수는 없다**(매도인에게 귀책사유가 없어 제546조의 해제권이 생기지 않음).

제7절 제3자를 위한 계약 ★★

1. 3면관계의 구조

- **기본관계(보상관계)**: 요약자 ↔ 낙약자. 제3자를 위한 계약의 내용 그 자체이다.
- **대가관계(출연관계)**: 요약자 ↔ 수익자. **계약의 내용이 아니다**. / **급부관계**: 낙약자 ↔ 수익자.
- 계약당사자는 **요약자와 낙약자**이며, **수익자는 계약당사자가 아니다**. 수익자는 계약 당시에 현존·특정되어 있을 필요가 없다(장래 태어날 자, 설립 중인 법인도 가능).

2. 효력

1. **수익의 의사표시**: 제3자의 권리는 **낙약자에 대하여** 수익의 의사를 표시한 때 생긴다(제539조 ②). 이는 권리발생요건일 뿐이므로 **제3자의 동의 없이도 계약은 성립**한다.
2. **변경권 제한**: 수익의 의사표시 후에는 당사자가 **임의로 제3자의 권리를 변경·소멸시키지 못한다**(제541조). 다만 낙약자의 채무불이행이 있으면 요약자는 해제할 수 있고, 제3자의 권리도 소멸한다.
3. **낙약자의 항변(제542조)**: **기본관계에 기한 항변**(무효·취소·해제, 동시이행)으로는 수익자에게 대항할 수 있으나, **대가관계에 기한 항변으로는 대항하지 못한다**.
4. **해제·취소권자**: 해제권·취소권은 계약당사자에게 있고 수익자에게는 **없다**(다만 수익자는 낙약자에게 손해배상은 청구할 수 있다).
5. **원상회복**: 해제 시 원상회복은 **계약당사자 사이에서만** 이루어지므로, **낙약자는 수익자가 아니라 요약자에게 반환을 청구**하여야 한다.

함정 주의

기본관계가 **통정허위표시로 무효**인 경우 수익자가 선의라면 낙약자는 그 무효로 대항할 수 없다(제108조 ②). **그 밖의 기본관계상 무효·취소·해제**로는 대항할 수 있다는 점과 구별할 것.

제8절 계약의 해제와 해지 ★★★

1. 법정해제권의 발생과 최고의 요부

사유	근거	최고 필요 여부
이행지체(보통의 채무)	제544조	**필요**
이행거절의 의사가 명백한 경우	제544조 단서	불요
정기행위의 이행지체	제545조	불요
이행불능(채무자 귀책)	제546조	불요

불완전이행(추완 가능 / 불가능)	판례	**필요** / 불요

- 이행불능을 이유로 해제할 때에는 **상대방의 이행제공이나 최고가 필요 없다**.
- 최고 시 **기간을 정하지 않았더라도 최고는 유효**하고, 상당한 기간이 경과한 때 해제권이 발생한다.
- **부수적 채무**의 불이행이나 목적물의 **가압류**만으로는 해제할 수 없다.
- 이행불능에 관하여 **스스로 귀책사유가 있는 자**는 해제권을 행사할 수 없다.

2. 해제권의 행사

- 해제는 상대방에 대한 **의사표시**로 하며(제543조), **일단 한 해제의 의사표시는 철회하지 못한다**.
- **불가분성(제547조)**: 당사자가 수인이면 해제·해지는 **전원으로부터 전원에 대하여** 하여야 하고, 1인의 해제권이 소멸하면 다른 자의 해제권도 소멸한다.
- **실권특약**(중도금 미지급 시 계약이 자동 실효된다는 특약)이 있으면 **해제의 의사표시 없이도** 계약이 소멸한다.

3. 해제의 효과

1. **소급적 소멸**: 계약은 처음부터 없었던 것으로 된다(직접효과설·판례).
2. **원상회복(제548조 ①)**: 성질은 **부당이득반환**이며, 선의·악의를 묻지 않고 받은 급부 전부를 원물로 반환한다.
3. **이자 가산(제548조 ②)**: 금전은 **받은 날로부터의 이자**를 가산한다. 손해배상이 아니라 **부당이득반환의 성질**이다.
4. 쌍방의 원상회복의무는 **동시이행관계**에 있다.
5. **손해배상(제551조)**: **해제와 손해배상을 함께 청구할 수 있고**, 해제하지 않고 손해배상만 청구할 수도 있다.

매도인은 해제로 소유권이 복귀한 자기 소유 물건에 유치권을 행사할 수 없다.

4. 해제와 제3자 보호(제548조 제1항 단서)

제3자란 해제된 계약의 법률효과를 기초로 **새로운 이해관계를 맺고 등기·인도 등 대항요건을 갖춘 자**를 말한다.

시기	선의	악의
해제 **전**에 등기 등을 갖춘 자	**보호 O**	**보호 O**
해제 **후** 말소등기 전에 등기를 갖춘 자	**보호 O**	보호 X

- **보호 O**: 매수인으로부터 소유권·저당권·가등기를 취득한 자, 가압류채권자, 매수인이 **등기를 마친 후 임차하여 대항요건을 갖춘 임차인**, 해제 전 소유권이전등기청구권 양수인.
- **보호 X**: 상속인·대리인, 일반채권자, 매수인이 **등기 없이 임대한 경우의 임차인**, 토지매매 해제 시 **그 지상 신축건물의 매수인**, 해제될 것을 알면서 가등기한 배신적 제3자.

> **두문자·암기법**
> **"전은 선악불문, 후는 선의만"** — 해제 전 등기한 제3자는 **선·악 불문 보호**, 해제 후 말소 전에 등기한 제3자는 **선의만 보호**. **"토지 해제 → 건물 매수인은 남남"**.

5. 법정해제·약정해제·합의해제의 비교

구분	법정해제	약정해제	합의해제(해제계약)
발생 근거	법률규정(채무불이행)	당사자의 해제권 유보 특약	해제에 관한 **새로운 계약**
성질	형성권 행사	형성권 행사(특약=계약)	**계약**
최고	원칙적으로 필요	불요	불요
손해배상	**인정**(제551조)	원칙적 부정	특약 없으면 부정
이자 가산	**인정**(받은 날부터)	인정	**특약 없으면 부정**

합의해제는 계약이므로 **명시적·묵시적으로 모두** 가능하고, 해제한 계약을 부활시키는 약정도 허용된다. 합의해제도 소급효가 있고 제3자의 권리를 해하지 못한다.

6. 해지

- 해지는 **계속적 계약**(임대차·고용·위임 등)을 **장래에 향하여** 소멸시키는 일방적 의사표시이다.
- 소급효가 없어 **원상회복의무가 발생하지 않고** 청산의무만 남으며, 손해배상청구에는 영향이 없다(제551조). **불가분성(제547조)**은 해지에도 적용된다.

기출·모의 지문 OX

1. 현상광고는 편무계약이면서 무상계약이다. → X (현상광고는 편무계약이지만 유상계약이다)
2. 아파트 분양광고는 그 자체로 청약에 해당한다. → X (원칙적으로 청약의 유인에 불과하다)
3. "일정 기간 내에 이의를 하지 않으면 승낙한 것으로 본다"는 내용의 청약은 상대방을 구속한다. → X (원칙적으로 효력이 없다)
4. 격지자 간의 계약에서 승낙을 발송하였으나 분실되어 도달하지 않은 경우에도 계약은 성립한다. → X (도달을 전제로 하므로 미도달 시 계약은 성립하지 않는다)
5. 일방이 이행을 제공하여 상대방이 수령지체에 빠진 후에는, 그 제공을 계속하지 않더라도 상대방은 동시이행의 항변권을 행사할 수 없다. → X (이행제공을 계속하지 않으면 항변권이 부활한다)
6. 선이행의무인 중도금을 지급하지 않은 상태에서 잔금지급기일이 도래한 경우, 그때부터 중도금·잔금지급의무와 소유권이전등기의무는 동시이행관계에 있다. → O (판례, 선이행의무의 동시이행관계 전환)
7. 근저당권 실행을 위한 경매가 무효인 경우, 경락인의 소유권이전등기 말소의무와 근저당권자의 배당금반환의무는 동시이행관계에 있다. → X (별개 당사자 사이의 의무이므로 동시이행관계가 아니다)
8. 매수인의 과실로 매매목적물이 멸실된 경우, 매도인은 이행불능을 이유로 계약을 해제할 수 있다. → X (제538조에 따라 대금지급을 청구할 수 있을 뿐이다)
9. 당사자 쌍방의 책임 없는 사유로 목적물이 멸실된 경우, 매도인은 매수인에게 대금지급을 청구할 수 없다. → O (제537조 채무자위험부담주의)
10. 제3자를 위한 계약에서 수익자가 수익의 의사를 표시한 후 낙약자의 채무불이행으로 요약자가 계약을 해제하면, 수익자의 권리도 소멸한다. → O (채무불이행이 있으면 해제가 가능하고 제3자의 권리도 소멸한다)
11. 제3자를 위한 계약이 해제된 경우, 낙약자는 이미 수익자에게 급부한 것의 반환을 수익자에게 청구할 수 있다. → X (원상회복은 계약당사자인 요약자에게 청구하여야 한다)
12. 이행을 최고하면서 상당한 기간을 정하지 않은 경우, 그 최고는 효력이 없다. → X (최고는 유효하고 상당한 기간이 경과하면 해제권이 발생한다)
13. 해제의 의사표시는 상대방의 동의가 있으면 철회할 수 있다. → X (해제의 의사표시는 철회하지 못한다)
14. 계약해제로 반환할 금전에 가산하는 이자는 손해배상에 해당한다. → X (부당이득반환의 성질을 가진다)
15. 합의해제의 경우 별도의 약정이 없으면 반환할 금전에 이자를 가산할 의무가 없다. → O (합의해제는 계약이므로 약정에 따른다)
16. 토지매매계약이 해제된 경우, 그 토지 위에 신축된 건물을 매수한 자는 해제로부터 보호되는 제3자이다. → X (해제된 계약의 목적물인 토지에 관하여 권리를 취득한 자가 아니다)
17. 해제 후 말소등기 전에 해제사실을 모르고 매매목적물을 가압류한 채권자는 보호되는 제3자이다. → O (해제 후의 제3자는 선의인 경우 보호된다)

제10장 매매·교환

1. 매매의 의의와 성립 ★★

1-1. 매매의 의의·법적 성질

매매는 당사자 일방이 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 그 대금을 지급할 것을 약정함으로써 효력이 생기는 계약이다(제563조).

- **법적 성질**: **낙성·쌍무·유상·불요식** 계약 — 4가지를 모두 갖춘 전형계약이다.
- 매도인의 재산권이전의무와 매수인의 대금지급의무는 **동시이행관계**에 있다.
- 타인의 권리도 매매의 목적으로 할 수 있고, 그 매매계약은 **유효**하다(제569조). 다만 매도인이 그 권리를 취득하여 이전하지 못하면 담보책임을 진다.

1-2. 매매의 일방예약(제564조)

- 매매의 예약은 다른 약정이 없으면 **일방예약**으로 추정된다.
- **예약완결권은 형성권**이다. 따라서 예약완결권자가 완결의 의사표시를 하면 **상대방의 승낙 없이도** 그 즉시 매매계약(본계약)이 성립한다.
- 행사기간을 **정한 경우**: 그 기간 내에 행사하여야 한다.
- 행사기간을 **정하지 않은 경우**: **예약이 성립한 날로부터 10년**의 제척기간 내에 행사하여야 한다.

> **함정 주의**
> 「예약완결권의 행사기간은 예약완결권을 행사할 수 있는 때로부터 10년」→ **X**. 기산점은 **예약이 성립한 날**이다. 또한 이는 소멸시효가 아니라 **제척기간**이므로 중단이 없고, 당사자의 주장이 없어도 법원이 직권으로 판단한다.

1-3. 매매계약의 비용(제566조)

- 매매계약에 관한 비용(계약서 작성비용, 감정비용 등)은 특약이 없으면 **당사자 쌍방이 균분하여 부담**한다.
  - 이와 구별할 것 — 변제비용(등기비용 등 이행에 드는 비용)은 원칙적으로 채무자(매도인) 부담이다.

2. 매매의 효력 — 과실의 귀속과 대금의 이자 ★★

2-1. 원칙(제587조)

구분	내용
목적물 **인도 전**의 과실	**매도인**에게 귀속(대금을 이미 받았더라도 인도 전이면 원칙은 매도인)
대금의 **이자**	매수인은 **목적물의 인도를 받은 날**로부터 대금의 이자를 지급
예외	대금지급에 **기한이 있는 때**에는 그 기한까지 이자지급의무 없음

2-2. 판례에 의한 수정

- 매매 목적물의 **인도 전**이라도 매수인이 **대금을 완납**하였다면, 그 이후에 발생한 과실은 **매수인**에게 귀속된다.
  - 대금을 완납한 이상 매수인이 사실상 목적물의 이익을 누려야 형평에 맞기 때문이다. 즉 「인도」와 「대금완납」 중 **먼저 이루어진 쪽**을 기준으로 과실귀속이 이전된다고 이해하면 된다.

> **핵심 암기**
> - 인도 X · 대금 X → 과실은 **매도인**, 매수인은 이자 지급의무 **없음**
> - 인도 O · 대금 X → 과실은 매수인, 매수인은 **인도받은 날부터 이자** 지급
> - 인도 X · 대금 완납 → 과실은 **매수인**(판례)

3. 계약금(해약금) ★★★

3-1. 계약금계약의 법적 성질

- **요물계약**이다(낙성계약 X). 계약금을 **현실적으로 지급(교부)한 때** 비로소 성립한다. 단순히 「계약금 1억 원을 지급하기로 한다」는 약정만으로는 계약금계약이 성립하지 않는다.
- **종된 계약**이다(주된 계약 X). 주된 계약인 매매계약에 부수한다.
- 따라서 **매매계약이 무효·취소되면 계약금계약도 무효**가 되고, 교부자는 부당이득으로 계약금의 반환을 청구할 수 있다.

> **두문자·암기법**
> 계약금계약 = **요·종**(**요**물계약 + **종**된 계약). 「요종」으로 외우고, 「낙성·주된계약」이라 쓰인 지문은 전부 X로 찍는다.

3-2. 계약금의 성질 — 해약금 추정

- 다른 약정이 없으면 계약금은 **해약금으로 추정**된다(제565조). 즉 증약금(계약 성립의 증거) 기능은 항상 갖지만, **위약금** 기능은 별도의 위약금 약정이 있어야만 인정된다.
- 위약금 약정이 있는 경우, 그 위약금은 원칙적으로 **손해배상액의 예정**으로 추정된다(위약벌 X). 위약벌로 인정되려면 **별도의 명백한 약정**이 필요하다.
- 계약이 **법정해제**(채무불이행으로 인한 해제)된 경우, **별도의 위약금 약정이 없는 한 계약금은 반환**되어야 한다. 계약금이 당연히 몰취되는 것이 아니다.
- 반대로 위약금 약정이 있고 매수인 乙의 귀책사유로 매도인 甲이 해제한 경우에는, 그 약정에 따라 乙이 지급한 계약금이 **甲에게 귀속(몰취)**될 수 있다.

> **함정 주의**
> 「계약금은 위약금으로 추정된다」→ **X**(해약금으로 추정). 「위약금은 위약벌로 추정된다」→ **X**(손해배상액의 예정으로 추정). 「매수인의 채무불이행으로 계약이 해제되면 위약금 약정이 없어도 계약금은 당연히 매도인에게 몰취된다」→ **X**(반환되어야 함).

3-3. 해약금에 의한 해제(제565조)

(1) 요건

구분	내용
주체·방법	교부자 = 계약금 **포기** / 수령자 = 계약금의 **배액 상환**
시기	**당사자의 일방이 이행에 착수할 때까지**
배액상환의 정도	**현실제공**으로 족하고 **공탁까지는 불요**(판례)
사유	채무불이행 등 **아무런 사유가 필요 없다**(임의해제)

제565조는 임의규정이므로, 당사자가 「계약금에 의한 해제권을 배제한다」고 특약하면 해약금 해제는 인정되지 않는다.

(2) 「이행의 착수」 판단 — 최다 출제 지점

사안	이행의 착수	해약금 해제
중도금이 지급된 후	O	**불가능**
매도인이 매매대금 청구소송을 제기한 후	O	**불가능**
토지거래허가구역에서 허가를 받은 것만으로	X	**가능**
계약금만 지급된 상태	X	가능

함정 주의

1. **「당사자의 일방」의 의미** — 해제하려는 자 자신이 이행에 착수하지 않았더라도, **상대방이 이미 이행에 착수했다면** 해제할 수 없다. 즉 「상대방이 이행에 착수할 때까지」로 읽어야 하고, 「자신이 이행에 착수할 때까지」로 바꿔놓은 지문은 X.
2. **계약금 일부만 지급된 경우** — 매도인이 해약금 해제를 하려면 실제 지급받은 금액이 아니라 **약정된 계약금 전액**을 기준으로 그 배액을 상환하여야 한다(판례). 예: 계약금 1억 약정, 1천만 원만 지급 → 매도인은 **2억 원**을 상환하여야 하며 2천만 원으로는 해제할 수 없다.
3. **계약금을 아직 수령하지 않은 경우** — 매도인은 배액을 상환할 대상 자체가 없으므로, 해제를 위해 **공탁은 필요 없다**. 이행의 제공(제공 후 상대방이 수령을 거절하면 제공한 것으로 충분)으로 족하다.
4. **토지거래허가** — 허가신청이나 허가를 받은 사정만으로는 이행의 착수가 아니므로, 허가 후에도 **해약금 해제는 여전히 가능**하다.

(3) 효과

- 계약은 소급하여 소멸하지만, **원상회복의무가 발생하지 않는다**(이행 착수 전이므로 반환할 급부가 없다).
- **손해배상청구권도 발생하지 않는다**. 채무불이행을 원인으로 한 해제가 아니라 법률이 인정한 임의해제이기 때문이다. 계약금의 포기·배액상환 자체가 정산의 전부이다.

핵심 암기

해약금 해제 = 원상회복 X, 손해배상 X. 반면 **법정해제(채무불이행) = 원상회복 O, 손해배상 O.** 이 대비가 그대로 지문이 된다.

4. 매도인의 담보책임 ★★★

4-1. 총설

- 담보책임은 **유효한 매매계약**을 전제로 매도인이 부담하는 **무과실책임**(법정책임)이다. 매도인의 고의·과실을 요하지 않는다.
- 매매 목적물에 관한 **법률관계 자체가 무효**인 경우(예: 처음부터 매도인에게 처분권이 전혀 없어 계약이 무효인 경우)에는 **담보책임이 아니라 계약 무효의 법리**가 적용되며, 담보책임은 인정되지 않는다.
- **담보책임 면제특약**도 유효하다. 다만 매도인이 **알면서 고지하지 아니한 사실**, 제3자에게 권리를 설정·양도한 행위에 대하여는 책임을 면하지 못한다(제584조).

4-2. 권리의 하자 — 매수인의 권리 비교표 ★★★

(1) 권리의 인정 여부(선의·악의 기준)

유형(조문)	계약해제권	손해배상청구권	대금감액청구권
전부 타인권리(569·570조)	**선의·악의 불문**	**선의만**	X
일부 타인권리(572조)	**선의만**(잔존부분만이면 매수하지 않았을 때)	**선의만**	**선의·악의 불문**
수량부족·일부멸실(574조)	**선의만**	**선의만**	**선의만**
제한물권(용익권 등)에 의한 제한(575조)	**선의만**(목적 달성 불능 시)	**선의만**	X
저당권·전세권의 실행(576조)	**선의·악의 불문**	**선의·악의 불문**	X

(2) 권리행사기간(제척기간)

유형	선의의 매수인	악의의 매수인
전부 타인권리(570조)	**제척기간 규정 없음**	
일부 타인권리(572조)	**사실을 안 날**로부터 1년	**계약한 날**로부터 1년
수량부족·일부멸실(574조)	사실을 안 날로부터 1년	권리 자체가 **없음**
제한물권에 의한 제한(575조)	사실을 안 날로부터 1년	권리 자체가 **없음**
저당권·전세권의 실행(576조)	**제척기간 규정 없음**	

물건의 하자(580·581조)	하자를 **안 날로부터 6개월**	권리 자체가 **없음**

두문자·암기법

- **「악의자도 해제되는 두 놈」 = 전부 타인권리 + 저당권·전세권 실행** → 이 둘은 **제척기간도 없다**. (악의 보호 O = 기간제한 X 로 묶어서 암기)
- **「악의자도 감액되는 하나」 = 일부 타인권리**. 대금감액청구권은 **일부 타인권리와 수량부족**에만 있고, 그중 악의자에게도 주는 것은 일부 타인권리뿐이다.
- **대금감액이 없는 셋** = 전부 타인권리(줄일 대금이 없음) · 제한물권 · 저당권 실행.
- 제척기간 숫자: 권리의 하자 = **1년**, 물건의 하자 = **6개월**.

(3) 유형별 요건·효과 정리

- **전부 타인권리(570조)**: 매도인이 타인의 권리를 취득하여 매수인에게 이전할 수 없는 때. 매수인은 선의·악의를 불문하고 해제할 수 있으나, **손해배상은 선의인 경우에만** 청구할 수 있다.
  - **매도인의 해제권(571조)**: 매도인이 선의인 경우(권리가 자기에게 속하지 않음을 몰랐던 경우) 매수인에게 손해를 배상하고 해제할 수 있다. 다만 **매수인이 악의**이면 매도인은 손해배상 없이 **이전 불능을 통지**하고 해제할 수 있다.
- **일부 타인권리(572조)**: 매수인은 선의·악의를 불문하고 **대금감액**을 청구할 수 있다. 잔존한 부분만이면 매수하지 아니하였을 때에 한하여 선의의 매수인만 전부 해제할 수 있고, 손해배상도 선의자만 가능하다.
- **수량부족·일부멸실(574조)**: **수량을 지정한 매매**에서 수량이 부족하거나 계약 당시 이미 일부가 멸실된 경우. 선의의 매수인만 대금감액·해제·손해배상을 모두 행사할 수 있고, **악의자는 아무런 권리가 없다**.
- **제한물권에 의한 제한(575조)**: 지상권·지역권·전세권·질권·유치권 등이 설정되어 있거나 지역권이 없는 등의 경우로서 **이로써 계약의 목적을 달성할 수 없는 때**에만 선의의 매수인이 해제할 수 있고, 그 밖에는 손해배상만 청구할 수 있다.
- **저당권·전세권의 실행(576조)**: 저당권·전세권의 행사로 매수인이 **소유권을 취득할 수 없거나 취득한 소유권을 잃은 때** 비로소 책임이 발생한다. 저당권의 존재는 등기부에 공시되어 있어 악의일 수밖에 없지만, 실행 여부는 매수인이 통제할 수 없으므로 **악의자도 해제권·손해배상청구권을 모두 가진다**.

함정 주의

저당권이 설정된 부동산을 **알면서** 매수한 자도 그 저당권이 실행되어 소유권을 잃으면 **해제와 손해배상이 모두 가능**하다. 「악의이므로 손해배상은 청구할 수 없다」는 지문은 X. 반대로 **전부 타인권리**에서는 악의자에게 해제권은 있어도 **손해배상청구권은 없다** — 이 둘을 바꿔놓는 지문이 가장 흔하다.

4-3. 물건의 하자에 대한 담보책임(580조·581조)

구분	특정물 매매(580조)	종류물 매매(581조)
요건	**선의·무과실**의 매수인	**선의·무과실**의 매수인
해제권	계약의 **목적을 달성할 수 없는** 경우에만	좌동
손해배상	O	O
완전물급부청구권	**X**	**O**(하자 없는 물건 청구)
제척기간	하자를 **안 날로부터 6개월**	좌동

- 물건의 하자는 **계약 당시**를 기준으로 존재하여야 하고, 매수인은 선의일 뿐 아니라 **알지 못한 데에 과실이 없어야** 한다(권리의 하자에서는 무과실까지 요구하지 않는 점과 구별).
- **경매의 목적물에 물건의 하자가 있더라도 담보책임은 인정되지 않는다**(제580조 제2항). 다만 **권리의 하자**(전부·일부 타인권리 등)에 대한 담보책임은 경매에도 적용될 수 있다.

4-4. 담보책임 관련 필수 판례

사안	해제권	손해배상
가등기가 되어 있다가 제3자 명의로 **본등기**가 경료되어 매수인이 소유권을 상실	**선의·악의 불문 O**	**선의·악의 불문 O**

가압류가 되어 있다가 **강제경매**로 매수인이 소유권을 상실	**선의·악의 불문 O**	**선의·악의 불문 O**

두 경우 모두 저당권·전세권의 실행(제576조)에 준하여 처리한다(576조 유추적용). 매수인이 등기부를 보고 가등기·가압류의 존재를 알고 있었더라도 결론은 같다.

- **법률적 제한과 물건의 하자**: 건축법·국토계획법 등 **법령상의 제한**으로 매매 목적 토지에 건물을 지을 수 없게 된 경우, 이는 **권리의 하자가 아니라 「물건의 하자」**에 해당한다(판례). 따라서 제580조가 적용되어 선의·무과실의 매수인이 안 날로부터 6개월 내에 권리를 행사하여야 한다.
- **성능 미달**: 매도인이 보증하거나 약속한 성능에 미달하는 경우에도 물건의 하자가 인정된다.
- **무효인 법률관계**: 매매 목적물에 관한 법률관계 자체가 무효인 경우에는 담보책임이 **부정**된다(담보책임은 유효한 계약을 전제로 하므로).

핵심 암기
「가등기→본등기」, 「가압류→강제경매」 = 저당권 실행과 같은 취급 = 악의자도 해제·손배 모두 O.
「법령상 제한으로 건축 불가」 = 물건의 하자(권리의 하자 X).
「경매」 = 물건의 하자담보책임 X, 권리의 하자담보책임 O.

5. 환매 ★★

5-1. 환매의 요건

- 환매는 매도인이 **매매계약과 동시에** 환매할 권리를 보류하는 특약이다(제590조). 매매계약 후 별도로 한 환매특약은 민법상의 환매가 아니라 **재매매의 예약**에 불과하다.
- **환매대금**: 원칙적으로 매수인이 지급한 **대금 및 매매비용**을 반환하여야 한다(특약으로 달리 정할 수 있다).
- **환매등기**: 부동산의 경우 매매등기와 동시에 환매권의 보류를 등기하면 **제3자에 대하여 대항**할 수 있다(제592조).

5-2. 환매기간(제591조) — 숫자 암기

구분	부동산	동산
최장기간	**5년**	**3년**
약정기간이 이를 넘는 경우	**5년으로 단축**	**3년으로 단축**
기간을 정하지 않은 경우	5년	3년
기간을 정한 경우의 연장	**다시 연장하지 못한다**	

5-3. 환매권의 성질과 행사

- 환매권은 **형성권**이다. 매도인이 기간 내에 환매대금을 제공하고 환매의 의사표시를 하면 **매수인의 승낙 없이** 효력이 생긴다.
- 환매권은 재산권이므로 **양도·상속의 대상이 되고, 채권자대위권의 목적**도 될 수 있다.
- 매도인이 환매기간 내에 대금과 매매비용을 **제공하지 아니하면** 환매할 권리를 잃는다.

함정 주의
「환매특약은 매매계약과 동시에 할 필요가 없다」→ **X**(동시에 하여야 한다). 「환매기간을 정한 경우 당사자의 합의로 연장할 수 있다」→ **X**. 「환매권 행사에는 매수인의 승낙이 필요하다」→ **X**(형성권). 「환매권은 일신전속권이어서 양도·상속할 수 없다」→ **X**.

6. 교환 ★★

- **의의**: 당사자 쌍방이 **금전 이외의 재산권**을 상호 이전할 것을 약정함으로써 효력이 생기는 계약이다(제596조).
- **성질**: 매매와 같이 **낙성·쌍무·유상·불요식** 계약이며, **매매에 관한 규정이 준용**된다. 따라서 동시이행의 항변권·위험부담·담보책임이 모두 적용된다.
- **보충금**: 당사자 일방이 재산권 이전과 함께 금전(보충금)의 지급을 약정한 경우, 그 **보충금에 대하여는 매매대금에 관한 규정이 준용**된다(제597조). 보충금을 지급하지 않으면 채무불이행이 되어 상대방은 계약을 해제할 수 있다.

- **담보책임**: 교환 목적물에 하자가 있는 경우에도 매도인의 담보책임 규정이 준용되어 **당사자 쌍방이 서로 상대방에게 담보책임**을 진다.
- **판례**: 교환계약의 당사자가 목적물의 **시가를 묵비하거나 시가보다 높은 가액을 시가라고 고지**하였더라도, 특별한 사정이 없는 한 기망행위에 해당하지 않는다.

핵심 암기

교환은 「금전 이외의 재산권 **상호** 이전」. 한쪽이 금전만 주면 매매이고, **보충금**이 붙어도 여전히 교환이다. 교환에서는 **쌍방 모두가 매도인의 지위**에 서므로 담보책임도 쌍방이 진다.

7. 기출·모의 지문 OX ★★★

기출·모의 지문 OX

1. 매매의 일방예약에서 예약완결권의 행사기간을 정하지 않은 경우, 예약완결권은 예약이 성립한 날로부터 10년 내에 행사하여야 한다. → O
2. 예약완결권을 행사하더라도 상대방이 승낙하여야 비로소 매매계약이 성립한다. → X (예약완결권은 형성권이므로 일방적 의사표시만으로 매매계약이 성립한다.)
3. 특약이 없으면 매매계약에 관한 비용은 매도인이 전부 부담한다. → X (당사자 쌍방이 균분하여 부담한다 — 제566조.)
4. 목적물의 인도 전이라도 매수인이 대금을 완납하였다면 그 이후의 과실은 매수인에게 귀속된다. → O
5. 매수인은 목적물의 인도를 받지 않았더라도 매매계약을 체결한 날부터 대금의 이자를 지급하여야 한다. → X (인도를 받은 날부터 이자를 지급하며, 대금지급에 기한이 있으면 그 기한까지는 이자지급의무도 없다 — 제587조.)
6. 계약금계약은 요물계약이므로 계약금을 현실적으로 지급한 때에 성립한다. → O
7. 매매계약이 무효이더라도 계약금계약은 그와 독립하여 유효하다. → X (계약금계약은 종된 계약이므로 주된 계약이 무효이면 함께 무효가 된다.)
8. 다른 약정이 없으면 계약금은 위약금으로 추정된다. → X (해약금으로 추정된다 — 제565조. 위약금이 되려면 별도의 위약금 약정이 필요하다.)
9. 위약금 약정이 있는 경우 그 위약금은 원칙적으로 위약벌로 추정된다. → X (손해배상액의 예정으로 추정된다. 위약벌로 보려면 명백한 별도 약정이 있어야 한다.)
10. 매수인의 채무불이행으로 매매계약이 법정해제된 경우, 위약금 약정이 없더라도 계약금은 당연히 매도인에게 몰취된다. → X (별도의 위약금 약정이 없는 한 계약금은 반환되어야 한다.)
11. 약정 계약금 1억 원 중 1천만 원만 지급된 상태에서 매도인이 해약금 해제를 하려면 2천만 원을 상환하면 된다. → X (실제 지급액이 아니라 약정 계약금 전액인 1억 원을 기준으로 그 배액인 2억 원을 상환하여야 한다.)
12. 매도인이 아직 계약금을 수령하지 않은 상태에서 해약금 해제를 하려면 반드시 배액을 공탁하여야 한다. → X (상환할 대상이 없으므로 공탁은 불요하고, 이행의 제공으로 족하다.)
13. 매수인이 중도금을 지급한 후에는 매도인은 계약금의 배액을 상환하고 계약을 해제할 수 없다. → O (이행의 착수가 있었으므로 제565조의 해제권이 소멸한다.)
14. 토지거래허가구역 내 토지에 관하여 허가를 받았다면, 그 사정만으로 이행의 착수가 있었다고 보아 해약금 해제를 할 수 없다. → X (허가신청이나 허가만으로는 이행의 착수가 아니므로 해약금 해제가 여전히 가능하다.)
15. 해약금에 의하여 계약이 해제된 경우 상대방은 채무불이행을 이유로 손해배상을 청구할 수 있다. → X (해약금 해제에서는 원상회복의무도 손해배상청구권도 발생하지 않는다.)
16. 타인의 권리를 매매의 목적으로 한 계약은 무효이다. → X (유효하며, 이전하지 못하면 매도인이 담보책임을 진다 — 제569조.)
17. 전부 타인권리의 매매에서 매수인이 악의이면 계약을 해제할 수 없다. → X (해제권은 선의·악의를 불문하고 인정된다. 다만 손해배상청구권은 선의의 매수인에게만 인정된다.)
18. 일부 타인권리의 매매에서 대금감액청구권은 선의의 매수인에게만 인정된다. → X (대금감액청구권은 선의·악의를 불문하고 인정된다. 해제권·손해배상청구권이 선의자에게만 인정된다.)
19. 일부 타인권리의 매매에서 악의의 매수인은 계약한 날로부터 1년 내에 권리를 행사하여야 한다. → O (선의자는 사실을 안 날로부터 1년이다.)
20. 수량을 지정한 매매에서 수량이 부족한 경우, 악의의 매수인도 대금감액을 청구할 수 있다. → X (수량부족·일부멸실에서는 선의의 매수인만 해제·손해배상·대금감액을 행사할 수 있고 악의자는 아무 권리가 없다.)
21. 매매목적물에 지상권이 설정되어 있어 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우, 악의의 매수인도 계약을 해제할 수 있다. → X (제575조의 제한물권에 의한 제한에서는 선의의 매수인만 해제·손해배상이 가능하다.)
22. 저당권이 설정된 사실을 알고 매수한 자도 그 저당권의 실행으로 소유권을 잃으면 계약을 해제하고 손해배상을 청구할 수 있다. → O (제576조는 선의·악의를 불문하며 제척기간 규정도 없다.)
23. 가등기가 경료된 부동산을 매수한 후 제3자 명의로 본등기가 되어 소유권을 상실한 경우, 악의의 매수인은 해제할 수 없다. → X (제576조를 유추적용하여 선의·악의를 불문하고 해제권과 손해배상청구권이 인정된다. 가압류 후 강제경매의 경우도 같다.)
24. 건축법상의 제한으로 매수한 토지에 건물을 지을 수 없게 된 경우, 이는 권리의 하자에 해당한다. → X (판례는 법률적 제한을 「물건의 하자」로 본다.)

25. 물건의 하자담보책임은 매수인이 선의이기만 하면 과실이 있어도 인정된다. → X (선의이고 알지 못한 데 과실이 없을 것, 즉 선의·무과실을 요구한다 — 제580조.)
26. 경매의 목적물에 물건의 하자가 있는 경우 매수인은 이를 이유로 담보책임을 물을 수 있다. → X (물건의 하자담보책임은 경매에 적용되지 않는다 — 제580조 제2항. 권리의 하자에 대한 담보책임은 적용될 수 있다.)
27. 매매 목적물에 관한 법률관계 자체가 무효인 경우에도 매수인은 담보책임을 물을 수 있다. → X (담보책임은 유효한 계약을 전제로 하므로 인정되지 않고, 무효의 법리가 적용된다.)
28. 환매특약은 매매계약과 동시에 하여야 하며, 매매계약 후에 한 환매특약은 민법상의 환매가 아니다. → O
29. 부동산의 환매기간을 7년으로 약정하면 그 약정은 무효가 되어 환매기간의 정함이 없는 것으로 된다. → X (약정기간이 5년을 넘는 때에는 5년으로 단축된다 — 제591조.)
30. 환매기간을 정한 때에도 당사자의 합의로 이를 연장할 수 있다. → X (환매기간을 정한 때에는 다시 이를 연장하지 못한다.)
31. 환매권은 양도하거나 상속할 수 없고 채권자대위권의 목적도 될 수 없다. → X (재산권이므로 양도·상속·대위행사가 모두 가능하다.)
32. 환매권을 행사하려면 매수인의 승낙이 있어야 한다. → X (환매권은 형성권이므로 상대방의 승낙이 필요 없다.)
33. 교환계약의 일방 당사자가 목적물의 시가를 묵비하거나 시가보다 높은 가액을 시가라고 고지한 것만으로는 기망행위가 되지 않는다. → O
34. 교환계약에서 보충금의 지급을 약정한 경우, 그 보충금에 대하여는 매매대금에 관한 규정이 준용된다. → O (제597조. 보충금 미지급은 채무불이행이 되어 해제사유가 된다.)

마무리 점검 3줄 — ① 계약금은 **요물·종된 계약**, **해약금 추정**, **상대방의 이행착수 전**까지, **약정 계약금 전액**의 배액. ② 담보책임에서 **악의자도 구제되는 것은 「전부 타인권리의 해제」와 「저당권·전세권 실행」(+가등기·가압류 유추)**, 이 둘만 제척기간이 없다. ③ 환매는 **동시특약·부동산 5년·연장 불가·형성권·등기하면 대항력**.

제11장 임대차(민법)

이 장은 민법 제618조~제654조의 **임대차 총칙**만 다룬다. 주택·상가건물임대차보호법은 별도 단원이며, 그 규정들은 모두 민법 임대차 원칙에 대한 **특례**이므로 여기서 원칙을 먼저 확정해 두어야 한다.

1. 임대차의 의의와 성립 — 보충(강의자료 외) ★

(1) 의의

임대차는 당사자 일방(임대인)이 상대방(임차인)에게 **목적물을 사용·수익하게 할 것**을 약정하고, 상대방이 이에 대하여 **차임을 지급할 것**을 약정함으로써 효력이 생기는 계약이다(제618조). 따라서 임대차는 **낙성·불요식·쌍무·유상계약**이다.

- **차임은 임대차의 본질적 요소**이다. 차임이 없으면 임대차가 아니라 사용대차이다. 차임은 금전에 한하지 않고 물건으로도 가능하다.
- 임대인이 반드시 **소유자일 필요는 없다**. 타인 소유 물건의 임대차도 채권계약으로서 유효하다.

(2) 처분권한 없는 자의 단기임대차(제619조·제620조)

목적물	최장기간	갱신 가능시기
식목·채염 또는 석조 등 견고한 건축을 목적으로 한 토지	10년	만료 전 1년 내
기타 토지	5년	만료 전 1년 내
건물 기타 공작물	3년	만료 전 3개월 내
동산	6개월	만료 전 1개월 내

두문자·암기법

단기임대차 **"십·오·삼·육"**(10년·5년·3년·6월), 갱신은 **"토1년·건3월·동1월"**.

2. 임대차의 존속기간과 갱신 ★

(1) 최장기간 제한의 폐지

과거 제651조는 임대차 존속기간을 20년으로 제한하였으나, 헌법재판소의 위헌결정을 거쳐 **2016년 민법 개정으로 제651조가 삭제**되었다. 따라서 현재 민법상 **최장기간 제한은 없고**, 판례도 특별한 사정이 없는 한 **영구무한의 임대차 약정도 유효**하다고 본다. 최단기간 보장(주택 2년·상가 1년)은 **특별법**의 영역이다.

(2) 기간의 약정이 없는 임대차 — 해지통고(제635조)

기간의 약정이 없으면 당사자는 **언제든지 해지통고**를 할 수 있고, 통고를 받은 날로부터 아래 기간이 경과하면 해지의 효력이 생긴다.

목적물	임대인이 해지통고	임차인이 해지통고
토지·건물 기타 공작물	**6개월**	**1개월**
동산	5일	5일

함정 주의

부동산에서 **임차인**이 해지통고한 경우는 **1개월**이다. 지문에서 **"3개월"**로 바꾸어 출제된 적이 있다. 6개월의 유예는 **임차인 보호**를 위한 것이므로 **임대인이 통고한 때**가 6개월이라고 기억한다.

(3) 묵시의 갱신(법정갱신, 제639조)

1. 기간 만료 후 **임차인이 사용·수익을 계속**하는데 임대인이 **상당한 기간 내에 이의하지 아니한 때**에는 전 임대차와 **동일한 조건**으로 다시 임대차한 것으로 본다.
2. 다만 **존속기간은 정함이 없는 것**이 되므로 당사자는 제635조에 의해 해지통고할 수 있다.

3. 전 임대차에 대하여 **제3자가 제공한 담보는 기간만료로 소멸**한다(제2항). 임차인 자신이 제공한 보증금은 존속한다.

핵심 암기
묵시갱신 = **"조건은 같고, 기간은 사라지고, 제3자 담보도 사라진다."**

3. 임대차의 효력 — 당사자의 의무 · 보충(강의자료 외) ★

(1) 임대인의 의무

- **사용·수익하게 할 의무**(제623조): 매도인과 달리 **적극적·계속적** 의무이다. 제3자의 방해는 임대인이 제거해 주어야 한다.
- **수선의무**(제623조): 임차인의 귀책사유 없이 파손되어 사용·수익에 지장이 생기면 **임대인에게 귀책사유가 없더라도** 수선의무를 진다. 임차인이 쉽게 고칠 수 있는 **사소한 파손**은 제외된다. **수선의무 면제특약이 있어도 대파손·주요구조부의 수선은 임대인이 부담**한다(판례).
- **보호의무(안전배려의무)**: **원칙적으로 부정**되고, 숙박계약 등 특별한 사정이 있는 때에만 인정된다.

(2) 임차인의 의무

- **차임지급의무**: 약정이 없으면 **후급**이 원칙이다(제633조).
- **선관주의 보관의무** 및 종료 시 **원상회복·반환의무**.
- **통지의무**(제634조): 수리를 요하거나 제3자가 권리를 주장하는 때 지체 없이 통지. 임대인이 이미 안 때에는 불요.
- **보존행위 인용의무**(제624조): 다만 임차인의 의사에 반하는 보존행위로 **임차의 목적을 달성할 수 없는 때에는 해지**할 수 있다(제625조).

(3) 차임의 감액·증감

- **일부멸실과 감액청구**(제627조): 임차인의 **과실 없이** 일부를 사용·수익할 수 없는 때 비율에 의한 감액청구, **잔존부분만으로 목적달성이 불가능하면 해지**.
- **차임증감청구권**(제628조): 경제사정 변동 시 **장래에 대하여** 증감청구. **형성권**. 판례는 **차임부증액 특약**은 임차인에게 불리하지 않아 유효로 본다.

4. 임차인의 비용상환청구권(제626조) ★★

구분	필요비	유익비
의의	보존·관리에 필요한 비용	객관적 가치를 증가시킨 비용
행사시기	**지출 즉시**	**임대차 종료 시**
범위	지출액 전부	가액증가 현존 시 **지출액 또는 증가액 중 임대인 선택**
상환기간 허여	불가	가능(허여되면 유치권 부정)
강행성	임의규정	임의규정 → **포기특약 유효**

핵심 암기
비용상환청구권은 제652조 목록에 **없으므로 임의규정**이다. "원상복구하고 나간다"는 원상회복 약정은 비용상환청구권 **포기특약**으로 해석되어 **유효**하다(판례). 반면 **부속물매수청구권**은 강행규정이어서 포기특약이 무효이다 — 이 대비가 출제 1순위.

함정 주의
행사기간: 비용상환청구권은 제654조가 준용하는 제617조에 따라 **임대인이 물건의 반환을 받은 날로부터 6개월 내**에 행사해야 한다. 반면 **부속물·지상물매수청구권에는 이런 제척기간이 없다**.

필요비·유익비상환청구권은 목적물에 관하여 생긴 채권이므로 **유치권**이 성립하고, 임차인은 **동시이행의 항변**으로 차임지급을 거절할 수도 있다(다만 유치권 행사 중의 사용이익은 부당이득으로 반환).

5. 토지임차인의 지상물매수청구권(제643조) ★★★

(1) 요건

1. **건물 기타 공작물의 소유 또는 식목·채염·목축을 목적**으로 한 **토지임대차**일 것.
2. 임대차 **기간이 만료**하고 **지상물이 현존**할 것.
3. 임차인이 **갱신을 청구**하였으나 임대인이 **거절**할 것(제283조 준용).

기간의 약정이 없는 토지임대차가 임대인의 해지통고로 종료된 경우에는 **갱신청구 없이 곧바로** 매수청구를 할 수 있다(판례). 임대인이 스스로 종료시킨 이상 갱신청구가 무의미하기 때문이다.

(2) 성질과 효과

- **형성권**이다. 행사하면 임대인의 승낙 없이 **시가에 의한 매매계약이 성립**한다.
- 대금지급의무와 지상물의 **소유권이전·인도의무는 동시이행관계**이다.
- 대금을 받지 못해 토지를 계속 점유하더라도 불법점유는 아니지만, **차임 상당액은 부당이득으로 반환**하여야 한다.
- **편면적 강행규정**(제652조): **"종료 시 지상시설 일체를 포기한다"는 특약은 무효**이고 매수청구권을 행사할 수 있다.

(3) 판례가 정리한 개별 쟁점

- **임대인의 동의 없이 신축한 건물**도 대상이 된다(동의는 요건이 아님).
- 지상물이 **경제적 가치가 없거나 임대인에게 효용이 없어도** 대상이 된다.
- **저당권이 설정된 건물**도 대상이 된다(매수인이 부담 인수).
- 건물이 **임차지와 제3자 소유 토지에 걸쳐** 있으면 **임차지상의 부분 중 구분소유의 객체가 될 수 있는 부분에 한하여** 행사할 수 있고, 건물 전부에 대하여는 할 수 없다.
- **임차인의 채무불이행(2기 차임연체 등)으로 해지된 경우에는 인정되지 않는다.**
- 토지가 양도된 경우 **임차권에 대항력이 없으면** 신소유자는 임대인 지위를 승계하지 않으므로 **신소유자에게는 행사할 수 없다.**

6. 건물임차인의 부속물매수청구권(제646조) ★★

- 주체는 **건물 기타 공작물의 임차인**, 객체는 **사용의 편익을 위하여 부속시킨 물건**으로서 **건물로부터 독립성이 있어야** 한다. 구성부분이 되어 독립성을 잃으면 **유익비**의 문제가 된다.
- **임대인의 동의를 얻어** 부속하였거나 **임대인으로부터 매수**한 것일 것(제2항).
- **임차인 개인의 특수한 영업목적**만을 위한 설비는 건물의 객관적 편익에 기여하지 않아 대상이 아니다.
- 행사시기는 **임대차 종료 시**이고 제척기간은 없다. **편면적 강행규정**이나, **일시사용을 위한 임대차**에는 적용되지 않는다(제653조).
- 매수대금채권은 **건물에 관하여 생긴 채권이 아니므로 건물에 대한 유치권은 인정되지 않는다.**

지상물매수청구권 vs 부속물매수청구권 비교표 ★★★

구분	지상물매수청구권(제643조)	부속물매수청구권(제646조)
주체	건물소유·식목·채염·목축 목적의 **토지**임차인(전차인: 제644조)	**건물 기타 공작물**의 임차인(전차인: 제647조)
객체	현존하는 건물·수목 등 **지상시설**	건물의 **객관적 편익**을 위한 **독립성 있는** 부속물
임대인의 동의	**불요**	**필요**(또는 임대인에게서 매수)
갱신청구 선행	원칙적으로 **필요**(임대인 해지통고 시에는 불요)	불요
유치권	토지에 대한 유치권 부정(동시이행으로 해결)	건물에 대한 유치권 **부정**
공통점	형성권 / 편면적 강행규정 / 제척기간 없음	임차인 채무불이행으로 종료 시 **모두 불인정**

두문자·암기법

"토지는 갱신 먼저, 건물은 동의 먼저" — 토지(지상물)는 **갱신청구**가, 건물(부속물)은 **임대인의 동의**가 선행요건. 그리고 **"내 잘못으로 끝나면 둘 다 없다."**

7. 임차권의 대항력(제621조·제622조) ★

(1) 임대차의 등기(제621조)

- **부동산** 임차인은 반대약정이 없으면 임대인에게 **임대차등기절차에 협력할 것을 청구**할 수 있고, 등기한 때에는 **그때부터** 제3자에 대하여 효력이 생긴다.
- 이는 **청구권일 뿐이므로 임대인의 협력 없이 임차인이 단독으로 등기할 수는 없다**.

(2) 건물등기 있는 차지권의 대항력(제622조)

- **건물의 소유를 목적으로 한 토지임대차**는 임대차를 등기하지 않았더라도 **임차인이 그 지상건물을 등기**하면 제3자에 대하여 효력이 생긴다.
- 건물등기는 **임차인 명의**여야 하며, 배우자·자녀 등 타인 명의로는 대항력이 생기지 않는다.
- 건물이 기간 만료 전에 **멸실·후폐**하면 그 효력을 잃는다(제2항).
- 적용범위는 **건물 소유 목적**의 토지임대차에 한정되고, 식목·채염·목축 목적에는 적용되지 않는다.

> **함정 주의**
> "임차인은 언제나 단독으로 임차권등기를 할 수 있다"는 지문은 **틀린다**. 단독신청이 가능한 임차권등기명령은 **특별법**의 제도이다.

8. 임차권의 양도와 전대(제629조~제632조) ★★★

(1) 원칙

임차인은 **임대인의 동의 없이** 그 권리를 양도하거나 임차물을 전대하지 못하고, 위반한 때에는 **임대인은 계약을 해지**할 수 있다(제629조). 다만 **건물의 소부분**을 타인에게 사용하게 하는 경우에는 제629조~제631조가 적용되지 않는다(제632조). 판례는 무단양도·무단전대라도 **배신적 행위라고 할 수 없는 특별한 사정**이 있으면 해지할 수 없다고 한다.

동의 있는 **양도**의 경우 임차인의 지위가 동일성을 유지한 채 양수인에게 이전하고 양도인은 임대차관계에서 탈퇴한다. 다만 **양도 전에 이미 발생한 연체차임채무는 특약이 없는 한 승계되지 않는다**.

(2) 무단전대 vs 적법전대(동의 있는 전대) 비교표

구분	무단전대(동의 없음)	적법전대(동의 있음)
임차인-전차인	당사자 사이에서는 **유효**	유효
임대인의 해지	**해지 가능**(제629조 제2항)	해지 불가
임대인-전차인	직접적 법률관계 **없음** → **차임 직접청구 불가**	전차인이 임대인에게 **직접 의무** 부담(제630조)
목적물 반환	소유권에 기한 **반환청구 가능**	불가(전차인은 적법한 점유권원 보유)
임차인의 책임	채무불이행 → **손해배상**(해지하지 않아도 가능)	없음

> **함정 주의**
> 무단전대에서 전차인이 사용·수익하지 못하게 된 경우 임차인의 책임은 **담보책임이 아니라 일반 채무불이행책임**이다. 또한 임대인이 아직 해지하지 않았다면 **전차인에게 직접 차임을 청구할 수 없다**(차임은 임차인에게 청구). 이 두 지문이 반복 출제된다.

(3) 적법전대에서 임대인·임차인·전차인의 법률관계

1. **직접의무 부담**(제630조 제1항): 전차인은 임대인에게 **직접 의무**를 진다. **의무만 부담하는 편면적 관계**이고 전차인이 임대인에 대한 권리를 취득하는 것은 아니다.
2. **차임의 범위**: 차임액과 전차임액 중 **적은 금액**의 한도에서 직접 지급의무를 진다.
3. **선지급의 대항 불가**: 전차인은 **전대차계약상 차임지급시기 전에 임차인에게 지급한 차임으로 임대인에게 대항하지 못한다**(제630조 제1항 단서). 지급시기 도래 후의 지급은 대항할 수 있다.
4. **임차인의 의무 존속**(제630조 제2항): 전대하여도 임차인은 임대인에 대한 권리·의무를 그대로 가진다.
5. **합의해지의 제한**(제631조): 임대인과 임차인이 **임대차를 합의해지하여도 전차인의 권리는 소멸하지 않는다**. 강행규정이다.

6. **해지통고의 통지**(제638조): 임대차가 **해지통고**로 종료된 경우에는 전차인에게 **통지**하지 않으면 대항하지 못하고, 통지 후 제635조의 기간(6개월·1개월·5일)이 지나야 해지의 효력이 생긴다.
7. **차임연체 해지의 경우**: 임차인의 **2기 차임연체**로 해지하는 때에는 **전차인에 대한 통지가 필요 없고** 전대차도 함께 종료하며, 전차인은 대항하지 못한다.
8. **반환의 처리**: 전대차 종료 시 전차인이 **임대인에게 직접 목적물을 반환하면** 임차인에 대한 반환의무도 면한다.
9. **전차인 보호규정**: 전차인의 임대청구권·지상물매수청구권(제644조), 전차인의 부속물매수청구권(제647조).

핵심 암기

적법전대의 3원칙 — **"직접의무는 지되 권리는 없고(630), 합의해지로는 안 죽고(631), 연체해지로는 죽는다(640)."**

9. 차임연체와 해지 · 보증금 ★★

- **제640조**: 건물 기타 공작물의 임대차에서 임차인의 **차임연체액이 2기의 차임액에 달하는 때** 임대인은 해지할 수 있다. 연속될 필요는 없고 **연체액의 합계**가 2기분이면 된다.
- **제641조**: 건물 소유·식목·채염·목축을 목적으로 한 **토지임대차**도 2기 연체 시 해지할 수 있다.
- **제642조**: 제641조의 경우 지상건물이 **담보물권의 목적**인 때에는 담보물권자에게 **통지**한 후 상당한 기간이 지나야 해지의 효력이 생긴다.
- 제640조·제641조는 **편면적 강행규정**이므로 **"1기만 연체하여도 해지한다"는 특약은 무효**이다. 차임연체 해지는 해지통고가 아니라 **즉시 해지**여서 유예기간이 없다.

보증금

- 보증금계약은 임대차에 **종된 계약**이다.
- **임대차 존속 중에 연체차임이 보증금에서 당연히 공제되지는 않는다.** 임대인이 공제를 주장할 것인지 선택할 수 있을 뿐이고, 임차인은 보증금의 존재를 이유로 차임지급을 거절하지 못한다.
- 종료 후 **목적물이 반환될 때** 연체차임·손해배상금이 **당연히 공제**되고 잔액만 반환된다. 공제사유의 **증명책임은 임대인**에게 있다.
- **보증금반환의무와 목적물반환의무는 동시이행관계**이다. 보증금을 받을 때까지 점유를 계속하는 것은 불법점유가 아니지만, **실제로 사용·수익하였다면 차임 상당액을 부당이득으로 반환**하여야 한다.

두문자·암기법

편면적 강행규정(제652조) = **627 · 628 · 631 · 635 · 638 · 640 · 641 · 643~647** → **"멸(627)·증(628)·확(631)·통고(635)·통지(638)·연체2(640·641)·매수5(643~647)"**. **제626조(비용상환)가 빠져 있다**는 점이 핵심.

10. 기출·모의 지문 OX ★★★

기출·모의 지문 OX

1. 건물의 사용을 목적으로 하는 임대차의 존속기간은 영구무한으로 정할 수 없다. → X (2016년 개정으로 최장기간을 제한하던 제651조가 삭제되어 상한이 없고, 판례도 영구 약정을 유효로 본다)
2. 임대차기간 만료 후 임차인이 사용·수익을 계속하는데 임대인이 상당한 기간 내에 이의하지 아니한 때에는 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차한 것으로 본다. → O (제639조 제1항. 다만 존속기간은 정함이 없는 것으로 된다)
3. 기간의 약정이 없는 토지임대차에서 임차인이 해지를 통고한 경우, 임대인이 통고를 받은 날로부터 3개월이 경과하여야 해지의 효력이 생긴다. → X (임차인이 통고한 때에는 1개월, 임대인이 통고한 때에는 6개월이다 — 제635조)
4. 임대인에게 귀책사유가 없이 목적물이 훼손되어 사용·수익할 수 없게 된 경우에도 임대인은 수선의무를 부담하며, 수선의무 면제특약이 있어도 주요구조부의 대수선은 임대인이 부담한다. → O (제623조 및 판례. 면제특약은 통상의 소모·수선에 한정된다)
5. 임차인의 필요비상환청구권은 임대차가 종료한 후에만 행사할 수 있다. → X (필요비는 지출 즉시 청구할 수 있다. 종료 시에 청구하는 것은 유익비이다)
6. 유익비상환청구권을 포기하기로 하는 특약은 임차인에게 불리하여 무효이다. → X (제626조는 제652조의 강행규정 목록에 없는 임의규정이므로 포기특약은 유효하다)
7. 유익비상환청구권은 임대인이 목적물의 반환을 받은 날로부터 6개월 내에 행사하여야 한다. → O (제654조가 준용하는 제617조의 제척기간. 부속물매수청구권에는 이러한 제한이 없다)
8. 부속된 물건이 건물의 구성부분이 되어 독립성을 상실한 경우에도 부속물매수청구권을 행사할 수 있다. → X (독립성이 있어야 부속물이고, 독립성이 없으면 유익비상환의 문제가 된다)
9. 토지임차인이 계약의 갱신을 청구하였으나 임대인이 이를 거절한 경우 임차인은 지상물의 매수를 청구할 수 있다. → O (제643조·제283조. 갱신청구가 선행요건이다)
10. 임대차 종료 시 지상시설 일체를 포기하기로 하는 특약이 있으면 토지임차인은 지상물매수청구권을 행사할 수 없다. → X (제652조의 편면적 강행규정에 반하여 무효이므로 매수청구권을 행사할 수 있다)
11. 임차인의 2기 차임연체를 이유로 임대차가 해지된 경우에도 토지임차인은 지상물매수청구권을 행사할 수 있다. → X (임차인의 채무불이행으로 종료된 때에는 매수청구권이 인정되지 않는다)
12. 기간의 약정이 없는 토지임대차가 임대인의 해지통고로 종료된 경우, 임차인은 갱신청구 없이 곧바로 지상물매수청구를 할 수 있다. → O (판례. 임대인이 스스로 종료시킨 이상 갱신청구는 무의미하다)
13. 임차인 소유의 건물이 임차토지와 제3자 소유의 토지에 걸쳐 있는 경우, 임차인은 건물 전부에 대하여 매수청구를 할 수 있다. → X (임차지상에 있는 부분 중 구분소유의 객체가 될 수 있는 부분에 한한다)
14. 임대인의 동의 없이 신축한 건물이거나 경제적 가치가 별로 없는 지상물은 매수청구의 대상이 되지 않는다. → X (동의는 요건이 아니고, 임대인에게 효용이 없거나 저당권이 설정되어 있어도 대상이 된다)
15. 토지가 제3자에게 양도된 경우, 임차권등기를 하지 않은 임차인은 새로운 소유자에게 지상물매수청구권을 행사할 수 있다. → X (대항력이 없으면 새 소유자가 임대인의 지위를 승계하지 않으므로 행사할 수 없다)
16. 임대인의 동의를 얻은 전대차에서 전차인은 전대차계약상 차임지급시기 전에 임차인에게 지급한 차임으로 임대인에게 대항할 수 있다. → X (제630조 제1항 단서. 선지급한 차임으로는 대항하지 못한다)
17. 임대인과 임차인이 임대차계약을 합의해지하면 적법한 전차인의 권리도 소멸한다. → X (제631조. 합의해지로는 전차인의 권리가 소멸하지 않는다. 반면 임차인의 2기 차임연체로 해지되는 때에는 전차인에 대한 통지 없이도 전대차가 함께 종료한다)
18. 임대인의 동의 없는 전대차의 경우, 임대인이 임대차를 해지하지 않았더라도 전차인에게 직접 차임의 지급을 청구할 수 있다. → X (임대인과 무단전차인 사이에는 직접적 법률관계가 없어 차임은 임차인에게 청구하여야 한다)

※ 기간·갱신·대항력의 세부 수치는 개정 가능성이 있으므로 **최신 법령 확인**이 필요하다. 민법의 "기간의 약정이 없는 임대차"와 특별법의 계약갱신요구권은 규율 내용이 전혀 다르므로 혼동하지 않는다.

제12장 주택임대차보호법

주택임대차보호법(이하 **주임법**)은 국민 주거생활의 안정을 위하여 민법의 임대차 규정에 대한 **특례**를 정한 법이다. 전 조문이 **편면적 강행규정**이므로, 이 법에 위반된 약정으로서 임차인에게 불리한 것은 무효이나, 임차인에게 유리한 특약은 유효하다.

1. 적용범위 ★★

1) 적용대상

- **주거용 건물(주택)의 임대차**에 적용된다. 주택에 해당하는지는 **공부상의 표시와 관계없이 실지용도(실제 사용관계)**를 기준으로 판단한다.
- **미등기 전세계약(채권적 전세)**에도 준용된다. 이때 전세금은 임대차의 보증금으로 본다.
- **미등기·무허가 건물**의 임대차에도 적용된다. 등기·허가 여부는 요건이 아니다.
- **보증금 액수와 관계없이** 모든 주택임대차에 전부 적용된다(상가건물임대차보호법과 결정적으로 다른 점).

2) 적용제외

- **일시사용을 위한 임대차임이 명백한 경우**에는 적용하지 않는다(숙박업소 단기투숙 등).
- 임차인이 **법인**인 경우에는 원칙적으로 적용하지 않는다. 다만 일정한 공공기관(주택도시기금 지원 임대주택 사업자 등)이나 중소기업인 법인이 직원 주거용으로 임차하는 경우 등 법이 정한 예외가 있다.

핵심 암기

주택임대차보호법은 **보증금 액수 무제한 전부 적용, 미등기 전세·무허가 건물도 적용, 일시사용 명백 시 부적용, 법인 임차인은 원칙 부적용(예외 있음)**. 상가건물임대차보호법은 법인도 항상 적용되고 환산보증금 기준의 제한이 있다는 점에서 정반대로 정리하면 된다.

함정 주의

"공부상 용도가 주택으로 되어 있어야 주임법이 적용된다"는 지문은 **틀린 지문**이다. 등기부·건축물대장상 근린생활시설이라도 실제로 주거용으로 사용하면 적용된다. 반대로 공부상 주택이라도 실제로 순수 영업용이면 적용되지 않는다.

2. 대항력 ★★★

1) 대항요건과 취득시기

임차인이 **주택의 인도**와 **주민등록(전입신고)**을 **모두 갖춘 그 다음 날 오전 0시**부터 제3자에 대하여 대항력이 생긴다. 즉 대항력은 익일 0시에 발생하며, 이는 같은 날 등기된 물권과의 우열을 가르는 결정적 기준이 된다.

사례로 보는 취득시점

사례	인도	주민등록	대항력 발생
기본형	10월 4일	10월 5일	10월 6일 0시
인도가 늦은 경우	10월 7일	10월 5일	10월 8일 0시
저당권 경합	10월 4일	10월 5일	10월 5일 저당권이 선순위

두 요건 중 **늦게 갖춘 날을 기준**으로 그 다음 날 0시에 대항력이 발생한다. 주민등록을 마친 바로 그날 저당권설정등기가 되었다면, 저당권은 당일 효력이 생기고 임차인의 대항력은 익일 0시에 생기므로 **저당권이 언제나 선순위**가 된다.

2) 간접점유와 대항력

- **적법한 전대차**의 경우, 임차인이 직접 점유하지 않더라도 **전차인이 주택을 인도받아 자신 명의로 주민등록을 마쳤다면** 임차인은 대항력을 취득·유지한다(간접점유로 충분).
- 반면 실제 직접점유자가 없이 주민등록만 되어 있는 경우(예: 매매만 이루어지고 임대인 명의로 주민등록만 남은 경우)에는 대항력이 인정되지 않는다.

3) 주민등록에 관한 판례 정리

다가구주택 vs 다세대주택

구분	다가구주택(단독주택)	다세대주택(공동주택)
법적 성질	1개의 건물, 구분소유 아님	구분소유(호별 독립 등기)
전입신고 기재	지번만 기재해도 충분	동·호수까지 정확히 기재
동·호수 누락 시	대항력 인정	원칙적으로 대항력 부정

다세대주택에서 동·호수를 누락하거나 잘못 기재한 경우라도, **이의절차를 거쳐 주민등록이 정정·회복되면 소급하여 대항력이 회복**된다.

직권말소와 회복의 효과

상황	회복 방법	대항력
행정청의 직권말소	이의절차를 거쳐 회복	소급적 회복
행정청의 직권말소	이의절차 없이 회복	비소급적 회복(말소기간 중 상실)

전출과 대항력의 존속

- 임차인 **본인만 일시적으로 전출**하고 **배우자·자녀 등 가족의 주민등록은 그대로 남아 있는 경우** → 대항력 유지.
- **가족 전부가 전출**한 경우 → 그 시점부터 대항력 소멸(다시 전입하면 그때부터 새로운 대항력이 생길 뿐, 소급하지 않는다).

두문자·암기법
"인+주, 다음 날 0시" — 인도 + 주민등록 → 익일 0시.
"다가구는 지번만, 다세대는 동·호수까지" — 가구는 대충, 세대는 자세히.
"직권말소는 이의하면 소급, 안 하면 비소급".

3. 우선변제권과 최우선변제권 ★★★

1) 두 권리의 구조

구분	우선변제권	최우선변제권
요건	대항요건(인도+주민등록) + **확정일자**	대항요건 + **소액임차인**에 해당
요건 구비 시기	배당요구 종기까지 유지	**경매신청 등기 전**까지 대항요건 구비
확정일자	필요	불요
효력	순위에 따라 후순위권리자보다 우선 배당	**선순위 담보물권자보다도 최우선** 배당
범위	보증금 전액(순위 내)	**주택가액의 2분의 1 한도** 내 일정액

2) 최우선변제권의 한도

- 소액임차인이 최우선변제를 받을 수 있는 금액의 총액은 **주택가액(대지가액 포함)의 2분의 1을 넘지 못한다**.
- 소액임차인에 해당하는 **보증금의 기준액**과 **최우선변제를 받을 일정액의 한도**는 지역별로 대통령령이 정하며 개정이 매우 잦다 → **최신 법령(주택임대차보호법 시행령) 확인 필요**.

함정 주의
지역별 소액보증금 기준액이나 최우선변제 한도액을 구체적 금액으로 묻는 지문이 나오면, **반드시 시험 시행 당시의 시행령**을 기준으로 판단해야 한다. 이 노트에서는 수치를 적지 않으니 **최신 법령(주택임대차보호법 시행령) 확인**. 다만 "주택가액의 1/2 한도"라는 상한 원칙은 법률에 규정되어 있어 변하지 않는다.

핵심 암기

대항력 = 인도 + 주민등록 / 우선변제권 = 대항력 + 확정일자 / 최우선변제권 = 대항력(경매신청 등기 전) + 소액. 확정일자는 **우선변제권에만** 필요하고 최우선변제권에는 필요 없다는 점이 가장 빈출되는 비교 포인트다.

4. 계약갱신요구권 ★★★

1) 행사기간과 횟수

- 임차인은 임대차기간이 끝나기 **6개월 전부터 2개월 전까지**의 사이에 계약갱신을 요구할 수 있다(상가건물임대차는 **6개월 전부터 1개월 전까지**).
- 갱신요구권은 **1회에 한하여** 행사할 수 있고, 갱신되는 임대차의 존속기간은 2년으로 본다(상가건물임대차는 최초 기간을 포함하여 **10년**을 넘지 않는 범위에서 반복 행사 가능).
- 기간을 정하지 않았거나 2년 미만으로 정한 주택임대차는 그 기간을 **2년**으로 본다. 다만 임차인은 2년 미만으로 정한 기간이 유효함을 주장할 수 있다(편면적 강행규정의 전형).

2) 임대인의 갱신거절 사유(주요)

1. 임차인이 **2기의 차임액에 해당하는 금액에 이르도록 차임을 연체한 사실이 있는 경우**(상가건물임대차는 **3기**). 현재 연체 중일 필요 없이 "연체한 사실"만 있으면 된다.
2. 임차인이 임차목적물을 **중대한 과실**로 파손한 경우. **경과실로 파손한 경우는 거절사유가 아니다**.
3. 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 임차한 경우, 임대인의 동의 없이 전대한 경우, 쌍방 합의로 상당한 보상을 제공한 경우 등.
4. **임대인(또는 그 직계존속·직계비속)이 목적 주택에 실제 거주하려는 경우** — 주임법에 고유한 거절사유. (보충: 강의자료 외)

두문자·암기법

"주 2·2, 상 1·3" — 주택은 종료 2개월 전까지 행사·2기 연체로 거절, 상가는 1개월 전까지 행사·3기 연체로 거절.
"주택 1회 2년, 상가 10년".

함정 주의

"임차인이 **경미한 과실**로 목적물을 파손한 경우에도 임대인은 갱신을 거절할 수 있다" → **틀린 지문**. 중대한 과실이어야 한다. 또한 "갱신요구는 기간 만료 **1개월** 전까지 하면 된다"는 지문도 주택임대차에서는 **틀린 지문**(2개월 전까지).

5. 임차권등기명령 ★★

- **임대차가 종료된 후 보증금을 반환받지 못한 임차인**은 임차주택 소재지 관할 법원에 **임차권등기명령**을 신청할 수 있다(임대인의 동의 불요).
- 임차권등기가 마쳐지면 임차인은 대항력과 우선변제권을 취득하며, 이미 취득하고 있던 경우에는 그 **대항력·우선변제권이 그대로 유지**된다. 따라서 **이사를 가거나 주민등록을 옮겨도 권리를 잃지 않는다**.
- 임차권등기 **이후에 입주한 소액임차인**은 그 주택에 대하여 **최우선변제권을 행사할 수 없다**. (보충: 강의자료 외)

임차권등기명령 제도는 주택임대차보호법과 상가건물임대차보호법에 **모두** 있다. 대항력·존속기간 보장·갱신요구·우선변제권·임차권등기명령은 두 법이 같은 원리로 운영되는 공통 제도군이다.

6. 임차권의 승계 ★

임차권 승계 제도는 주택임대차보호법에만 있고 상가건물임대차보호법에는 없다. 상가에만 있는 제도가 **권리금 보호**라면, 주택에만 있는 제도가 **임차권 승계**다.

(보충: 강의자료 외 — 기본 내용만 간결히) 임차인이 상속인 없이 사망한 경우, 그 주택에서 **가정공동생활을 하던 사실혼 배우자**가 임차인의 권리·의무를 승계한다. 상속인이 있더라도 그 상속인이 임차인과 가정공동생활을 하고 있지 않았다면, 사실혼 배우자와 **2촌 이내의 친족**이 공동으로 승계한다. 승계대상자가 임차인 사망 후 **1개월 이내**에 임대인에게 반대의사를 표시하면 승계되지 않는다. 승계인은 임대차관계에서 생긴 채권·채무를 함께 승계한다.

두문자·암기법

"주택만 승계, 상가만 권리금" — 두 법의 비공통 제도는 이 둘만 기억하면 된다. 나머지(대항력·최단기간·갱신요구·우선변제·임차권등기명령)는 모두 **공통**.

7. 주택임대차보호법 vs 상가건물임대차보호법 비교 ★★★

1) 대항력·우선변제권·최우선변제·계약갱신요구권 비교표

구분	주택임대차보호법	상가건물임대차보호법
대항요건	인도 + **주민등록(전입신고)**	인도 + **사업자등록 신청**
대항력 발생	요건 구비 **다음 날 0시**	요건 구비 **다음 날 0시**
우선변제권	대항요건 + **확정일자**	대항요건 + **확정일자**(환산보증금 이하만)
최우선변제	소액임차인, **주택가액 1/2 한도**, 경매신청 등기 전 대항요건	소액임차인, **상가건물가액 1/2 한도**, 경매신청 등기 전 대항요건
갱신요구 행사기간	종료 **6개월 전 ~ 2개월 전**	종료 **6개월 전 ~ 1개월 전**
갱신요구 한도	**1회**(갱신기간 2년)	최초기간 포함 **10년** 이내

2) 적용범위·고유제도 비교표

구분	주택임대차보호법	상가건물임대차보호법
강행성	편면적 강행규정	편면적 강행규정
미등기 전세·무허가	적용	적용
일시사용 임대차	부적용	부적용
법인 임차인	원칙 부적용(예외 有)	**항상 적용**
보증금에 의한 제한	**없음**(전부 적용)	환산보증금 이하만 원칙 적용
고유 제도	**임차권 승계**	**권리금 보호**

환산보증금을 **초과**하는 상가건물임대차에도 대항력·계약갱신요구권·권리금 규정·최단존속기간(1년)·3기 차임연체로 인한 해지 규정은 적용된다. 다만 **우선변제·최우선변제 규정은 적용되지 않는다**. 이는 주임법에는 아예 없는 논점이므로 비교 지문으로 자주 출제된다.

3) 차임 연체·해지 비교

구분	주택	상가
해지·갱신거절 기준	**2기** 연체	**3기** 연체
최단존속기간	**2년**	**1년**

핵심 암기

두 법을 가르는 **4대 차이**: ① 대항요건(주민등록 vs 사업자등록), ② 보증금 제한(무제한 vs 환산보증금), ③ 법인(원칙 부적용 vs 항상 적용), ④ 고유제도(승계 vs 권리금). 여기에 **기간 숫자(2년·2개월·2기 / 1년·1개월·3기·10년)**만 얹으면 비교 문제는 모두 해결된다.

기출·모의 지문 OX

1. 주택임대차보호법은 공부상 용도가 주택으로 등재된 건물의 임대차에만 적용된다. → X (공부상 표시와 무관하게 실지용도를 기준으로 판단한다.)
2. 미등기 전세계약에 대하여도 주택임대차보호법이 준용되며, 전세금은 임대차의 보증금으로 본다. → O (미등기 전세, 미등기·무허가 건물에도 적용된다.)
3. 일시사용을 위한 임대차임이 명백한 경우에도 주택임대차보호법이 적용된다. → X (일시사용이 명백한 임대차에는 적용하지 않는다. 주택·상가 공통.)
4. 임차인이 법인인 경우 주택임대차보호법은 원칙적으로 적용되지 않으나, 상가건물임대차보호법은 법인에게도 적용된다. → O (다만 주택도 일정 공공기관·중소기업 법인에는 예외적으로 적용된다.)
5. 주택임대차보호법은 보증금이 일정액 이하인 임대차에만 적용된다. → X (보증금 액수와 관계없이 전부 적용된다. 환산보증금 제한은 상가건물임대차보호법의 문제다.)
6. 임차인이 10월 4일 주택을 인도받고 10월 5일 전입신고를 마쳤다면, 대항력은 10월 5일 0시에 발생한다. → X (늦게 갖춘 요건의 다음 날 0시, 즉 10월 6일 0시에 발생한다.)
7. 임차인이 전입신고를 마친 같은 날 저당권설정등기가 된 경우, 임차인이 저당권자에 우선한다. → X (대항력은 익일 0시에 발생하므로 당일 등기된 저당권이 선순위다.)
8. 임대인의 동의를 얻어 전대한 경우, 전차인이 주택을 인도받아 자기 명의로 주민등록을 마쳤다면 임차인은 대항력을 유지한다. → O (간접점유로도 대항요건이 충족된다.)
9. 다가구용 단독주택의 임차인은 지번만 기재하여 전입신고를 하였더라도 대항력이 인정된다. → O (구분소유가 아니므로 동·호수 기재는 요구되지 않는다.)
10. 다세대주택 임차인이 전입신고 시 동·호수를 누락한 경우에도 지번이 일치하면 대항력이 인정된다. → X (다세대주택은 동·호수까지 정확히 기재해야 하며, 누락 시 원칙적으로 대항력이 부정된다.)
11. 주민등록이 행정청에 의해 직권말소된 후 이의절차를 거쳐 회복된 경우, 대항력은 소급하여 유지된다. → O (이의절차 없이 회복된 경우에는 비소급적 회복이어서 말소기간 동안 대항력을 상실한다.)
12. 임차인이 가족의 주민등록은 그대로 둔 채 본인만 일시적으로 다른 곳에 전출한 경우 대항력을 상실한다. → X (가족의 주민등록이 남아 있으면 대항력은 유지된다. 가족 전부가 전출해야 소멸한다.)
13. 확정일자를 받지 않은 소액임차인도 최우선변제권을 행사할 수 있다. → O (최우선변제권에는 확정일자가 요구되지 않는다. 다만 경매신청 등기 전까지 대항요건을 갖추어야 한다.)
14. 소액임차인들이 최우선변제로 받을 수 있는 금액의 총액은 주택가액의 3분의 1을 넘지 못한다. → X (주택가액의 2분의 1 한도다. 구체적 기준액·한도액은 최신 법령 확인 필요.)
15. 주택임차인의 계약갱신요구는 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 하여야 한다. → X (주택은 6개월 전부터 2개월 전까지다. 1개월 전까지는 상가건물임대차의 기준.)
16. 주택임차인의 계약갱신요구권은 최초 임대차기간을 포함하여 10년을 넘지 않는 범위에서 행사할 수 있다. → X (주택은 1회에 한하며, 10년 기준은 상가건물임대차의 내용이다.)
17. 임차인이 2기의 차임액에 이르도록 차임을 연체한 사실이 있으면 임대인은 갱신요구를 거절할 수 있다. → O (주택은 2기, 상가는 3기. 현재 연체 중일 것을 요하지 않는다.)
18. 임차인이 경과실로 임차목적물을 파손한 경우에도 임대인은 계약갱신요구를 거절할 수 있다. → X (중대한 과실로 파손한 경우여야 한다.)
19. 임차권등기명령에 따라 임차권등기를 마친 임차인은 그 후 이사하여 주민등록을 옮겨도 이미 취득한 대항력과 우선변제권을 유지한다. → O (임차권등기명령 제도의 핵심 효과이며, 주택·상가에 모두 있는 제도다.)
20. 임차권의 승계 제도는 주택임대차보호법과 상가건물임대차보호법에 모두 규정되어 있다. → X (승계는 주택에만, 권리금 보호는 상가에만 있는 고유 제도다.)

※ 본 장의 **기간·횟수·비율(2년, 2개월, 2기, 1회, 주택가액 1/2 등)**은 법률에 직접 규정된 사항이므로 그대로 암기한다. 반면 **소액임차인의 보증금 기준액과 최우선변제 한도액(지역별 원화 금액)**은 시행령 사항으로 개정이 잦으므로, 반드시 시험 시행일 기준 최신 법령(주택임대차보호법 시행령) 확인이 필요하다.

제13장 상가건물임대차보호법

1. 목적과 적용범위 ★★

1-1. 법의 성격

상가건물임대차보호법(이하 **상가법**)은 **사업자등록의 대상이 되는 상가건물의 임대차**에 관하여 민법의 특례를 정한 법이다. 이 법에 위반된 약정으로서 **임차인에게 불리한 것은 효력이 없다(편면적 강행규정)**. 임차인에게 유리한 특약은 유효하다.

1-2. 적용되는 경우 / 적용되지 않는 경우

구분	내용
적용 O	사업자등록 대상이 되는 **영업용** 건물의 임대차(주된 부분을 영업용으로 사용하면 적용)
적용 O	**미등기 전세(채권적 전세)** — 전세금을 보증금으로 보아 준용
적용 O	**미등기 · 무허가 건물**의 임대차 — 등기 · 허가 여부는 요건이 아님
적용 O	**법인**이 임차인인 경우 (주택임대차와 다른 점)
적용 X	**일시사용**이 명백한 임대차

동창회 · 종교단체 · 자선단체 사무실처럼 영리를 목적으로 하지 않는 비영업용 건물은 사업자등록 대상이 아니므로 적용되지 않는다.

함정 주의

주택임대차에서는 **법인**이 원칙적으로 보호받지 못하지만(중소기업인 법인 등 예외), 상가법에서는 **법인도 언제나 보호**된다. "임차인이 법인이면 이 법이 적용되지 않는다"는 **틀린 지문**이다.

1-3. 환산보증금 — 이 법 전면적용의 기준선

상가법은 **환산보증금**이 시행령이 정하는 일정 금액 **이하**인 임대차에 대하여 원칙적으로 전면 적용된다. 환산보증금은 **보증금 + (월 차임 × 100)**으로 산정한다.

지역별 환산보증금 기준액, 소액임차인 보증금 한도액, 최우선변제액 등 구체적 금액은 최신 법령(상가건물임대차보호법 시행령) 확인 필요.

1-4. 환산보증금을 "초과"해도 적용되는 규정 (최중요)

구분	환산보증금 이하	환산보증금 초과
대항력(인도 + 사업자등록 신청)	적용	**적용**
계약갱신요구권(10년 한도)	적용	**적용**
권리금 회수기회 보호	적용	**적용**
최단존속기간 보장(1년)	적용	**적용**
3기 차임연체 시 해지	적용	**적용**

구분	환산보증금 이하	환산보증금 초과
확정일자에 의한 우선변제권	적용	**적용 X**
소액임차인의 최우선변제권	적용	**적용 X**
임차권등기명령	적용	**적용 X**
차임증액청구의 상한 제한	적용	**적용 X**
묵시적 갱신(1년 의제)	적용	**적용 X**(민법 적용)

두문자 · 암기법

"대 · 갱 · 권 · 일 · 삼" — 대항력, 갱신요구권, 권리금, 최단 일년, 삼기 연체 해지. 이 다섯은 **환산보증금 초과 임대차에도 적용**된다. 나머지 **돈(우선변제 · 최우선변제 · 임차권등기)**은 환산보증금 이하에서만 작동한다.

2. 대항력 ★★★

2-1. 대항요건과 발생시기

임대차는 그 등기가 없는 경우에도 임차인이 **건물의 인도**와 **사업자등록을 신청**하면 그 **다음 날 오전 0시**부터 제3자에 대하여 효력이 생긴다.

- 주택의 "주민등록(전입신고)"에 대응하는 것이 **사업자등록 신청**이다. 등록 완료가 아니라 신청이 기준이다.
- 임차건물의 **양수인**은 임대인의 지위를 승계하고 보증금반환채무도 이전되며, 종전 임대인은 원칙적으로 채무를 면한다.
- 대항요건은 **존속요건**이므로 배당요구 종기 또는 보증금 반환 시까지 유지되어야 한다.

2-2. 사업자등록의 공시력

사업자등록은 **신청서에 첨부된 임대차계약서상의 임차 부분**을 기준으로 공시 기능을 한다. 건물 일부를 임차하면서 도면을 첨부하지 않은 경우 유효한 공시방법으로 인정되지 않을 수 있다.

핵심 암기

대항력 = **인도 + 사업자등록 신청** → **다음 날 0시**. 우선변제권 = **대항요건 + 확정일자**(상가는 세무서장, 주택은 주민센터 · 등기소 · 공증인).

3. 보증금의 회수 — 우선변제권과 최우선변제권 ★★

3-1. 확정일자에 의한 우선변제권

대항요건을 갖추고 관할 **세무서장**에게 임대차계약서상의 **확정일자**를 받은 임차인은, 경매 · 공매 시 임차건물(대지 포함)의 환가대금에서 후순위권리자보다 **우선하여 보증금을 변제받을 권리**가 있다.

- 임차인이 경매를 신청하는 경우 **반대의무의 이행(건물 명도)을 집행개시 요건으로 하지 아니한다**.
- 다만 **배당금을 수령하려면 임차건물을 양수인에게 인도**하여야 한다.

3-2. 소액임차인의 최우선변제권

보증금이 일정액 이하인 **소액임차인**은 보증금 중 일정액을 다른 담보물권자보다 **우선하여 변제**받는다. 경매신청 등기 전에 **대항요건**을 갖추어야 하나, 확정일자는 요구되지 않는다.

소액임차인의 범위 · 최우선변제액 · 배당 총액 한도(건물가액의 일정 비율)는 최신 법령(상가건물임대차보호법 시행령) 확인 필요.

3-3. 임차권등기명령 ★

임대차가 **종료된 후** 보증금을 반환받지 못한 임차인은 관할 법원에 **임차권등기명령**을 신청할 수 있다. 등기가 경료되면 **대항력과 우선변제권을 취득**하고, 이미 취득한 대항력 · 우선변제권은 그대로 유지되므로 이후 퇴거하거나 사업자등록을 말소하여도 효력을 잃지 않는다.

함정 주의

우선변제권 · 최우선변제권 · 임차권등기명령은 **환산보증금 이하**에만 적용된다. 고액 상가임대차 사례에서 "확정일자를 받았으므로 우선변제권이 있다"는 지문은 **환산보증금부터 따져야** 한다. 반면 대항력 · 갱신요구권 · 권리금 · 1년 보장 · 3기 해지는 그대로 인정된다.

4. 존속기간과 계약갱신요구권 ★★★

4-1. 최단존속기간의 보장

기간을 정하지 아니하거나 **1년 미만**으로 정한 임대차는 그 기간을 **1년**으로 본다. 다만 임차인은 1년 미만으로 정한 기간이 유효함을 주장할 수 있다.

임대차 종료 후에도 임차인이 보증금을 반환받을 때까지는 **임대차 관계가 존속하는 것으로 본다**.

4-2. 묵시적 갱신(법정갱신)

임대인이 기간 만료 **6개월 전부터 1개월 전까지** 갱신 거절 또는 조건 변경의 통지를 하지 아니하면 만료 시에 **전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차한 것**으로 본다. 이때 존속기간은 **1년**으로 본다.

- 묵시적 갱신의 경우 **임차인은 언제든지 해지를 통고**할 수 있고, 임대인이 통고받은 날부터 법정기간 경과 시 해지의 효력이 생긴다. **임대인은 해지할 수 없다**.

4-3. 계약갱신요구권

(1) 행사방법과 한도

- 임차인은 기간 만료 전 **6개월 전부터 1개월 전까지** 갱신을 요구할 수 있고, 임대인은 정당한 사유 없이 **거절하지 못한다**.
- 갱신요구권은 **최초 임대차기간을 포함한 전체 기간이 10년을 초과하지 않는 범위**에서만 행사할 수 있다.
- 갱신되는 임대차는 **전 임대차와 동일한 조건**으로 본다. 다만 차임 · 보증금의 증감은 청구할 수 있다.
- 기간의 약정이 없는 임대차도 1년으로 의제되므로 갱신요구권이 인정된다.

(2) 임대인이 갱신을 거절할 수 있는 정당한 사유

거절사유	요건 포인트	판단
차임 연체	**3기**의 차임액에 해당하는 금액에 이르도록 **연체한 사실이 있는** 경우	O
부정한 방법의 임차	거짓 그 밖의 부정한 방법으로 임차한 경우	O
무단 전대	임대인의 동의 없이 목적 건물의 전부 또는 일부를 **전대**한 경우	O
건물 파손	**고의 또는 중대한 과실**로 파손한 경우 (경과실은 제외)	O
철거 · 재건축	계획을 구체적으로 고지하고 그에 따르는 등 법정 요건 충족 시	O

그 밖에 ① 건물의 전부 · 일부 멸실로 임대차 목적을 달성할 수 없는 경우, ② 상호 합의하여 상당한 보상을 제공한 경우, ③ 임차인의 의무를 현저히 위반한 경우도 거절사유이다.

함정 주의

"2기"는 주택, "3기"는 상가이다. 상가 사례에서 "2기의 차임을 연체한 사실이 있으면 갱신을 거절할 수 있다"는 지문은 **틀린 지문**이다. 또한 경과실로 건물을 파손한 것은 거절사유가 아니다(고의 · 중과실만 해당).

5. 차임연체와 해지 — "해지"와 "갱신거절"의 요건 차이 ★

차임연체액이 **3기의 차임액에 달하는 때** 임대인은 계약을 **해지**할 수 있다. 반면 갱신거절 사유는 "3기에 이르도록 연체한 사실이 있는 경우"여서 **요건이 다르다**.

구분	계약 해지	갱신요구 거절
요건 문언	연체액이 3기에 **달하는 때**	3기에 이르도록 **연체한 사실이 있는** 경우
과거 연체 후 모두 변제	**해지 불가**	**거절 가능**
현재 3기 이상 연체 중	해지 가능	거절 가능
권리금 회수 보호의무	—	거절사유 있으면 **면제**

핵심 암기

과거에 3기 연체 사실이 있었으나 지금은 모두 변제하여 연체액이 3기 미만인 사안 → ① 임대인은 **해지할 수 없다**, ② 그러나 **갱신요구는 거절할 수 있다**, ③ 갱신거절 사유가 있으므로 **권리금 회수기회 보호의무도 없다**. 이 3단 결론이 모의고사 단골이다.

6. 권리금 회수기회 보호 ★★★

6-1. 권리금의 개념

권리금이란 상가건물에서 영업을 하는 자가 영업시설 · 비품, 거래처, 신용, 노하우, 위치에 따른 영업상 이점 등 **유형 · 무형의 재산적 가치의 양도 또는 이용대가**로서 보증금과 차임 이외에 지급하는 대가를 말한다. 권리금 계약은 신규임차인이 되려는 자가 임차인에게 권리금을 지급하기로 하는 계약이다.

이 제도는 임대인에게 **권리금 지급의무**를 지우는 것이 아니라, **임차인의 권리금 회수 기회를 방해하지 말 것**을 요구하는 **상가 고유의 제도**이다.

6-2. 보호기간

임대인은 임대차기간이 끝나기 **6개월 전부터 임대차 종료 시까지** 권리금 회수를 방해하여서는 아니 된다. 임차인도 이 기간 내에 신규임차인이 되려는 자와 권리금 계약을 체결하고 **주선**하여야 보호받는다.

함정 주의

권리금 보호기간은 **"종료 6개월 전부터 종료 시까지"**이다. 계약갱신요구권의 행사기간인 "6개월 전부터 1개월 전까지"와 혼동하게 만드는 지문이 반복 출제된다. "권리금 계약은 임대차 종료 1개월 전까지 체결하여야 한다"는 서술은 **틀린 지문**이다.

6-3. 방해행위의 유형

1. 신규임차인이 되려는 자에게 **권리금을 요구하거나 그로부터 권리금을 수수하는 행위**
2. 신규임차인이 되려는 자로 하여금 임차인에게 **권리금을 지급하지 못하게 하는 행위**
3. 임차인이 주선한 신규임차인에게 조세 · 공과금, 주변 상가의 차임 · 보증금에 비추어 현저히 고액의 차임과 보증금을 요구하는 행위
4. 그 밖에 정당한 사유 없이 임차인이 주선한 신규임차인과 **임대차계약의 체결을 거절**하는 행위

판례상 권리금 계약을 체결한 사실이 없더라도, 임대인이 정당한 이유 없이 **신규임차인과 계약할 의사가 없음을 확정적으로 표시**한 경우에는 **방해행위에 해당**할 수 있다.

6-4. 임대인이 계약 체결을 거절할 수 있는 정당한 사유

- 신규임차인이 되려는 자가 **보증금 · 차임을 지급할 자력이 없는** 경우
- 신규임차인이 되려는 자가 **임차인의 의무를 위반할 우려**가 있는 등 임대차를 유지하기 어려운 상당한 사유가 있는 경우
- 상가건물을 **1년 6개월 이상 영리목적으로 사용하지 아니한** 경우
- 임대인이 선택한 신규임차인이 임차인과 권리금 계약을 체결하고 권리금을 지급한 경우
- 갱신요구 거절사유(3기 연체 사실, 무단전대, 고의 · 중과실 파손, 철거 · 재건축 등)가 있으면 권리금 보호규정 자체가 적용되지 않는다.

6-5. 손해배상책임

임대인이 방해행위로 임차인에게 손해를 발생하게 한 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

쟁점	내용
배상액 한도	**신규임차인이 임차인에게 지급하기로 한 권리금**과 **임대차 종료 당시의 권리금** 중 **낮은 금액**을 넘지 못한다
소멸시효	임대차가 **종료한 날부터 3년** 이내에 행사하지 아니하면 시효로 소멸
자료 제공의무	임차인은 신규임차인의 지급능력 · 의무이행 능력에 관한 정보를 임대인에게 제공하여야 한다

6-6. 권리금 규정이 적용되지 않는 경우

- 목적물이 **대규모점포 또는 준대규모점포**의 일부인 경우
- 목적물이 **국유재산 또는 공유재산**인 경우
- **전대인과 전차인 사이의 전대차**에는 권리금 규정이 준용되지 않는다

두문자 · 암기법

권리금 **"육 · 종 · 저 · 삼"** — 종료 6개월 전부터 종료 시까지 보호, 배상액은 둘 중 저가(낮은 금액) 한도, 시효는 종료일부터 3년.
배제대상은 **"국 · 대 · 전"** — 국공유재산, 대규모점포, 전대차.

7. 주택임대차보호법 vs 상가건물임대차보호법 비교 ★★★

7-1. 대항력 · 우선변제권 · 최우선변제 · 계약갱신요구권 비교표

구분	주택임대차보호법	상가건물임대차보호법
대항요건	주택의 인도 + 주민등록(전입신고)	건물의 인도 + 사업자등록 신청
대항력 발생시기	다음 날 오전 0시	다음 날 오전 0시
확정일자 부여기관	주민센터 · 등기소 · 공증인 등	**관할 세무서장**
우선변제권	대항요건 + 확정일자 (보증금액 제한 없음)	대항요건 + 확정일자 (**환산보증금 이하만**)
최우선변제	경매신청 등기 전 대항요건, 주택가액의 법정비율 한도	경매신청 등기 전 대항요건, 건물가액의 법정비율 한도(**환산보증금 이하만**)

구분	주택임대차보호법	상가건물임대차보호법
최단존속기간	2년	**1년**
갱신요구권 행사기간	종료 6개월 전부터 2개월 전까지	**종료 6개월 전부터 1개월 전까지**
갱신요구 한도	1회에 한하여(갱신기간 2년)	**최초 기간 포함 10년 범위**에서 횟수 제한 없음
차임연체 기준	2기	**3기**
법인 임차인	원칙적 보호 X (법정 예외만)	**언제나 보호 O**

구분	주택임대차보호법	상가건물임대차보호법
권리금 회수기회 보호	규정 없음	**고유 제도 O**
보증금액에 따른 적용 제한	없음(전면 적용)	**환산보증금 기준**으로 일부 규정만 초과 적용
미등기 전세 / 일시사용	준용 O / 적용 X	준용 O / 적용 X

양 법 모두 **편면적 강행규정**이며, 양수인은 임대인의 지위를 승계한다.

핵심 암기

주택은 **"2 · 2 · 2"**(2년 · 2기 · 2개월 전까지), 상가는 **"1 · 3 · 1"**(1년 · 3기 · 1개월 전까지)로 대비하여 외운다. 갱신 한도는 주택 1회 2년, 상가 총 10년.

8. 기출 · 모의 지문 OX ★

기출 · 모의 지문 OX

1. 상가건물의 임차인이 건물을 인도받고 사업자등록을 신청하면 그 신청한 다음 날 오전 0시부터 대항력을 취득한다. → O (인도 + 사업자등록 신청 → 익일 0시)
2. 임차인이 법인인 경우에는 상가건물임대차보호법이 적용되지 않는다. → X (상가법은 법인 임차인에게도 언제나 적용된다. 주택임대차와 다른 점)
3. 상가건물의 미등기 전세에 대하여도 상가건물임대차보호법이 준용된다. → O (전세금을 보증금으로 보아 준용)
4. 환산보증금이 시행령이 정한 기준액을 초과하는 임대차에도 계약갱신요구권 규정은 적용된다. → O (대항력 · 갱신요구권 · 권리금 · 최단 1년 · 3기 해지는 초과해도 적용)
5. 환산보증금이 기준액을 초과하는 임대차에도 확정일자에 의한 우선변제권 규정이 적용된다. → X (우선변제 · 최우선변제 · 임차권등기명령은 환산보증금 이하에만 적용)
6. 존속기간에 관한 약정이 없는 상가건물임대차의 임차인에게는 계약갱신요구권이 인정되지 않는다. → X (기간의 정함이 없으면 1년으로 보므로 갱신요구권이 인정된다)
7. 임차인의 계약갱신요구권은 최초의 임대차기간을 포함한 전체 임대차기간이 10년을 초과하지 않는 범위에서 행사할 수 있다. → O (10년 한도)
8. 임차인이 2기의 차임액에 해당하는 금액에 이르도록 차임을 연체한 사실이 있으면 임대인은 갱신요구를 거절할 수 있다. → X (상가는 3기 기준이다. 2기는 주택임대차의 기준)
9. 임차인이 임차목적물을 경과실로 파손한 경우 임대인은 갱신요구를 거절할 수 있다. → X (고의 또는 중대한 과실로 파손한 경우에만 거절사유가 된다)
10. 임대인의 동의 없이 목적 건물의 일부를 전대한 경우 임대인은 갱신요구를 거절할 수 있다. → O (무단 전대는 거절사유)
11. 건물의 철거 · 재건축을 위하여 목적 건물의 점유를 회복할 필요가 있는 경우 임대인은 법정 요건 아래 갱신요구를 거절할 수 있다. → O (정당한 사유로 인정)
12. 과거에 3기의 차임액에 이르도록 연체한 사실이 있으나 현재 연체액이 3기에 미달하는 경우, 임대인은 그 연체 사실을 이유로 계약을 해지할 수 있다. → X (해지는 현재 연체액이 3기에 달할 것을 요한다)
13. 위 사안에서 임대인은 임차인의 계약갱신요구를 거절할 수 있다. → O (갱신거절은 "연체한 사실이 있는" 경우이므로 해지와 요건이 다르다)
14. 위 사안에서 임대인은 임차인의 권리금 회수기회를 보호할 의무를 부담하지 않는다. → O (갱신거절의 정당사유가 있으면 권리금 회수기회 보호규정이 적용되지 않는다)
15. 권리금 회수기회를 보호받으려면 임대차기간 만료 1개월 전까지 신규임차인과 권리금계약을 체결하여야 한다. → X (종료 6개월 전부터 임대차 종료 시까지 사이이다. 1개월 전까지는 갱신요구권의 행사기간)
16. 임대인의 손해배상액은 임차인이 주선한 신규임차인이 지급하기로 한 권리금과 임대차 종료 당시의 권리금 중 높은 금액을 한도로 한다. → X (둘 중 낮은 금액을 넘지 못한다)
17. 권리금 회수 방해로 인한 임대인의 손해배상책임은 임대차가 종료한 날부터 3년 이내에 행사하지 않으면 시효로 소멸한다. → O (3년의 소멸시효)
18. 임대인이 목적 건물을 1년 6개월 이상 영리목적으로 사용하지 아니한 경우, 임차인이 주선한 신규임차인과의 계약 체결을 거절할 정당한 사유가 인정된다. → O (법정 정당사유)
19. 임차인이 신규임차인과 권리금계약을 체결한 사실이 없다면, 임대인이 정당한 이유 없이 더 이상 임대하지 않겠다는 의사를 명백히 표시하였더라도 방해행위에 해당하지 않는다. → X (계약 체결 사실이 없어도 확정적 거절 의사 표시는 방해행위가 될 수 있다)
20. 권리금 회수기회 보호에 관한 규정은 전대인과 전차인의 전대차관계에도 준용된다. → X (전대차에는 권리금 규정이 적용되지 않는다. 국유 · 공유재산, 대규모점포도 제외)

※ 환산보증금 기준액, 소액임차인 보증금 한도, 최우선변제액 등 금액은 개정이 잦다. 최신 법령(상가건물임대차보호법 시행령) 확인 필요.

제14장 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률

집합건물법은 1동의 건물을 구조상·이용상 독립된 여러 개의 부분으로 나누어 각각 소유권의 객체로 삼는 **구분소유관계**를 규율하는 **민사특별법**이다. 아파트·오피스텔·상가 등 우리 주변의 대부분의 부동산이 집합건물이므로, 시험에서는 공용부분의 법률관계와 관리단집회의 결의정족수가 매년 반복 출제된다.

> **핵심 암기**
> 집합건물법의 출발점은 **"전유부분 중심주의"**이다. 공용부분 지분도, 대지사용권도, 관리비 승계도 모두 **전유부분을 따라 움직인다**는 하나의 원리에서 파생된다. 이 원리를 잡으면 개별 조문을 따로 외울 필요가 없다.

제1절 집합건물의 기본 용어와 구분소유권의 성립 ★★

1. 주요 용어

(1) 전유부분

구분소유권의 목적인 건물부분을 말한다. 예컨대 아파트 102동의 **개별 호실**이 전유부분이다. 전유부분은 구조상·이용상 독립성을 갖추어야 한다.

(2) 공용부분

- **법정(구조상) 공용부분**: 구조상 당연히 공용으로 되는 부분. **계단, 복도, 엘리베이터, 옥상, 외벽** 등. 성질상 전유부분이 될 수 없다.
- **규약상 공용부분**: 원래 전유부분이 될 수 있는 것을 규약으로 공용부분화한 것. **관리사무소, 노인정, 창고** 등이 대표적이다.

(3) 그 밖의 용어

- **관리단**: 구분소유자 전원으로 당연히 구성되는 단체(조직행위 불요).
- **관리소(관리사무소)**: 관리업무를 실제로 수행하는 물적·인적 조직으로, 관리단과는 구별되는 개념이다.
- **대지사용권**: 구분소유자가 전유부분을 소유하기 위하여 건물의 대지에 대하여 가지는 권리(소유권, 지상권, 임차권 등).

2. 구분소유권의 성립요건

판례에 의하면 구분소유권은 **구조상 독립성 + 이용상 독립성 + 구분행위**가 있으면 성립하고, 별도로 집합건물의 표시등기를 할 것을 요하지 아니한다.

1. **구조상 독립성**: 다른 부분과 차단되어 있을 것.
2. **이용상 독립성**: 독립하여 건물로서의 용도를 수행할 수 있을 것.
3. **구분행위**: 건물의 특정 부분을 구분하여 별개의 소유권의 객체로 삼으려는 구분소유자의 의사표시. 분양계약 등 처분행위로도 인정될 수 있다.

> **함정 주의**
> "구분소유권이 성립하려면 **집합건물의 표시에 관한 등기를 하여야 한다**"는 지문은 **틀린 지문**이다. 등기는 성립요건이 아니라 공시방법에 불과하다. 반대로 **규약상 공용부분**은 규약설정만으로 부족하고 **그 취지의 등기가 있어야** 물권변동의 효력이 생기고 제3자에게 대항할 수 있다.

3. 등기의 요부 정리

구분	등기 필요 여부	근거·이유
구분소유권의 성립	**불요**	독립성 + 구분행위만으로 성립(판례)
구조상(법정) 공용부분	**불요**	구조상 당연히 공용부분이 됨
규약상 공용부분	**필요**	규약설정 + 등기하여야 제3자에게 대항
공용부분의 물권변동	**불요**	전유부분 처분에 따라 당연히 이전

두문자·암기법

"구·구·공(不) / 규(要)" - 구분소유권 성립, 구조상 공용부분, 공용부분의 물권변동은 등기 **불요**. 오직 규약상 공용부분만 등기 **필요**.

제2절 공용부분의 법률관계 ★★★

1. 공용부분에 대한 지분

각 공유자의 지분은 **그가 가지는 전유부분의 면적 비율**에 따른다. 민법상 공유처럼 **균등한 것으로 추정되지 않는다**는 점이 핵심이다.

2. 공용부분의 처분 - 분리처분 금지

공용부분에 대한 공유자의 지분은 그가 가지는 전유부분의 처분에 따르며, 전유부분과 분리하여 처분할 수 없다. 이 금지는 **규약으로도 배제할 수 없다**.

함정 주의

공용부분은 규약으로도 전유부분과 분리처분할 수 **없다**. 그러나 **대지사용권**은 규약 또는 공정증서로 정하면 분리처분이 **가능**하다. 둘을 바꾸어 놓은 지문이 단골 출제된다.

3. 공용부분의 변경

유형	내용	의결정족수
중대한 변경	구분소유자의 **소유권 비율에 영향**이 있는 경우	**구분소유자 및 의결권의 각 4분의 3 이상**
경미한 변경	소유권 비율에 **영향이 없는** 경우	통상의 집회결의(**과반수**)

4. 공용부분의 사용

각 공유자는 공용부분을 **그 용도에 따라** 사용할 수 있다. "지분의 비율로" 사용하는 것이 아니다(민법상 공유와의 결정적 차이).

공용부분의 무단 독점사용에 대한 구제

구분소유자 1인이 **관리단집회의 결의나 적법한 사용권원 없이** 공용부분을 배타적·독점적으로 사용하는 경우,

- 다른 구분소유자들은 그 사용의 **중지를 청구**할 수 있다. **(가능)**
- 다른 구분소유자들은 지분비율에 따라 부당이득반환을 청구할 수 있다. **(가능)**
- 그러나 공용부분을 **자신에게 인도할 것을 청구할 수는 없다**. **(불가)** 공용부분은 구분소유자 전원의 공용에 제공된 것이어서 특정인에게 인도시킬 수 없기 때문이다.

5. 분할청구의 금지

공용부분은 구분소유자 전원의 공용에 제공되므로 **분할청구를 할 수 없다**. 마찬가지로 건물의 대지 공유자는 건물 사용에 필요한 범위 내의 대지에 대하여는 분할청구를 하지 못한다.

6. 민법상 공유 규정 vs 집합건물법상 공용부분 규정 비교

비교 기준	민법상 공유	집합건물법상 공용부분
지분비율	**균등한 것으로 추정**	**전유부분의 면적 비율**
지분의 처분	지분 처분 **자유**	**전유부분의 처분에 따름(분리처분 불가)**
변경(공유물의 변경)	공유자 **전원의 동의**	관리단집회의 결의(사안별 과반수 · 4분의 3 · 5분의 4 등)
사용	**지분의 비율**로 사용	**용도에 따라** 사용
분할청구	원칙적으로 **자유**	**불가능**

두문자·암기법

"지·처·변·사·분" 5개 기준으로 비교표를 세로로 외운다. 집합건물 쪽 답은 **"면적 → 따름 → 집회결의 → 용도 → 불가"**. 민법 공유 쪽 답은 **"균등 → 자유 → 전원동의 → 지분비율 → 자유"**로 대비시켜 외운다.

제3절 대지사용권 ★★

1. 의의와 성질

대지사용권은 구분소유자가 전유부분을 소유하기 위하여 건물의 대지에 대하여 가지는 권리이다. 전유부분과 **운명을 같이하는 종속적 권리**이다.

2. 분리처분의 금지와 예외

1. **원칙**: 구분소유자는 그가 가지는 전유부분과 분리하여 대지사용권을 처분할 수 **없다**.
2. **예외**: 규약 또는 공정증서로 달리 정한 경우에는 **분리처분이 가능**하다.

3. 저당권의 효력 범위

전유부분에 설정된 **저당권의 효력**은 특별한 사정이 없는 한 **그 대지사용권에도 미친다**. 전유부분만을 경매로 취득한 자는 대지사용권도 함께 취득하게 된다.

핵심 암기

대지사용권 3단 논법: **(1)** 원칙 분리처분 금지 → **(2)** 예외 규약·공정증서로 가능 → **(3)** 전유부분 저당권의 효력은 대지사용권에 미침. 또한 **대지 공유자는 건물 사용에 필요한 범위의 대지에 대하여 분할청구를 하지 못한다**.

제4절 관리단 · 관리인 · 관리위원회 ★★

1. 관리단

관리단은 건물에 대하여 구분소유관계가 성립하면 **구분소유자 전원을 구성원으로 하여 당연히 성립**한다. 별도의 설립결의나 조직행위를 필요로 하지 않는다.

2. 관리인

- 구분소유자가 **10인 이상**일 때에는 관리인을 **반드시 선임하여야 한다**.
- 관리인은 구분소유자일 필요가 없다. 즉 **구분소유자가 아닌 자도 관리인이 될 수 있다**.

3. 관리위원회

관리위원회의 위원은 **구분소유자 중에서 선출**한다. 관리인과 달리 **구분소유자가 아닌 자는 관리위원회 위원이 될 수 없다**는 점이 대비 포인트이다.

함정 주의

관리인은 구분소유자가 **아니어도** 되지만, **관리위원회 위원**은 **구분소유자 중에서** 선출한다. "관리인은 구분소유자여야 한다"거나 "관리위원회 위원은 구분소유자가 아니어도 된다"는 지문은 모두 틀린 지문이다.

제5절 관리단집회의 결의정족수 ★★★

1. 결의정족수 정리표

사항	정족수	비고
공용부분의 **경미한 변경**(소유권 비율에 영향 없음)	**과반수**	통상의 집회결의
공용부분의 **중대한 변경**(소유권 비율에 영향 있음)	**각 4분의 3 이상**	구분소유자 및 의결권

규약의 설정 · 변경 · 폐지	**각 4분의 3 이상**	구분소유자 및 의결권
법 위반행위자에 대한 **전유부분의 경매청구**	**각 4분의 3 이상**	구분소유자 및 의결권
재건축의 결의	**각 5분의 4 이상**	구분소유자 및 의결권

사항	정족수	비고
관리단집회 **소집통지의 생략**	**구분소유자 전원의 동의**	전원동의 시 절차 생략
공용부분의 **분할**	자료 확인 필요	공용부분은 원칙적으로 분할청구 불가
임시 관리단집회의 소집청구	자료 확인 필요	일정 비율 이상의 구분소유자 청구로 소집 가능

위 표의 "자료 확인 필요" 항목은 본 요약노트의 근거자료만으로는 구체적 분수를 확정할 수 없는 부분이므로, 법령 원문으로 반드시 확인한 후 보충하여야 한다. 시험장에서 확신 없는 분수를 찍어 적는 것보다, 확실한 **4분의 3**과 **5분의 4**를 정확히 구별하는 것이 실익이 크다.

두문자·암기법

"규 · 경 · 중 → 3/4 / 재건축만 4/5" - 규약 설정·변경, 경매청구, 중대한 변경은 모두 **각 4분의 3**. 오직 **재건축결의**만 **각 5분의 4**. 그리고 소집통지 생략은 **전원동의**.

2. 재건축결의

- 재건축의 결의는 관리단집회에서 **구분소유자 및 의결권의 각 5분의 4 이상**의 결의에 따른다.
- 단지 내 여러 동의 건물을 **일괄하여 재건축**하는 경우에는 전체 구분소유자 및 의결권의 5분의 4 이상의 결의 외에, 각 동별로도 5분의 4 이상의 요건을 충족하여야 한다.

핵심 암기

일괄 재건축 = **"전체 5분의 4 + 각 동별 5분의 4"**. 전체 요건만 충족하면 된다는 지문은 틀린 지문이다.

제6절 관리비의 승계 ★★★

1. 특별승계인의 관리비 승계 범위

구분	특별승계인에 대한 승계 여부
공용부분에 관한 체납관리비	**승계 O**
공용부분 관리비에 대한 **연체료**	**승계 O**(공용부분 관리비에 포함)
전유부분에 관한 체납관리비	**승계 X**

2. 공용부분에 관한 권리의 승계

구분소유자가 공용부분에 관하여 다른 구분소유자에 대하여 가지는 채권은 그 특별승계인에 대하여도 행사할 수 있다.

함정 주의

"체납된 **전유부분** 관리비도 특별승계인이 승계한다"는 지문은 **틀린 지문**이다. 승계되는 것은 공용부분에 관한 관리비(연체료 포함)에 한정된다. 반대로 "**공용부분** 관리비는 승계되지 않는다"는 지문도 틀린 지문이므로, 어느 쪽을 물어도 **공용부분 = 승계, 전유부분 = 불승계**로 답한다.

기출·모의 지문 OX

1. 구분소유권이 성립하기 위해서는 구조상·이용상의 독립성과 구분행위 외에 집합건물의 표시에 관한 등기를 하여야 한다. → X (판례상 독립성 + 구분행위만으로 성립하고 등기는 성립요건이 아니다)
2. 구조상 공용부분은 그 취지의 등기가 있어야 공용부분으로 인정된다. → X (구조상 공용부분은 등기 없이도 당연히 공용부분이 된다)
3. 규약상 공용부분에 관한 물권변동의 효력은 그 취지의 등기를 하여야 발생한다. → O (원래 전유부분이 될 수 있는 부분이므로 등기가 필요하다)
4. 공용부분에 대한 각 구분소유자의 지분은 균등한 것으로 추정된다. → X (전유부분의 면적 비율에 따른다. 균등추정은 민법상 공유의 법리이다)
5. 공용부분에 대한 지분은 규약으로 정하면 전유부분과 분리하여 처분할 수 있다. → X (공용부분 지분은 규약으로도 분리처분할 수 없다. 대지사용권과 구별)
6. 각 구분소유자는 공용부분 전부를 지분의 비율로 사용할 수 있다. → X (지분의 비율이 아니라 그 용도에 따라 사용할 수 있다)
7. 구분소유자는 공용부분에 대하여 분할을 청구할 수 있다. → X (공용부분은 전원의 공용에 제공되므로 분할청구가 불가능하다)
8. 구분소유자의 소유권 비율에 영향을 미치는 공용부분의 변경은 관리단집회에서 구분소유자 및 의결권의 각 4분의 3 이상의 결의로 한다. → O (중대한 변경의 특별정족수이다)
9. 대지사용권은 규약이나 공정증서로 달리 정하지 않는 한 전유부분과 분리하여 처분할 수 없다. → O (원칙 분리처분 금지, 예외적으로 규약·공정증서로 분리처분 가능)
10. 전유부분에 설정된 저당권의 효력은 특별한 사정이 없는 한 대지사용권에도 미친다. → O (대지사용권은 전유부분에 종속하는 권리이다)
11. 구분소유자 1인이 관리단집회의 결의나 적법한 사용권한 없이 공용부분을 배타적으로 점유·사용하는 경우, 다른 구분소유자는 그 공용부분을 자신에게 인도할 것을 청구할 수 있다. → X (인도청구는 불가하고, 사용의 중지 청구와 지분비율에 따른 부당이득반환 청구만 가능하다)
12. 관리단은 구분소유관계가 성립하면 별도의 조직행위 없이도 당연히 성립한다. → O (구분소유자 전원을 구성원으로 하는 당연설립단체이다)
13. 구분소유자가 10인 이상일 때에는 관리인을 선임하여야 하며, 관리인은 구분소유자가 아니어도 된다. → O (관리인의 필수 선임요건과 자격의 무제한)
14. 관리위원회의 위원은 구분소유자가 아닌 자 중에서도 선출할 수 있다. → X (관리위원회 위원은 구분소유자 중에서 선출한다. 관리인과 구별)
15. 재건축의 결의는 관리단집회에서 구분소유자 및 의결권의 각 5분의 4 이상의 결의에 따른다. → O (집합건물법상 가장 무거운 정족수이다)
16. 규약의 설정·변경·폐지와 법 위반행위자에 대한 전유부분 경매청구는 모두 구분소유자 및 의결권의 각 4분의 3 이상의 결의를 요한다. → O (4분의 3 정족수 그룹으로 묶어 정리한다)
17. 관리단집회는 구분소유자 전원이 동의하면 소집절차를 거치지 않고 소집할 수 있다. → O (전원동의에 의한 소집통지 생략이 인정된다)
18. 체납된 전유부분 관리비의 지급의무는 특별승계인에게 승계된다. → X (전유부분 관리비는 승계되지 않고, 공용부분 관리비만 승계된다)

마무리 점검: **(1)** 등기 요부는 "규약상 공용부분만 필요", **(2)** 공용부분 5대 기준은 "면적·따름·집회결의·용도·불가", **(3)** 정족수는 "4분의 3 그룹 3개 + 재건축 5분의 4 + 소집통지 생략 전원동의", **(4)** 관리비는 "공용부분 승계·전유부분 불승계". 이 네 줄만 정확하면 집합건물법은 실전에서 사실상 완성된다.

제15장 가등기담보 등에 관한 법률

제1절 가등기담보법의 의의와 적용범위 ★★★

1. 가등기담보권의 개념과 구조

채권자와 채무자 사이에 **금전소비대차계약**이 체결되면서, 채무자(또는 물상보증인) 소유의 부동산에 **채권자 명의의 가등기**를 설정해 두는 방식의 담보를 **가등기담보**라 한다. 채무자가 변제하지 않으면 채권자가 가등기에 기한 본등기를 하여 소유권을 취득하는 구조이므로, 외형은 대물변제예약·매매예약이지만 실질은 담보이다.

- 등기부상 순위 – 1순위: 소유자(채무자 또는 물상보증인), 2순위: 가등기권리자(채권자), 3순위: 후순위 저당권자 등 다른 채권자
- 동일한 구조에서 가등기 대신 **소유권이전등기**(매매 형식)를 미리 경료해 두는 것이 **양도담보**이다. 등기의 형식만 다를 뿐 담보라는 실질은 같으므로 두 경우 모두 가등기담보법이 적용된다.
- 가등기담보법은 폭리적 대물변제를 막기 위해 **청산의무**를 강제하는 법률이며, 그 결과 가등기담보권·양도담보권은 실질적으로 저당권과 같이 취급된다.

2. 가등기담보법의 적용요건

(1) 초과담보일 것 - 목적물 가액 > 피담보채권액

예약(담보계약 체결) 당시 목적물의 가액이 **차용액(대여원본) + 이에 붙인 이자**의 합산액을 **초과**하는 경우에만 적용된다. 목적물 가액이 채권액에 미달하는 부족담보의 경우에는 폭리의 위험이 없으므로 이 법이 적용되지 않는다.

- 목적물 가액을 산정할 때 **선순위 담보권의 피담보채권액은 공제**한다. 선순위 저당권이 있으면 그 채권액을 뺀 나머지 가액과 대여금을 비교한다.
- **가액 산정시기의 구별** – 적용 여부 판단은 **예약(계약체결) 당시**의 가액, 청산금 산정은 **실행통지 당시(청산 시)**의 가액을 기준으로 한다.

(2) 소비대차(준소비대차)에 기한 채권을 담보할 것

이 법은 **소비대차 또는 준소비대차에 기한 채권**을 담보할 목적인 경우에만 적용된다. 따라서 소비대차에 기하지 않은 채권을 담보하는 가등기에는 적용되지 않는다.

- **매매대금채권** 담보 목적의 가등기(예: 매매대금 지급을 담보하기 위하여 매도인 명의로 경료한 가등기) → **적용 안 됨**
- **공사대금채권** 담보 목적의 가등기 → **적용 안 됨**
- 대여금채권 담보 목적의 가등기 → 적용됨

(3) 등기·등록이 경료되었을 것

채권자 명의로 **가등기 또는 소유권이전등기**가 마쳐진 경우에 비로소 적용된다. 담보계약(예약)만 체결하고 채권자 명의의 등기를 하지 않은 상태에서는 이 법이 적용되지 않으므로, 그 상태에서 청산절차 없이 목적물을 처분하였더라도 가등기담보법 위반이라고 할 수 없다.

(4) 목적물이 등기·등록할 수 있는 재산(부동산)일 것

가등기담보법은 부동산 담보에 관한 법이므로, 담보목적물이 **동산**인 경우(동산 양도담보)에는 적용되지 않는다.

구분	적용 O	적용 X
피담보채권	대여금(소비대차·준소비대차)	매매대금, 공사대금
담보가치	목적물 가액 > 원본+이자(초과담보)	목적물 가액 ≤ 채권액(부족담보)
등기	가등기·소유권이전등기 경료	예약만 하고 등기 안 한 경우
목적물	부동산 등 등기·등록 가능 재산	동산

두문자·암기법

"소·초·등·부" – **소**비대차 채권 / **초**과담보 / **등**기 경료 / **부**동산. 네 가지가 모두 갖추어져야 가등기담보법이 적용된다. 하나라도 빠지면 민법의 일반원칙(대물변제예약·양도담보 법리)으로 해결한다.

함정 주의

"매매대금채권을 담보할 목적으로 경료된 가등기에도 가등기담보법이 적용된다"는 지문은 **틀린 서술**이다. 또한 "담보계약을 체결하였으나 채권자 명의의 등기를 하지 않은 경우에도 청산절차 없이 처분하면 가등기담보법 위반이다"도 **틀린 서술**이다(등기가 없으면 애초에 법 적용 대상이 아니다).

제2절 가등기담보권의 실행과 청산절차 ★★★

1. 실행방법 - 귀속청산 원칙, 처분청산 불허

- **사적 실행(권리취득에 의한 실행)**은 **귀속청산**만 허용된다. 채권자가 목적물의 소유권을 취득하되 정당한 청산금을 지급하는 방식이다.
- 청산절차를 거치지 않고 채권자가 임의로 목적물을 처분하여 대금에서 변제받는 **처분청산(처분정산형 사적 실행)은 허용되지 않는다**.
- **공적 실행**으로서 경매를 신청하는 것은 가능하며, 경매절차에서 담보가등기는 저당권으로 본다.

2. 청산절차의 4단계 흐름 ★★★

단계	내용	핵심 포인트
① 변제기 도래	피담보채무의 변제기가 지나야 실행 가능	변제기 전 실행통지는 효력 없음
② 실행통지	청산금의 평가액을 통지(청산금이 없으면 없다는 뜻을 통지)	채무자·물상보증인·제3취득자 **전원**에게
③ 청산기간	통지가 **도달한 날부터 2개월** 경과	기간 중 본등기는 **무효**
④ 청산금 지급	정당하게 평가된 청산금을 지급	지급 전까지 채무자는 말소청구 가능
⑤ 본등기·인도	소유권이전 본등기 및 목적물 인도	청산금 지급과 **동시이행**

흐름 한 줄 정리: **변제기 도래 → 실행통지(청산금 평가액 통지) → 도달일부터 2개월의 청산기간 경과 → 청산금 지급 → 본등기 및 인도(청산금 지급과 동시이행)**

3. 실행통지

(1) 통지의 상대방

통지는 **채무자, 물상보증인, 담보가등기 후 소유권을 취득한 제3취득자**(등기부에 그 권리를 취득한 것으로 기록된 자) **모두에게** 하여야 한다. 채무자에게만 통지하고 물상보증인에게 하지 않으면 적법한 실행통지가 되지 못한다.

(2) 통지의 내용과 효력

- 채무자에게 지급할 **청산금이 없다고 인정되는 경우에도 통지를 생략할 수 없다**. 이때는 "청산금이 없다"는 취지를 통지하여야 한다.
- 채권자가 통지한 청산금의 액수가 **객관적인 가액에 미달**하더라도 그 통지는 **실행통지로서의 효력이 있다**. 다만 채무자는 정당하게 평가된 청산금을 청구할 수 있다.
- 채권자는 자기가 통지한 청산금의 액수에 대하여 **스스로 다툴 수 없다**(자기모순 금지). 반면 **채무자는 그 액수를 다툴 수 있다**.
- 채무자에게 지급할 청산금이 없는 경우, 목적물의 **사용·수익권은 청산기간이 만료한 날부터** 채권자에게 이전된다.

핵심 암기

통지 3원칙 - ① 청산금이 없어도 통지는 필수, ② 과소평가 통지도 통지로서는 유효, ③ 채권자는 못 다투고 채무자는 다툴 수 있다.

4. 청산금의 산정

청산금 = **실행통지 당시(청산 시)의 목적물 가액 - 피담보채권액(원본·이자·비용) - 선순위 담보권의 피담보채권액**. 적용 여부를 가릴 때의 기준시(예약 당시)와 청산금을 계산할 때의 기준시(실행통지 당시)가 **다르다**는 점이 반복 출제된다.

계산 예제

甲이 乙에 대한 **3억원**의 채권을 담보하기 위하여 乙 소유 X부동산에 담보가등기를 경료하였다. X부동산의 가액이 **예약 당시 5억원**, **실행통지 당시 4억원**인 경우(선순위 담보권은 없다고 가정)

- 법 적용 여부 판단 → **예약 당시** 5억원 > 3억원이므로 초과담보 → 가등기담보법 **적용**
- 청산금 산정 → **실행통지 당시** 가액 기준: 4억원 - 3억원 = **1억원**
- 甲은 1억원을 지급하여야 하고, 그 지급과 상환으로 본등기와 인도를 청구할 수 있다.

예약 당시 가액 5억원을 기준으로 2억원이라고 계산하면 틀린다.

5. 청산기간과 본등기의 효력

- 실행통지가 **도달한 날부터 2개월**이 지나야 청산금을 지급하고 본등기를 할 수 있다.
- 청산기간(2개월) 경과 전에 채권자가 경료한 **본등기는 효력이 없다**.
- 청산절차를 전혀 거치지 않고 경료한 본등기도 **무효**이다. 다만 판례는 그 후 **적법한 청산절차를 완료하면** 실체관계에 부합하는 등기가 되어 유효로 될 수 있다고 한다(하자의 치유).
- 청산기간이 지난 후 청산금을 지급하고 한 본등기는 **유효**하다.
- 청산금의 지급의무와 소유권이전등기·인도의무는 **동시이행관계**에 있다.

함정 주의

"청산기간이 지나기 전에 한 본등기라도 나중에 청산금을 지급하면 처음부터 유효하다"는 식의 지문은 주의해야 한다. **본등기 당시에는 무효**이고, 이후 적법한 청산절차가 완료된 때에 실체관계 부합으로 유효하게 될 수 있을 뿐이다.

제3절 채무자 등의 보호와 후순위권리자 보호 ★★

1. 채무자의 말소청구권(수의변제권)

채무자 등은 **청산금을 지급받을 때까지** 채무액(원본·이자·손해금)을 전액 변제하고 담보가등기의 **말소를 청구할 수 있다**. 따라서 청산기간이 경과한 후라도 채권자가 아직 청산금을 지급하지 않았다면 채무자는 채무 전액을 변제하고 가등기 말소를 청구할 수 있다.

2. 후순위권리자의 보호

- **경매청구권** - 후순위 저당권자 등은 청산기간 중 자기 채권의 변제기가 도래한 경우에 한하여 목적물의 경매를 청구할 수 있다. 변제기가 도래하기 전에는 경매를 청구할 수 없다.
- **본등기 저지효** - 청산기간 중(청산절차 진행 중)에 경매신청이 있으면 **채권자는 본등기를 청구할 수 없다**. 청산금을 지급하더라도 마찬가지이다.
- **경매에서의 지위** - 경매가 개시되면 담보가등기는 저당권으로 본다. 가등기담보권자는 그 순위에 따라 우선변제를 받는다.
- **채권신고** - 가등기담보권자가 **채권신고를 하지 않으면 배당을 받을 수 없다**. 우선변제받을 채권액은 경매신청등기 전(배당요구 종기까지) 신고한 채권액을 기준으로 확정된다.
- 피담보채권이 완제되지 않은 가등기담보권이라도 **경매로 소멸**한다(저당권으로 보기 때문). "소멸하지 않는다"는 지문은 틀린다.

핵심 암기

후순위권리자 보호 **"변·경·저·신"** - **변**제기 도래해야 경매청구 / 청산 중 **경**매신청 있으면 채권자 본등기 불가 / 경매에서 담보가등기는 **저**당권 / 채권**신**고 없으면 배당 없음.

3. 가등기담보권의 성질

- **수반성** - 가등기담보권은 피담보채권과 **분리하여 제3자에게 양도할 수 없다**.
- **제3자 명의의 가등기** - 채권자·채무자·제3자 사이의 합의가 있고 채권이 실질적으로 그 제3자에게 귀속된다고 볼 수 있는 특별한 사정이 있으면, 제3자 명의의 담보가등기도 **유효**하다.

제4절 양도담보 ★★

1. 양도담보권의 성질

- 목적물의 소유권은 **대외적으로는 채권자(양도담보권자)**에게 있으나, 채무자와의 관계(대내적)에서는 담보물권적 성격을 가진다(신탁적 소유권이전설).
- 양도담보권자에게 **우선변제권**이 인정된다(저당권과 유사하게 취급).
- 양도담보권자의 **물상대위**가 인정된다. 목적물이 멸실·훼손되어 발생한 **화재보험금 채권에 대하여 물상대위권을 행사할 수 있다**.

2. 사용·수익권과 과실수취권의 귀속

청산절차가 완료되기 전까지 목적물의 사용·수익권은 **설정자(채무자)**에게 있고, 양도담보권자에게는 과실수취권이 인정되지 않는다.
과실수취권은 **청산절차가 완료된 후**부터 채권자에게 귀속한다.

- 따라서 청산절차 완료 전에는 채권자가 **설정자로부터 목적물을 임차한 자에게 소유권에 기한 반환청구**를 할 수 없다.
- 다만 청산금이 없는 경우에는 청산기간이 만료한 날부터 사용·수익권이 채권자에게 이전한다.

3. 청산절차 없는 처분과 제3자 보호

양도담보권자가 청산절차를 거치지 않고 목적물을 제3자에게 처분하여 등기를 경료해 준 경우, **선의의 제3자 명의의 등기는 유효**하다.
따라서 설정자는 그 등기의 **말소를 청구할 수 없고**, 채권자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있을 뿐이다.

4. 채무 변제 후 말소등기청구권

채무자가 피담보채무 전부를 변제한 후 행사하는 소유권이전등기 **말소등기청구권**은, 설정자가 목적물을 계속 점유하고 있는 동안에는 소멸시효가 진행하지 않는다. 다만 점유를 상실하면 그때부터 **10년의 소멸시효**가 진행한다.

제5절 가등기담보권과 양도담보권의 비교 ★★

구분	가등기담보권	양도담보권
공시방법	담보가등기(예약 형식)	소유권이전등기(매매 형식)
등기부상 소유권	설정자에게 남아 있음	채권자 앞으로 이전됨
실행방법	청산 후 **본등기**	청산 후 **확정적 소유권 취득**
청산절차	실행통지 → 2개월 → 청산금 지급 → 본등기	실행통지 → 2개월 → 청산금 지급 → 소유권 확정
처분청산	사적 실행으로서 불허	불허(단 선의의 제3자는 보호)
사용·수익권	청산절차 완료 전까지 설정자	청산절차 완료 전까지 설정자
우선변제권·물상대위	인정(경매 시 저당권으로 봄)	인정
제3자 처분 시	본등기 전이므로 처분 자체가 곤란	선의의 제3자 등기 유효, 말소청구 불가

두 권리 모두 **담보물권적 성질**을 가지므로 수반성·불가분성·물상대위성이 인정되고, 피담보채권과 분리하여 양도할 수 없다는 점도 같다.

두문자·암기법

청산절차 순서 **"변→통→이(2)→청→본"** - **변**제기 도래, 실행**통**지, **2**개월 청산기간, **청**산금 지급, **본**등기. 마지막 두 단계는 동시이행으로 묶어서 기억한다.

기출·모의 지문 OX

1. 매매대금의 지급을 담보하기 위하여 경료한 가등기에는 가등기담보법이 적용되지 않는다. → O (매매대금채권은 소비대차에 기한 채권이 아니므로 공사대금채권과 마찬가지로 적용 대상이 아니다)
2. 담보계약은 체결하였으나 채권자 명의의 등기를 하지 않은 상태에서 청산절차 없이 목적물을 처분하였다면 가등기담보법 위반이다. → X (등기가 경료되지 않으면 가등기담보법 자체가 적용되지 않으므로 위반이라 할 수 없다)
3. 채무자에게 지급할 청산금이 없다고 인정되는 경우 채권자는 실행통지를 생략할 수 있다. → X (청산금이 없다는 뜻이라도 반드시 통지하여야 한다)
4. 채권자가 통지한 청산금의 액수가 객관적 가액에 미달하면 그 통지는 실행통지로서의 효력이 없다. → X (통지 자체는 유효하고, 채무자가 정당한 청산금을 청구할 수 있을 뿐이다)
5. 채권자는 자신이 통지한 청산금의 액수에 관하여 다툴 수 없으나, 채무자는 다툴 수 있다. → O (채권자 스스로 평가한 금액이므로 자기모순은 허용되지 않는다)
6. 실행통지는 채무자에게만 하면 되고 물상보증인에게는 할 필요가 없다. → X (채무자·물상보증인·제3취득자 모두에게 통지하여야 한다)
7. 실행통지가 도달한 날부터 2개월이 지나기 전에 채권자가 경료한 본등기는 효력이 없다. → O (2개월의 청산기간은 강행적으로 보장된다)
8. 청산절차를 거치지 않고 경료한 본등기라도 그 후 적법한 청산절차를 완료하면 유효로 될 수 있다. → O (실체관계에 부합하는 등기가 되어 하자가 치유된다는 것이 판례이다)
9. 청산금의 지급의무와 소유권이전등기 및 인도의무는 동시이행관계에 있다. → O (채무자 보호를 위한 동시이행항변권이 인정된다)
10. 청산기간이 지난 후라도 청산금을 지급받지 못한 채무자는 채무 전액을 변제하고 담보가등기의 말소를 청구할 수 있다. → O (청산금 지급 시까지 채무자의 말소청구권이 존속한다)
11. 피담보채권 3억원을 담보하는 가등기담보의 목적물 가액이 예약 당시 5억원, 실행통지 당시 4억원이라면 정당한 청산금은 2억원이다. → X (청산금은 실행통지 당시 가액을 기준으로 하므로 4억원-3억원=1억원이다)
12. 후순위 저당권자는 변제기 도래 여부와 관계없이 청산기간 중 경매를 청구할 수 있다. → X (자기 채권의 변제기가 도래한 경우에 한하여 경매를 청구할 수 있다)
13. 청산기간 중 후순위권리자가 경매를 신청한 경우에도 채권자는 청산금을 지급하면 본등기를 청구할 수 있다. → X (경매신청이 있으면 채권자는 본등기를 청구할 수 없다)
14. 담보가등기가 설정된 부동산이 경매되는 경우 가등기담보권자가 채권신고를 하지 않으면 배당을 받을 수 없다. → O (경매에서 담보가등기는 저당권으로 보며, 우선변제받을 채권액은 신고한 액수로 확정된다)
15. 피담보채권이 완제되지 않은 가등기담보권은 경매로 소멸하지 않는다. → X (담보가등기는 저당권으로 보므로 경매절차에서 소멸하는 것이 원칙이다)
16. 양도담보 목적물의 과실수취권은 담보권 설정 즉시 채권자에게 귀속한다. → X (청산절차가 완료된 후에 비로소 채권자에게 귀속하며, 그 전까지 사용·수익권은 설정자에게 있다)
17. 양도담보권자는 목적물의 멸실로 인한 화재보험금 채권에 대하여 물상대위권을 행사할 수 있다. → O (양도담보권에도 담보물권으로서 물상대위가 인정된다)
18. 양도담보권자가 청산절차를 거치지 않고 선의의 제3자에게 처분하여 등기를 경료해 준 경우 설정자는 그 등기의 말소를 청구할 수 있다. → X (선의의 제3자 명의의 등기는 유효하므로 말소청구는 불가하고 손해배상만 청구할 수 있다)

정리 - 가등기담보법 문제는 ① 적용요건(소비대차·초과담보·등기·부동산) 판단, ② 청산절차의 순서와 2개월 기간, ③ 청산금 산정 기준시(실행통지 당시), ④ 후순위권리자 보호, ⑤ 양도담보의 사용·수익권 귀속시기의 다섯 축에서 반복 출제된다.

제16장 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률

제1절 명의신탁의 개념과 적용범위 ★★

1. 명의신탁의 의의

명의신탁이란 **실권리자(신탁자)**가 부동산에 관한 물권을 보유하거나 사실상 취득하면서, 그에 관한 **등기는 타인(수탁자)의 명의로 하기로 하는 약정**을 말한다. 부동산실명법은 이러한 명의신탁약정과 **그에 따른 물권변동(등기)을 모두 무효**로 하여, 등기명의와 실체관계를 일치시키는 것을 목적으로 한다.

- 명의신탁약정의 무효(법 제4조 제1항) — 신탁자와 수탁자 사이의 약정 자체가 무효이다.
- 명의신탁약정에 따른 등기의 무효(법 제4조 제2항 본문) — 다만 **계약명의신탁에서 상대방(매도인)이 선의인 경우**에는 등기가 유효하다(같은 항 단서).
- 제3자에 대한 대항 불가(법 제4조 제3항) — 무효는 **선의·악의를 불문하고** 제3자에게 대항하지 못한다.

2. 명의신탁이 아닌 것 — 부동산실명법의 적용대상 자체가 아닌 경우

다음은 등기명의와 실질이 달라 보이더라도 부동산실명법상 명의신탁으로 보지 않는다. 따라서 무효 법리가 적용되지 않는다.

1. **양도담보** — 채무변제를 담보하기 위하여 채권자가 채무자로부터 소유권이전등기를 경료받은 경우
2. **가등기담보** — 담보 목적으로 가등기를 경료한 경우
3. **구분소유적 공유(상호명의신탁)** — 1필의 토지를 위치·면적으로 특정하여 구분소유하면서 등기만 공유지분으로 한 경우
4. **신탁법 또는 자본시장법상의 신탁** — 법률에 근거한 신탁등기

함정 주의

「청구권보전을 위한 **가등기를 제3자 명의로 하여 둔 경우**」는 담보가등기가 아니라 **가등기의 명의신탁**으로서 부동산실명법의 **적용대상에 해당**한다. "적용대상이 아닌 것"을 고르는 문제에서 이를 골라내면 틀린다.

함정 주의

종중·배우자·종교단체의 명의신탁은 **적용대상이기는 하되 특례로 유효**한 것이지, "적용대상이 아닌 것"이 아니다. 적용대상 제외(양도담보 등)와 특례로 유효(종중 등)를 다른 층위로 구별해야 한다.

두문자·암기법

적용대상 **아닌 것** = **「양·가·구·신」** (양도담보 · 가등기담보 · 구분소유적 공유 · 신탁법상 신탁)

제2절 예외적으로 유효한 명의신탁(특례) ★★

1. 특례의 요건

다음 세 유형은 **조세포탈·강제집행의 면탈·법령상 제한의 회피를 목적으로 하지 아니하는 경우**에 한하여 명의신탁약정과 등기가 모두 **유효**하다(법 제8조).

- **종중**이 보유한 부동산을 종중 외의 자(종원·종손 등) 명의로 등기한 경우
- **배우자** 명의로 부동산에 관한 물권을 등기한 경우
- **종교단체**의 명의로 그 산하조직이 보유한 부동산을 등기한 경우

함정 주의

여기서 **배우자는 법률상 배우자만**을 의미하며 **사실혼 배우자는 포함되지 않는다**. 또한 명의신탁 당시에는 사실혼이었다가 뒤에 혼인신고를 마친 경우, 유효로 되는 시점은 **혼인한 때부터 장래를 향하여**이고 약정 당시로 소급하지 않는다.

2. 유효한 명의신탁의 법률관계

특례로 유효한 명의신탁에서는 **내부적 소유권은 신탁자**에게, **대외적 소유권은 수탁자**에게 귀속한다. 이 구조에서 나오는 결론들이 그대로 지문이 된다.

쟁점	결론	이유
신탁자의 소유권에 기한 말소등기청구	불가	대외적 소유자가 아니므로 물권적 청구권이 없음
명의신탁 해지를 원인으로 한 등기청구	가능	약정이 유효하므로 해지권 행사 가능
진정명의회복을 원인으로 한 이전등기청구	가능	해지의 효과로 실체관계에 부합
불법점유 제3자에 대한 직접 반환청구	불가	대외적 소유자인 수탁자가 행사해야 함
수탁자로부터 취득한 제3자의 보호	선의·악의 불문 보호	수탁자가 대외적 소유자이므로 유효한 처분

핵심 암기

유효한 명의신탁(종중·배우자·종교단체) → **"소유권에 기한 청구는 ×, 해지를 원인으로 한 청구는 ○"**. 무효인 명의신탁(양자간) → **"소유권에 기한 청구는 ○, 해지라는 개념 자체가 ×"**. 두 축을 뒤집어 출제하는 것이 전형이다.

제3절 양자간 명의신탁 ★★

1. 구조

이미 신탁자 甲의 소유인 부동산에 관하여 甲과 乙이 명의신탁약정을 맺고 **甲 → 乙로 소유권이전등기**를 경료하는 가장 기본적인 형태이다(이전형 명의신탁).

2. 법률관계

1. 명의신탁약정은 **무효**이고, 그에 따른 **乙 명의의 등기도 무효**이다.
2. 따라서 **내부적으로도 외부적으로도 소유자는 여전히 신탁자 甲**이다.
3. 甲은 乙에게 **소유권에 기한 방해배제청구권(말소등기청구권)**을 행사할 수 있고, 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구도 가능하다.
4. 제3자가 목적물을 불법점유하는 경우 **甲이 직접** 물권적 청구권을 행사할 수 있다(甲이 소유자이므로).
5. 乙이 목적물을 제3자 丁에게 처분한 경우, **丁은 선의·악의를 불문하고 유효하게 소유권을 취득**한다(법 제4조 제3항). 이때 甲은 乙에게 불법행위에 기한 손해배상이나 부당이득의 반환을 구할 수 있을 뿐이다.

핵심 암기

양자간 명의신탁에서 **등기가 무효**이므로 "해지"라는 개념은 성립하지 않는다. 물권변동이 처음부터 없었으므로 **해지가 아니라 소유권에 기한 말소청구**의 문제이다.

핵심 암기

명의신탁약정에 따라 수탁자 앞으로 이전된 부동산은 **불법원인급여에 해당하지 않는다**. 그러므로 신탁자의 반환청구(말소청구)가 봉쇄되지 않는다.

3. 보호되지 않는 "제3자"

법 제4조 제3항의 제3자는 **수탁자가 물권자임을 기초로 새로운 이해관계를 맺은 자**를 말한다. 따라서 **신탁자와 매매계약을 체결하고 편의상 수탁자로부터 등기명의만 이전받은 외관을 갖춘 자**는 여기의 제3자에 해당하지 않아 보호되지 않는다.

제4절 3자간 등기명의신탁(중간생략등기형) ★★★

1. 구조

신탁자 甲이 **매도인 丙과 직접 매매계약**을 체결하되, 등기만은 명의신탁약정에 따라 **丙으로부터 수탁자 乙 앞으로 직접 이전**받아 두는 형태이다. 계약당사자가 甲이라는 점이 계약명의신탁과 결정적으로 다르다.

2. 법률관계 — 사례로 정리

[사례] 甲과 乙이 명의신탁약정을 하고, 甲이 丙으로부터 매수한 X토지의 등기를 乙이 丙으로부터 직접 경료받았다.

1. 甲·乙의 **명의신탁약정은 무효**이다.
2. 乙 명의의 **등기도 무효**이다. 따라서 **X토지의 소유자는 여전히 매도인 丙**이다.
3. **甲과 丙 사이의 매매계약은 유효**하다. 명의신탁약정의 무효가 매매계약까지 무효로 만들지는 않는다.
4. 丙은 소유자로서 **乙에게 말소등기를 청구할 수 있다.**
5. 甲은 乙에게 **직접 말소등기를 청구할 수 없다**. 甲과 乙 사이에는 매매 등 아무런 계약관계가 없고, 甲이 소유자도 아니기 때문이다.
6. 甲은 丙에 대한 **매매계약상 소유권이전등기청구권을 피보전채권**으로 하여, **丙을 대위하여 乙 명의 등기의 말소를 청구**할 수 있고, 이어 丙에게 자신 앞으로의 이전등기를 청구할 수 있다.
7. 乙로부터 X토지를 매수하여 등기를 이전받은 丁은 **선의·악의를 불문하고** 소유권을 취득한다.

> **핵심 암기**
> 3자간 등기명의신탁의 구제 경로 = **"직접청구 ×, 대위청구 ○"**. 甲 → (丙 대위) → 乙 말소 → 丙 → 甲 이전등기. 이 화살표 순서를 그대로 외운다.

한편 甲이 X토지를 **인도받아 점유를 계속하고 있는 동안**에는 丙에 대한 소유권이전등기청구권의 **소멸시효가 진행하지 않는다**(점유하는 매수인의 등기청구권 법리). 乙이 목적물을 임의처분한 경우 제3취득자는 유효하게 취득하고, 乙이 받은 처분대금은 신탁자에 대한 부당이득 내지 불법행위의 문제로 처리된다.

제5절 계약명의신탁 ★★★

1. 구조

신탁자 甲이 자금을 제공하고, **수탁자 乙이 자기 이름으로 매도인 丙과 매매계약**을 체결한 뒤 등기도 乙 명의로 경료하는 형태이다. 계약당사자가 乙이므로, 상대방인 丙이 명의신탁 사실을 알았는지 여부에 따라 결론이 정반대로 갈린다.

2. 매도인 丙이 선의인 경우 — 수탁자가 유효하게 소유권 취득

1. 甲·乙의 **명의신탁약정은 여전히 무효**이다. 丙이 선의라 하여 약정까지 유효로 되는 것이 **아니다**.
2. 다만 법 제4조 제2항 단서에 의하여 **乙 명의의 등기는 유효**하고, 乙이 **완전한 소유권**을 취득한다.
3. 甲은 乙에게 **소유권이전등기나 말소등기를 청구할 수 없다.** 물권적 청구권도, 계약상 청구권도 없기 때문이다. 명의신탁약정에서 "甲의 요청이 있으면 등기를 넘겨준다"고 정하였더라도 그 약정 자체가 무효이므로 이행을 구할 수 없다.
4. 甲은 丙을 대위하여 말소를 구할 수도 **없다**. 丙·乙 사이의 매매가 유효하여 **피보전채권이 존재하지 않기 때문**이다.
5. 甲의 구제수단은 **乙에게 제공한 매수자금 상당액의 부당이득반환청구**뿐이다.
6. 乙이 목적물을 임의처분하여도 **유효**하며, 제3자 丁은 선의·악의 불문 소유권을 취득한다. 乙이 얻은 처분대금을 甲에게 반환할 의무는 없고, 甲은 제공한 자금 상당액만 청구할 수 있다.

> **함정 주의**
> 丙이 **계약 체결 당시에는 선의**였다면, 그 후 명의신탁 사실을 **알게 되더라도 이미 유효하게 성립한 乙의 소유권 취득은 번복되지 않는다**. 선의·악의의 판단 시점은 계약 체결 시이다.

> **함정 주의**
> 甲이 매수자금 반환채권을 확보하기 위하여 목적 부동산에 **유치권**을 주장하는 지문이 자주 나온다. 매수자금 반환채권은 **그 부동산에 관하여 생긴 채권(견련성)이 아니므로** 유치권은 성립하지 않는다.

3. 매도인 丙이 악의인 경우 — 수탁자는 소유권을 취득하지 못함

- 명의신탁약정이 무효일 뿐 아니라 **丙·乙 사이의 매매계약 자체가 무효**가 되어, 乙 명의의 등기도 무효이다.
- 소유자는 여전히 **丙**이므로, 丙은 乙에게 **말소등기를 청구할 수 있다.**
- 甲은 乙에게 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 없다. 甲은 丙과 아무런 계약관계가 없어(계약당사자는 乙) 3자간 등기명의신탁처럼 대위구조로 목적물을 회복하기도 어렵고, 결국 **乙에 대한 매수자금 반환청구**에 그친다.
- 제3자가 乙로부터 취득한 경우에는 **선의·악의 불문 유효**하게 소유권을 취득한다(법 제4조 제3항).

4. 경매를 통한 계약명의신탁

甲이 자금을 제공하고 **乙이 경매절차에서 매수인(낙찰자)**이 되어 소유권이전등기를 마친 경우도 **계약명의신탁**에 해당한다.

- 甲·乙의 **명의신탁약정은 무효**이다.
- 그러나 경매의 특수성상, **경매목적물의 소유자나 제3자가 명의신탁 사실을 알았는지 여부와 관계없이** 매수인 乙은 **유효하게 소유권을 취득**한다.
- 甲의 구제수단은 **乙에게 지급한 경락대금 상당액의 부당이득반환청구**이다.
- 甲이 그 부동산을 점유하더라도 소유의 의사가 인정되지 않아 **타주점유**이다.

두문자·암기법

계약명의신탁 결론 = **「약정은 언제나 무효, 등기는 상대방 선의면 유효」**. 경매는 **「상대방을 따지지 않고 언제나 수탁자 유효취득」**.

제6절 세 가지 유형 종합비교 ★★★

구분	양자간 명의신탁	3자간(중간생략등기형)	계약명의신탁(매도인 선의)	계약명의신탁(매도인 악의)
계약당사자	해당 없음	신탁자 甲	수탁자 乙	수탁자 乙
명의신탁약정의 효력	무효	무효	무효	무효
매매계약의 효력	해당 없음	유효(甲·丙)	유효(乙·丙)	무효
수탁자 명의 등기	무효	무효	유효	무효
소유권 귀속	신탁자 甲	매도인 丙	수탁자 乙	매도인 丙
신탁자의 수탁자에 대한 직접 말소·이전청구	가능(소유권에 기하여)	불가	불가	불가
신탁자의 대위청구	불필요	가능(丙 대위)	불가(피보전채권 없음)	부정
신탁자의 최종 구제수단	말소등기·진정명의회복	丙 대위 말소 후 丙에게 이전등기청구	매수자금 상당액 부당이득반환	매수자금 상당액 부당이득반환
수탁자의 임의처분과 제3자	선악 불문 유효취득	선악 불문 유효취득	선악 불문 유효취득	선악 불문 유효취득

핵심 암기

제3자 보호는 네 유형 모두 동일하게 "선의·악의 불문 유효취득"이다. 사례형에서 마지막 지문은 거의 언제나 이 결론으로 끝난다. 차이가 생기는 지점은 오직 ① **등기의 효력** ② **소유권의 귀속** ③ **신탁자의 구제수단** 세 가지뿐이다.

두문자·암기법

소유자 찾기 = **「양자간은 甲, 3자간은 丙, 계약형은 선의면 乙·악의면 丙」** → **「양甲·삼丙·계선乙」**

제7절 구분소유적 공유(상호명의신탁) ★

1. 의의

1필의 토지를 위치와 면적을 특정하여 **구분소유하기로 하면서** 등기만은 각자의 면적 비율에 따른 **공유지분등기**를 마친 경우를 말한다. 서로 상대방 구분부분에 관하여 지분등기를 보유하는 형태이므로 **상호명의신탁**이라 부르며, 부동산실명법의 적용대상에서는 제외된다.

2. 법률관계

- **대내적**으로는 각자가 자신의 특정 구분부분을 **단독소유**한다. 따라서 다른 공유자의 동의 없이 자신의 구분부분을 **배타적으로 사용·수익**할 수 있다.
- **대외적**으로는 공유관계로 취급되어, 지분의 처분은 유효하다.
- 구분부분을 **불법점유**하는 자에 대한 반환청구나 손해배상청구는 **그 구분부분을 소유하는 자만** 할 수 있고, 다른 구분소유자는 할 수 없다.
- 관계를 해소하려면 **공유물분할청구가 아니라** 상호명의신탁의 **해지를 원인으로 한 지분이전등기청구**에 의한다.

> **함정 주의**
> "구분소유적 공유자는 **공유물분할청구권**을 행사할 수 있다"는 지문은 **틀린 지문**이다. 통상의 공유와 구별할 것.

기출·모의 지문 OX

1. 채무의 변제를 담보하기 위하여 채권자가 채무자로부터 소유권이전등기를 경료받은 경우, 이는 부동산실명법상 명의신탁에 해당하여 등기가 무효이다. → X (양도담보로서 부동산실명법의 적용대상 자체가 아니다)
2. 가등기담보, 구분소유적 공유, 신탁법상의 신탁은 부동산실명법상 명의신탁에 해당하지 않는다. → O (적용대상 제외 사유)
3. 청구권보전을 위한 가등기를 제3자 명의로 하여 둔 경우는 부동산실명법의 적용대상이 아니다. → X (가등기의 명의신탁으로서 적용대상에 해당한다)
4. 조세포탈 등의 목적 없이 종교단체의 산하조직이 보유한 부동산을 그 종교단체 명의로 등기한 경우, 그 명의신탁은 유효하다. → O (법 제8조 특례)
5. 부동산실명법상 특례가 인정되는 배우자에는 사실혼 배우자도 포함된다. → X (법률상 배우자만 해당한다)
6. 명의신탁약정의 당사자가 그 후 혼인신고를 마친 경우, 명의신탁약정은 약정 당시로 소급하여 유효로 된다. → X (혼인한 때부터 장래를 향하여 유효로 될 뿐 소급하지 않는다)
7. 명의신탁약정에 의하여 신탁자가 수탁자에게 등기를 이전한 부동산은 불법원인급여물에 해당한다. → X (불법원인급여가 아니므로 신탁자의 반환청구가 인정된다)
8. 신탁자와 매매계약을 체결하고 수탁자로부터 등기명의만 이전받은 외관을 갖춘 자는, 명의신탁의 무효로 대항할 수 없는 제3자에 해당하지 않는다. → O (수탁자의 물권을 기초로 새로운 이해관계를 맺은 자가 아니다)
9. 무효인 양자간 명의신탁에서 신탁자는 수탁자에게 소유권에 기한 말소등기를 청구할 수 있다. → O (등기가 무효이므로 신탁자가 여전히 소유자이다)
10. 무효인 양자간 명의신탁에서 수탁자로부터 부동산을 매수하여 등기를 이전받은 자는 악의인 경우 소유권을 취득하지 못한다. → X (선의·악의 불문 유효하게 취득한다)
11. 조세포탈 목적 없이 종중이 종중 소유 토지를 종손 명의로 등기한 경우, 종중은 종손에게 소유권에 기한 말소등기를 청구할 수 있다. → X (유효한 명의신탁이므로 대외적 소유자는 수탁자이고, 종중에게 물권적 청구권이 없다)
12. 위 사안에서 종중은 명의신탁 해지를 원인으로 하여 말소등기를 청구할 수 있다. → O (약정이 유효하므로 해지가 가능하다)
13. 위 사안에서 종중은 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있다. → O (해지의 효과로 실체관계에 부합하는 등기를 구할 수 있다)
14. 위 사안에서 종중은 토지를 불법점유하는 제3자에게 직접 소유물반환청구권을 행사할 수 있다. → X (대외적 소유자가 아니므로 직접 행사할 수 없다)
15. 중간생략등기형 명의신탁에서 신탁자와 매도인 사이의 매매계약은 무효이다. → X (명의신탁약정과 등기만 무효이고 매매계약은 유효하다)
16. 중간생략등기형 명의신탁에서 매도인은 수탁자에게 말소등기를 청구할 수 있다. → O (수탁자 명의 등기가 무효여서 매도인이 여전히 소유자이다)
17. 중간생략등기형 명의신탁에서 신탁자는 수탁자에게 직접 등기의 말소를 청구할 수 있다. → X (신탁자·수탁자 사이에 계약관계가 없고 신탁자가 소유자도 아니어서 대위행사만 가능하다)
18. 중간생략등기형 명의신탁에서 신탁자는 매도인을 대위하여 수탁자 명의 등기의 말소를 청구할 수 있다. → O (매매계약상 이전등기청구권을 피보전채권으로 한 채권자대위)
19. 중간생략등기형 명의신탁에서 신탁자가 목적 부동산을 점유하고 있는 동안에는 매도인에 대한 소유권이전등기청구권의 소멸시효가 진행하지 않는다. → O (점유하는 매수인의 등기청구권 법리)
20. 계약명의신탁에서 매도인이 계약 체결 당시 명의신탁약정을 알지 못하였다면, 신탁자와 수탁자의 명의신탁약정도 유효로 된다. → X (약정은 여전히 무효이고, 수탁자의 소유권 취득만 유효하다)
21. 계약명의신탁에서 매도인이 계약 당시에는 몰랐으나 그 후 명의신탁 사실을 알게 되면 수탁자 명의의 등기는 무효로 된다. → X (선의 여부는 계약 체결 시를 기준으로 하며, 이미 유효하게 성립한 소유권 취득은 번복되지 않는다)
22. 계약명의신탁에서 매도인이 선의인 경우, 신탁자는 매도인을 대위하여 수탁자 명의 등기의 말소를 청구할 수 있다. → X (매도인·수탁자 사이의 매매가 유효하여 대위의 피보전채권이 존재하지 않는다)
23. 계약명의신탁에서 매도인이 악의인 경우, 신탁자는 수탁자에게 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있다. → X (매매계약이 무효여서 소유자는 매도인이고, 신탁자는 매수자금의 반환만 구할 수 있다)
24. 신탁자가 자금을 제공하고 수탁자가 경매절차에서 부동산을 매수하여 등기를 마친 경우, 제3자가 명의신탁 사실을 알고 있었다면 수탁자는 소유권을 취득하지 못한다. → X (경매의 경우 타인의 인식 여부와 무관하게 매수인인 수탁자가 유효하게 소유권을 취득한다)

25. 위 경매 사안에서 신탁자는 수탁자에게 지급하였던 경락대금 상당액의 반환을 청구할 수 있고, 신탁자가 그 부동산을 점유하더라도 타주점유이다. → O (부당이득반환청구만 가능하고, 소유의 의사가 인정되지 않는다)
26. 구분소유적 공유관계에서 각 구분소유자는 다른 공유자의 동의 없이 자신이 구분소유하는 부분을 배타적으로 사용할 수 있다. → O (대내적으로는 특정부분의 단독소유이다)
27. 구분소유적 공유관계에서 甲은 乙이 구분소유하는 부분을 불법점유하는 자에게 반환청구나 손해배상청구를 할 수 있다. → X (자신의 구분부분에 대해서만 청구할 수 있다)
28. 구분소유적 공유관계를 해소하려면 공유물분할청구를 하여야 한다. → X (상호명의신탁의 해지를 원인으로 한 지분이전등기청구에 의한다)

이로써 민법 및 민사특별법 전 범위의 정리를 마친다. 본법은 사례형 출제 비중이 높으므로, 사안에서 **계약당사자가 누구인지**를 먼저 확정한 뒤 등기의 효력과 소유권 귀속, 구제수단의 순서로 판단하는 습관을 들이면 대부분의 지문을 해결할 수 있다.

99. 시험 직전 최종점검

이 장은 01~16장 전체에서 뽑은 **숫자·기간표**, **가장 자주 틀리는 함정 TOP 30**, **남은 5주 학습전략**으로 구성된다. 시험 전날·당일 아침에는 이 장만 다시 훑어도 충분하도록 만들었다.

① 민법 전체 암기 숫자·기간 총정리표 ★★★

1. 제척기간(형성권·취소권 등 행사기간)

권리	기간	기산점
취소권(제한능력·착오·사기·강박)	**3년 / 10년**	추인할 수 있는 날부터 3년, **법률행위를 한 날부터 10년** 중 먼저 도래하는 때
매매 예약완결권(행사기간 미정)	**10년**	예약이 **성립한 날**부터(완결권을 행사할 수 있는 때부터가 아님)
점유물반환청구권	**1년**	침탈당한 날부터 — **출소기간**(재판상 행사 필수)
매도인 담보책임 - 권리의 하자(일부타인권리·수량부족·제한물권)	**1년**	선의: 사실을 **안 날** / 악의: **계약한 날**
매도인 담보책임 - 물건의 하자(특정물·종류물)	**6개월**	하자를 **안 날**부터(악의자는 권리 자체가 없음)
매도인 담보책임 - 전부타인권리 / 저당권·전세권 실행	**제척기간 없음**	악의자도 구제되는 대신 기간 제한도 없음
임차인의 비용상환청구권(제654조→제617조 준용)	**6개월**	임대인이 목적물을 **반환받은 날**부터
상가건물임대차 권리금 손해배상청구권	**3년**	임대차가 **종료한 날**부터(소멸시효)

2. 시효취득 기간

구분	기간	요건
부동산 점유취득시효(제245조①)	**20년**	소유의 의사·평온·공연(선의·무과실 불요)
부동산 등기부취득시효(제245조②)	**10년**	자주·평온·공연 + **선의·무과실** + 소유자로 등기
동산 취득시효(제246조)	**10년(일반) / 5년(선의·무과실)**	-
분묘기지권(취득시효형)	**20년**	장사법 시행 전 설치된 분묘, 등기 불요
지상권·지역권·전세권의 소멸시효	**20년** 불행사	용익물권도 시효로 소멸할 수 있는 유일한 물권군

3. 무주물·유실물·매장물

구분	공고 후 기간	귀속
유실물 습득	**6개월**	습득자
매장물 발견	**1년**	발견자(타인 토지면 토지소유자와 절반씩)

4. 물권 관련 숫자

항목	숫자
지상권 최단존속기간 - 견고건물·수목	**30년**
지상권 최단존속기간 - 그 밖의 건물	**15년**(종류·구조 미정 시에도 15년)
지상권 최단존속기간 - 공작물	**5년**
지상권 최장기간	**제한 없음**(영구 가능)

지상권 지료 연체로 소멸청구	**2년분**
전세권 최단기간(건물만, 토지는 제한 없음)	**1년**
전세권 최장기간(토지·건물 공통)	**10년**
전세권 법정갱신 통지기간(건물)	만료 전 **6개월~1개월**
전세권 기간 정함 없을 때 소멸통고 후	**6개월** 경과로 소멸
공유물분할금지특약 최장기간	**5년**(갱신도 갱신일로부터 5년까지)
저당권 지연배상(원본이행기 경과 후) 우선변제 한도	**1년분**(근저당권은 이 제한 없음)

5. 담보물권 특별법 숫자

항목	숫자
가등기담보 청산기간	실행통지 도달일부터 **2개월**

6. 매매·계약 관련 숫자

항목	숫자
환매기간 - 부동산	**5년**(초과 약정 시 5년으로 단축, 재연장 불가)
환매기간 - 동산	**3년**

7. 민법상 임대차(총론) 숫자

항목	숫자
단기임대차(처분권한 없는 자) - 식목·채염·견고건축 목적 토지	**10년**(갱신은 만료 전 1년 내)
단기임대차 - 그 밖의 토지	**5년**(갱신은 만료 전 1년 내)
단기임대차 - 건물 기타 공작물	**3년**(갱신은 만료 전 3개월 내)
단기임대차 - 동산	**6개월**(갱신은 만료 전 1개월 내)
기간 약정 없는 임대차 - 임대인이 해지통고(부동산)	**6개월**
기간 약정 없는 임대차 - 임차인이 해지통고(부동산)	**1개월**
기간 약정 없는 임대차 - 해지통고(동산)	**5일**
차임연체로 인한 해지 기준(건물·토지 공통)	**2기**

8. 주택임대차보호법 vs 상가건물임대차보호법 숫자 비교 (최다 출제)

항목	주택임대차보호법	상가건물임대차보호법
대항력 발생	인도+주민등록 익일 **0시**	인도+사업자등록신청 익일 **0시**
최단존속기간	**2년**	**1년**
계약갱신요구 행사기간	종료 전 **6개월~2개월**	종료 전 **6개월~1개월**
갱신요구 한도	**1회**(갱신기간 2년)	최초기간 포함 **10년**
차임연체 해지·갱신거절 기준	**2기**	**3기**
최우선변제 한도	주택가액의 **1/2**	상가건물가액의 **1/2**
권리금 보호기간	규정 없음	종료 전 **6개월**부터 종료 시까지
권리금 손해배상 소멸시효	-	종료일부터 **3년**

권리금 - 정당한 거절사유(미사용기간)	-	**1년 6개월** 이상 미사용

구체적 원화 금액(소액보증금 기준액, 환산보증금 기준액, 최우선변제 한도액)은 시행령 사항으로 개정이 매우 잦다. 반드시 **시험 시행일 기준 최신 법령**으로 확인할 것 — 이 노트에는 의도적으로 기재하지 않았다.

9. 집합건물법 결의정족수

사항	정족수
공용부분의 경미한 변경	**과반수**
공용부분의 중대한 변경 / 규약의 설정·변경·폐지 / 법위반자 전유부분 경매청구	각 **4분의 3** 이상
재건축 결의	각 **5분의 4** 이상(단지 일괄 재건축은 각 동별로도 5분의 4)
관리단집회 소집통지 생략	구분소유자 **전원**의 동의
관리인 선임 의무화 기준	구분소유자 **10인** 이상

10. 소멸시효 vs 물권적 청구권 — 시효로 소멸하지 않는 것

- 소유권, 점유권, 소유권에 기한 물권적 청구권 → **소멸시효 적용 없음**.
- 공유물분할청구권 → 공유관계가 존속하는 한 **시효로 소멸하지 않음**.
- 점유취득시효 완성자의 등기청구권(채권적 청구권) → **점유를 계속하는 동안**에는 소멸시효가 진행하지 않고, **점유를 상실하면 그때부터** 진행.
- 지상권·지역권·전세권 → **20년** 불행사 시 소멸시효로 소멸 가능(용익물권 중 유일하게 시효소멸 대상).

② 함정 TOP 30 ★★★

함정 주의

1. **2기 vs 3기** — 민법상 임대차·주택임대차보호법의 차임연체 해지 기준은 **2기**, 상가건물임대차보호법은 **3기**. 숫자를 바꿔 출제하는 최빈출 함정.
2. **2개월 vs 1개월(갱신요구 행사기간)** — 주택은 종료 전 6개월~**2개월**, 상가는 6개월~**1개월**.
3. **1회 vs 10년** — 주택 갱신요구권은 **1회**(2년), 상가는 최초기간 포함 **10년** 한도로 횟수 제한 없음.
4. **권리의 하자(1년) vs 물건의 하자(6개월)** — 매도인 담보책임의 제척기간을 서로 바꿔 놓는 지문이 매년 나온다.
5. **법정지상권(저당권 설정 당시) vs 관습법상 법정지상권(처분 당시)** — 동일인 소유 판단 시점이 다르다.
6. **지상권 최단기간 "5년"으로 바꾼 함정** — 종류·구조를 정하지 않은 지상권은 **15년**(제280조 제1항 제2호)이지 5년이 아니다.
7. **전세권 법정갱신 후 존속기간 "1년/2년"** — 실제로는 **기간의 정함이 없는 것**으로 본다.
8. **유치권의 우선변제권** — 유치권에는 **우선변제권·물상대위가 없다**. "경매하여 우선변제 받는다"는 지문은 틀림(사실상 우선변제 효과만 있을 뿐).
9. **저당권 효력 범위의 과실** — **압류 후**의 과실에만 미친다. 부합물·종물은 설정 전후 불문하고 미친다는 것과 혼동하지 말 것.
10. **근저당권 지연배상 "1년분 제한"** — 보통저당권과 달리 근저당권은 이 제한이 **없다**(채권최고액 범위 내 전액 우선변제).
11. **공동저당 후순위자 대위 vs 물상보증인 우선** — 계산문제는 동시배당 시 **경매대가에 비례한 안분**이 기본 공식이다.
12. **가등기담보 청산금 산정시점** — 법 **적용 여부**는 예약(계약체결) 당시 가액 기준, **청산금 산정**은 실행통지(청산) 당시 가액 기준으로 서로 다르다.
13. **계약금은 "위약금"으로 추정된다는 함정** — 실제로는 **해약금**으로 추정된다(제565조). 위약금이 되려면 별도 약정이 필요.
14. **위약금은 "위약벌"로 추정된다는 함정** — 실제로는 **손해배상액의 예정**으로 추정된다.
15. **해약금 해제의 기준 — "자신이" 이행 착수 vs "상대방"** — 정확히는 **당사자 어느 일방이라도** 이행에 착수하면 해제할 수 없다(자신이 착수 안 해도 상대방이 착수했으면 불가).
16. **계약금 일부만 지급된 경우 배액 기준** — **실제 지급액이 아니라 약정 계약금 전액**의 배액을 상환해야 한다.
17. **동시이행항변권 "한번 제공하면 끝"이라는 함정** — 이행제공을 **계속하지 않으면** 상대방의 항변권이 다시 살아난다.
18. **선이행의무자의 항변권 전환** — 선이행의무를 이행하지 않은 채 **상대방의 이행기가 도래하면** 그때부터 동시이행관계로 전환된다.
19. **위험부담 — 매수인 귀책 시 매도인의 "해제" 가능 여부** — 매수인(채권자) 귀책이면 매도인은 **대금청구만** 가능하고 해제는 할 수 없다(매도인에게 귀책사유가 없어 해제권 자체가 없음).
20. **제3자를 위한 계약 — 기본관계 하자 vs 대가관계 하자** — 낙약자는 **기본관계(요약자-낙약자)**의 하자로는 수익자에게 대항할 수 있으나, **대가관계(요약자-수익자)**의 하자로는 대항할 수 없다.
21. **해제의 제3자 — "전"은 선악불문, "후"는 선의만** — 해제 **전** 등기한 제3자는 선·악 불문 보호, 해제 **후** 등기한 제3자는 선의만 보호.
22. **임차권등기명령에 의한 등기말소의무와 보증금반환의무** — 동시이행관계가 **아니며**, 임대인의 보증금반환의무가 **먼저** 이행되어야 한다(임대인의 목적물반환-보증금반환은 동시이행이지만, 임차권등기명령 말소는 다르다).
23. **토지임차인의 지상물매수청구권 vs 건물임차인의 부속물매수청구권 — 임대인 동의 요부** — 지상물매수청구권은 **임대인 동의 불요**, 부속물매수청구권은 **임대인 동의(또는 매수) 필요**.
24. **무단전대 — 임대인의 전차인에 대한 직접 차임청구** — 임대인이 해지하지 않았어도 **전차인에게 직접 차임을 청구할 수 없다**(임대인-전차인 사이 직접 법률관계 없음).
25. **주택임대차 대항력 발생시점 계산** — 인도와 주민등록을 **모두 갖춘 날의 다음 날 0시**부터. 같은 날 저당권이 설정되면 저당권이 선순위가 된다.
26. **다가구주택 vs 다세대주택 전입신고** — 다가구는 **지번만** 기재해도 대항력 인정, 다세대는 **동·호수까지** 정확히 기재해야 한다.
27. **공용부분의 지분·사용 — "균등추정"·"지분비율 사용"이라는 함정** — 공용부분 지분은 **전유부분 면적비율**(균등추정 아님), 사용은 **용도에 따라**(지분비율 아님) — 민법상 공유와 정반대.
28. **계약명의신탁 — 매도인 선의 시 신탁자의 구제수단** — 신탁자는 수탁자에게 **소유권이전등기를 청구할 수 없고**, **매수자금 상당액의 부당이득반환**만 청구할 수 있다.
29. **3자간(중간생략등기형) 명의신탁 — 신탁자의 직접청구 가능 여부** — 신탁자는 수탁자에게 **직접** 말소를 청구할 수 없고, **매도인을 대위**하여서만 가능하다.
30. **명의신탁 무효의 제3자 대항 — "선의자만 보호"라는 함정** — 부동산실명법 제4조 3항의 제3자는 **선의·악의를 불문**하고 보호된다(해제의 제3자와 다른 법리이므로 혼동 주의).

③ 남은 5주 학습전략 ★★★

1. 출제 비중(강사 제시 구조 — 40문항)

영역	문항수	해당 단원
민법총칙	10문제	01~03장(법률행위·의사표시, 대리, 무효·취소·조건·기한)
물권법	14문제	04~08장(물권총론·물권변동, 점유권, 소유권, 용익물권, 담보물권)
계약법	10문제	09~11장(계약법총론, 매매·교환, 임대차)
민사특별법	6문제	12~16장(주택·상가임대차보호법, 집합건물법, 가등기담보법, 부동산실명법)

합격선은 과목 **40점 이상** + 1차 평균 **60점 이상**(부동산학개론과 합산)이다. 물권법이 14문제로 가장 비중이 크므로 **물권법 이해가 곧 민법 점수**라고 봐도 무방하다.

2. 주차별 배분(총 5주)

1. **1주차 — 물권법 집중 정리(04~08장)**: 물권변동(등기 필요/불필요), 점유권(자주·타주 전환), 소유권(공유 사례·상린관계·취득시효), 용익물권(지상권·법정지상권·전세권), 담보물권(유치권·저당권·근저당권 비교표)을 표 중심으로 재암기한다. 14문제 중 **물권변동·공유·용익물권·담보물권 비교표**에서 절반 이상이 나온다.
2. **2주차 — 민법총칙 정리(01~03장)**: 강행규정·반사회질서·불공정행위(무효 유형), 비진의표시·통정허위표시·착오·사기강박(제3자 보호 범위), 대리(표현대리 3유형·무권대리인 책임), 취소·조건·기한의 숫자(3년/10년)를 정리한다. 총칙은 **절대적 무효 vs 상대적 무효**(선의의 제3자 대항 가부)가 가장 자주 나온다.
3. **3주차 — 계약법 정리(09~11장)**: 동시이행항변권 인정·부정 사례표, 위험부담(제537·538조 사례), 해제의 효과와 제3자 보호, 매매(담보책임 비교표·계약금), 민법상 임대차(지상물매수청구권·전대차)를 반복한다. 특히 **매도인 담보책임 비교표(선의·악의·제척기간)**는 계산 없이 암기로 승부가 나는 구간이라 효율이 매우 높다.
4. **4주차 — 민사특별법 정리(12~16장)**: 주택임대차보호법·상가건물임대차보호법을 **반드시 나란히 비교**(대항력·우선변제권·최우선변제·갱신요구권 표)하고, 집합건물법 결의정족수, 가등기담보법 청산절차, 부동산실명법 3유형(양자간·3자간·계약명의신탁) 비교표를 사례 중심으로 암기한다. 6문제뿐이지만 **비교표 하나만 확실히 알면 2~3문제를 그대로 가져가는** 고효율 구간이다.
5. **5주차 — 전 범위 모의고사·오답노트·이 장(99장) 반복**: 실전 모의고사를 매일 1회분씩 풀며 시간 배분을 연습하고, 오답은 해당 단원의 "함정 주의" 박스와 대조한다. 마지막 2~3일은 **99장의 숫자표·함정 TOP 30만** 반복해서 읽는다.

3. 버릴 곳 / 잡을 곳

구분	내용
반드시 잡을 곳 (고효율)	동시이행 인정·부정 사례표, 매도인 담보책임 비교표, 물권변동 등기 필요/불필요표, 자주·타주점유 전환표, 공유 사례(과반수·소수지분권자), 유치권·저당권 비교표, 주임법·상임법 비교표, 명의신탁 3유형 비교표 — **전부 "표로 정리된 결론 암기"만으로 정답률이 오른다.**
시간 대비 효율이 낮은 곳	등기의 추정력 세부 판례(사망자 명의 등기 등 지엽적 예외), 집합건물법의 세부 정족수 중 "자료 확인 필요"로 표시된 항목, 환매의 세부 절차 — 기본 결론만 알고 지엽적 지문은 과감히 넘긴다.
계산문제	공동저당 안분배당(제368조 1항), 가등기담보 청산금 계산(실행통지 당시 가액 – 피담보채권액) 두 유형만 공식을 정확히 익히면 충분하다. 출제빈도가 낮으므로 시간을 많이 투자하지 않는다.

핵심 암기

남은 5주 원칙은 **"표를 외워라, 조문 전문을 외우지 마라"**이다. 민법 시험은 판례의 결론(가능/불가능, 유효/무효, 인정/부정)을 정확히 아는지를 묻는다. 각 장의 **비교표와 "함정 주의" 박스**만 시험 전까지 반복하면 과목 40점(16문항 정답)은 물권법·계약법의 비교표만으로도 충분히 확보된다.

이것으로 「민법 및 민사특별법」 전 16개 장(총론 3·물권법 5·계약법 3·민사특별법 5)의 요약노트가 완성되었다. 남은 5주, 이 노트 한 권만 반복하면 된다.